

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

БИЛТЕН

Бр. 2



Ниш, 2012. године

БИЛТЕН

АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

ИЗДАВАЧ: Intermex, Београд, Булевар војводе Мишића 37/II
За издавача: Љиљана Миланковић-Васовић, директор

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК: Новица Стефановић,
в.ф. председника Апелационог суда у Нишу

ЗАМЕНИК
ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ
УРЕДНИКА: Зоран Ђорђевић,
судија Апелационог суда у Нишу

РЕДАКЦИЈСКЕ ГРУПЕ
За кривично право: судија Снежана Милошевић - руководилац групе
судија Вера Милошевић - члан
судија Мирјана Ђорђевић - члан

За грађанско право: судија Зоран Ђорђевић - руководилац групе
судија Јелена Јовановић - члан
виши судијски сарадник Јелена Станковић - члан

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: Милена Симоновић, виши судијски сарадник

ШТАМПАРИЈА: "CICERO", Београд

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
34

БИЛТЕН Апелационог суда у Нишу / главни и одговорни уредник Новица Стефановић. - бр. 2, 2012- . - Београд (Булевар војводе Мишића 37/II) : Intermex, 2012- (Београд : "CICERO"). - 22 cm

Три пута годишње. - Је наставак: Билтен судске праксе - Окружни суд у Нишу = ISSN 1452-6603
ISSN 2217-4125 = Билтен Апелационог суда у Нишу - COBISS.SR-ID 179852044

Свако копирање, умножавање, објављивање и дистрибуирање целине или делова текста из ове публикације представља повреду ауторског права и кривично дело (сходно одредбама чл. 215.-217. Закона о ауторском и сродним правима, и чл. 198.-202. Кривичног законика).

Коришћење делова текста из овог Билтена дозвољено је сходно ауторском праву и уз сагласност издавача.

САДРЖАЈ

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ ЗА 2013. ГОДИНУ	5
---	---

СУДСКА ПРАКСА

ГРАЂАНСКО ПРАВО	11
КРИВИЧНО ПРАВО	17
Кривично право.....	19
Кривично процесно право.....	45

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА

Ненад Стојановић

Преиначење правоснажне пресуде без понављања кривичног поступка (чл. 405. ст.1. тач. 1. ЗКП)	85
---	----

Зоран Ђорђевић

Примена Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији ("Сл. гласник РС" бр. 104/2009).....	93
--	----

ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ ЗА 2013. ГОДИНУ

I

СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи председник суда.

За заменика председника суда одређује се судија Братислав Крстић.

Заменику председника суда, поред општих послова, поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то:

1. доношење и потписивање аката судске управе у одсуству председника суда, а које нису у искључивој – непреносивој надлежности председника суда;
2. поступање по притужбама и захтевима за изузеће судија;
3. поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
4. спровођење и праћење Програма решавања старих предмета.

Посебне обавезе поверавају се судији Снежани Милошевић за информисање и контакте с јавношћу и медијима (портпарол).

II

СУДСКА ОДЕЉЕЊА

За председнике судских одељења одређују се и то:

1. У Одељењу судске праксе: председник Новица Стефановић, вршилац функције председника суда; заменици судија Вера Милошевић, Мирослава Миловановић и судија Зоран Ђорђевић.

2. У Кривичном одељењу: председник, судија Снежана Милошевић, а заменик Зоран Поповић.

3. У Грађанском одељењу: председник, судија Слађана Ђуричковић, заменик судија Миомир Митровић.

4. У Одељењу радних спорова: председник судија Зоран Ђорђевић, заменик судија Ивана Рађеновић.

III

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1.

I - ВЕЋЕ

1. Вера Милошевић, председник већа
2. Љиљана Миљковић, члан
3. Ранко Банковић, члан

Судијски помоћници:

Ивана Лазовић и Милан Ђорђевић

II – ВЕЋЕ

1. Братислав Крстић, председник већа
2. Весна Стевановић, члан
3. Драгана Живадиновић, члан

Судијски помоћници:

Ана Јовичић, Милица Алексић и Зоран Ђурђевић.

Ово веће ће примати предмете у поступцима према малолетницима, те ће чинити и веће за малолетнике.

III - ВЕЋЕ

1. Снежана Милошевић, председник већа
2. Слободан Љубић, члан
3. Љубомир Јовановић, члан

Судијски помоћници:

Милош Увалин, Марија Петровић, Ненад Стојановић

IV – ВЕЋЕ

1. Зоран Поповић, председник већа
2. Мирјана Ђорђевић, члан
3. Слободан Стојилковић, члан

Судијски помоћници:

Иван Калезић, Ивана Милошевић и Владимир Станојевић.

V – ВЕЋЕ

1. Новица Стефановић, председник већа,
2. Горана Митић, члан,
3. Небојша Цолић, члан

Судијски помоћници:

Слађана Лендра

Веће за одлучивање у трећем степену биће у сваком конкретном предмету одређено посебном наредбом председника суда.

2.

Председника већа замењује први члан већа.

Попуна већа до пуног састава вршиће се према посебном распореду који ће месечно утврђивати председник Кривичног одељења.

Дежурна већа за време годишњих одмора у Кривичном одељењу:

1. у јулу месецу III веће,
2. у августу месецу IV веће

IV

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

I – ВЕЋЕ

1. Слађана Ђуричковић, председник већа,
2. Љиљана Јовановић, члан,
3. Миомир Митровић, члан

Судијски помоћници:

Бети Лазаревић, Јелена Божиловић и Сандра Стефановић

II – ВЕЋЕ

1. Мирослава Миловановић, председник већа,
2. Данијела Николић, члан,
3. Слободанка Китановић, члан

Судијски помоћници:

Милена Симоновић, Миљана Поповић Ђурић и Мирјана Милутиновић

Судије I и II већа примаће и предмете у вези породичних и статусних спорова, те ће чинити посебна већа за наведене спорове.

III – ВЕЋЕ

1. Миодраг Марјановић, председник већа,
2. Марина Милановић, члан

3. Александар Пантић, члан,

4. Јасмина Андрејевић, члан

Судијски помоћници:

Јелена Јанчетовић, Јелена Увалин, Јелена Голубовић и Горан Драгоман

V

ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

IV – ВЕЋЕ

1. Зоран Ђорђевић, председник већа,

2. Весна Вукас, члан

3. Тања Ристић, члан

Судијски помоћници:

Драгана Вељковић и Весна Јовановић-Јанковић

V – ВЕЋЕ

1. Јелена Јовановић, председник већа

2. Милица Манић, члан

3. Зорица Цветковић, члан

Судијски помоћници:

Ивана Ђурђић Митровић и Јелена Станковић

VI – ВЕЋЕ

1. Ивана Рађеновић, председник већа,

2. Љубиша Милојевић, члан

3. Слађана Стојановић, члан

Судијски помоћници:

Слађанка Тасић, Слађана Љубеновић и Наташа Митковић

VI

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Одељење судске праксе чине судије:

1. Новица Стефановић, вршилац функције председника суда,
2. Снежана Милошевић, председник Кривичног одељења,
3. Слађана Ђуричковић, председник Грађанског одељења,
4. Зоран Ђорђевић, председник Одељења радних спорова,
5. Вера Милошевић, руководиоца евиденције судске праксе у Кривичном одељењу,
6. Мирослава Миловановић, руководиоца евиденције судске праксе у Грађанском одељењу,
7. Судијски помоћник Горан Димитријевић у Кривичном одељењу, кога мења судијски помоћник Ненад Стојановић,
8. Судијски помоћник Златица Петровић у Грађанском одељењу, коју мења судијски помоћник Јелена Станковић,

СУДСКА ПРАКСА

ГРАЂАНСКО ПРАВО

ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

(Чл. 179. ст. 1. тач. 3. Закона о раду)

Судском особљу није дозвољен разговор са странкама о правилности судских радњи или одлука, или вероватном исходу спора, па стога покушај и иницирање разговора о судским предметима представља основ за дисциплинску одговорност запослених у суду, у смислу чл. 88. ст. 4. Судског пословника ("Службени гласник РС" бр. 65/2003 ... 50/2006).

Из образложења:

У конкретном случају правилно је првостепени суд ценио да се ради о акту недисциплине који је прописан општим актом послодавца и да је у конкретном случају запослени имао свест о недисциплини и ризику да употребљен отказни разлог може довести до престанка радног односа, јер је одредбом чл. 88. Судског пословника јасно и свеобухватно прописано шта чини недозвољено понашање судског особља, које подразумева сваки разговор са странком у вези поступања суда по иницијалном акту странке.

Тужила је недозвољено користила податке из службених списка, уз помоћ којих је прибавила телефонски број странке, што су несумњиво предузете радње којима је исказана намера, а затим и реализована позивањем странке, када је и обављен разговор, којим је тражено да се састане са странком ради разговора у вези предмета који је процесуиран пред судом.

Само контактирање странке и иницијатива да се разговара о судском предмету представља акт недисциплине због којег запослени не може наставити рад код послодавца, односно понашање које се не може толерисати, при том нарочито имајући у виду да до даљег разговора није дошло услед одустанка тужиле спознајом да се ради о акту недисциплине, већ напротив услед реакције странке на недозвољено понашање тужиле.

Стога, из изнетих разлога нису основани наводи жалбе којима се инсистира на томе да Судски пословник санкционише већ предузету радњу, али не и намеру запосленог, као и наводи којима се указује да дати разлози у побијаној пресуди нису јасни у погледу недозвољеног коришћења података из списка предмета, обзиром да је тужила управо податак о адреси странке прибавила из службених списка, а затим на основу тих података преко ПГТ службе прибавила кућни број телефона странке, што су радње

у провођењу њене намере да се учини акт недисциплине. Такође, жалбени наводи којима се указује да тужила није предузела конкретне радње које би се огледале у вођењу разговора о судским радњама или одлукама или о исходу спора не могу утицати на доношење другачије одлуке, обзиром да је разговор обављен у коме је захтевано да се разговара о судском предмету. Тиме што је даљи разговор о предмету спречен активном улогом странке указивањем на недозвољено понашање тужиле, то изнети наводи жалбе нису основани и не могу бити оправдавајући разлози у оспоравању решења о престанку радног односа.

Осим тога, законитост одлука о престанку радног односа цени се на основу чињеничног основа изнетог у самом решењу и на основу утврђених чињеница у поступку пред судом, стога уколико послодавац погрешно примени материјално право, не утиче на правилност одлука у погледу радно-правног статуса запосленог, јер о правилној примени материјалног права суд води рачуна по службеној дужности. Међутим, у конкретном случају, правилном применом одредбе чл. 140. ст. 1. и 171. ст. 3 Закона о државним службеницима, којим је регулисано овлашћење за одлучивање о правима и обавезама државних службеника и намештеника и чл. 179. тач. 3. Закона о раду, донето је оспорено решење, са ког становишта је правилно првостепени суд ценио законитост одлуке. Такође, тужила је у складу са одредбом чл. 180 Закона о раду упозорена на настали отказни разлог и омогућено јој је да се изјасни о чињеницама и околностима који су изнети у упозорењу и сходно чл. 181 истог Закона, затражено је мишљење синдиката.

На потпуно и правилно утврђено чињенично стање утврђено оценом свих приложених и предложених доказа првостепени суд је правилно применио материјално право ценећи законитост оспореног решења са процесноправног и материјалноправног становишта у свему дајући разлоге које прихвата и овај суд, а како се жалбеним наводима не доводи у сумњу утврђен чињенични основ, то изнети наводи не могу утицати на доношење другачије одлуке у овој правној ствари.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, 18Гж1.2380/11 од 02.12.2011. године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

ЗЛОУПОТРЕБА ПРАВА

(Чл. 9. ст. 3. Закона о парничном поступку)

Уколико странка предузме процесну радњу у поступку која је споља законита, али која је предузета са циљем који је противан намени процесног овлашћења и противна циљу поступка за пружање правне заштите, то представља злоупотребу права од стране странке у поступку.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању тужилац је био у радном односу код туженог, у периоду од 04.11.1988 године до 31.08.2002 године. Тужилац је тужбом тражио да се тужени обавезе да тужиоцу на име доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за 1993 и 1994 годину, уплати износ од 254.470,89 динара. У току поступка тужилац је проширио тужбу тражећи да му тужени, поред уплате доприноса, исплати и износ од 20.000,00 динара на име разлике накнаде зараде за период од 13.04.2008 до 13.04.2010 године. На основу тако постављеног захтева извршено је вештачење вештака финансијске струке, који је у свом налазу утврдио да нема услова за обрачун спорног потраживања тужиоца, по основу разлике накнаде зараде за период од 13.04.2008 год 13.04.2010 године јер нема доказа да је тужилац у означеном периоду био у радном односу код туженог, док је у вези доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање утврђено да тужени није уплатио тужиоцу доприносе за период од 19.10.1993 до 31.12.1994 године. Тужилац је дана 04.01.2011 године прецизирао тужбени захтев којим је тражио да се тужени обавезе да на име тужиоца уплати фонду ПИО, за период од 19.10.1993 до 31.12.1994 године, на основицу која важи у моменту уплате доприноса, у висини колико утврди вештак финансијске струке, као и да се обавезе тужени да тужиоцу исплати на име разлике накнаде зараде, за период од 19.10.1993 до 31.12.1994 године, износ од 200 динара са законском затезном каматом почев од дана подношења тужбе.

Одлучивање о самосталном тужбеном захтеву који се односи на обавезивање послодавца на уплату доприноса из обавезног социјалног осигурања не спада у надлежност суда опште надлежности јер се не ради о спору из чл. 1. ЗПП, па је тужилац након извршеног вештачења прецизирао тужбени захтев захтевајући разлику накнаде зараде, управо за период

за који захтева и уплату доприноса, јер би управо у том случају био надлежан основни суд у првом степену на основу чл. 22. ст. 3. Закона о уређењу судова у вези чл. 105. ст. 2. и 191. ст. 2. Закона о раду.

Одредбом чл. 9. ст. 3. Закона о раду прописано да је суд дужан да спречи сваку злоупотребу права која имају странке у поступку те да настоји да се поступак спроведе без одуговлачења и са што мање трошкова у складу са чл. 10. ЗПП. Тужилац је након више одржаних рочишта пред првостепеним судом и након изведених свих приложених и предложених доказа, прецизирао тужбени захтев у поднеску од 04.01.2011. године без навођења чињеничног основа и материјалног прописа на коме заснива своје новчано потраживање чија се заштита тражи, уз паушално навођење износа од по 200,00 динара месечно за спорни период, те на тај начин је исказана заправо тежња тужиоца да искористи процесну форму ради заснивања надлежности суда, па из изнетих разлога нису основани наводи жалбе да првостепени суд није требао да одбаци тужбу тужиоцу јер је уз накнаду зараде постављен и тужбени захтев о доприносима за обавезно пензијско и инвалидско осигурање.

(Из пресуда Апелационог суда у Нишу, 19 Гж1.724/11)

Аутор сентенце: Слађана Љубеновић,
судијски сарадник

СУДСКА ПРАКСА

КРИВИЧНО ПРАВО

КРИВИЧНО ПРАВО

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД КАЗНЕ

(Чл. 58. ст. 2.КЗ)

Нема законских услова да се учинилац ослободи од казне за кривично дело извршено са умишљајем.

Из образложења:

Испитујући првостепену пресуду због одлуке о кривичној санкцији, Апелациони суд налази да је неоснован жалбени предлог да се пресуда у овом делу преиначи и да се у смислу чл. 58. ст. 2. КЗ оптужени ослободи од казне.

Ово из разлога што је одредбом чл. 58. ст. 2. КЗ прописано да суд може ослободити од казне учиниоца кривичног дела учињеног из нехата кад последице дела тако тешко погађају учиниоца да изрицање казне у таквом случају очигледно не би одговарало сврси кажњавања.

У смислу наведене законске одредбе, за примену овог института, потребно је да су кумулативно испуњена два услова и то да је кривично дело учињено из нехата, као објективни услов који аутоматски произилази из законског решења, а други услов је субјективне природе и изражава однос између проузроковане последице и учиниоца дела.

У конкретном случају, из правилно утврђеног чињеничног стања, које се жалбом не оспорава, произилази да је у предметној саобраћајној незгоди смртно страдала супруга оптуженог, са којом је исти био у браку 32 године, а из побијане пресуде произилази и изјашњење оптуженог да је било боље да је погинуо он него његова супруга и изјашњење оштећеног да је изгубио мајку и не би желео да изгуби и оца, док се жалбом истиче и то да је оптужени размишљао о суициду јер га је тешко погодила смрт његове супруге. Из правилне оцене свих ових околности произилази да је услов субјективне природе за ослобођење од казне испуњен те да су оптуженог последице дела тешко погодиле.

Међутим, овај суд налази да за ослобођење од казне није испуњен објективни услов, који се тиче извршења кривичног дела из нехата, јер је доказима изведеним током поступка несумњиво утврђено да је оптужени био свестан да управљањем под дејством алкохола и неприлагођеном брзином кретања може угрожити јавни саобраћај и довести у опасност живот и тело људи па је на то пристао, из чега произилази да је у односу на основни облик кривичног дела поступао са евентуалним умишљајем. Како у конкретном случају умишљајно поступање искључује могућност примене института ослобођење од казне, то овај суд налази да се правилност закључивања првостепеног суда у овом делу неосновано побија изјављеном жалбом.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.2506/10 од 05.04.2011. године, пресуда Вишег суда у Нишу 3К.бр.124/10 од 23.04.2010. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД КАЗНЕ (Чл. 59. КЗ)

Приликом одлучивања о примени института ослобађања од казне из чл. 59. КЗ првостепени суд осим испуњености објективног услова који се односи на запрећену казну за кривично дело у питању цени и да ли је окривљени испунио обавезе из споразума постигнутог са оштећеном.

Из образложења:

Правилно је првостепени суд у ситуацији када су и окривљени и оштећена на главном претресу изјавили да је окривљени испунио све обавезе из споразума који је са оштећеном постигао нашао да окривљеног треба ослободити од казне применом чл. 59. КЗ.

Неосновано јавни тужилац жалбом побија првостепену пресуду због ослобођења окривљеног од казне наводећи да првостепени суд као доказ није извео споразум о потпуној накнади штете окривљеног према оштећеној, јер по оцени Апелационог суда, у ситуацији када из одбране окривљеног и исказа оштећене произилази да је окривљени испунио своје

обавезе које је на основу постигнутог споразума са оштећеном преузео, постојање писменог споразума о накнади штете није нужан услов за примену института ослобађања од казне.

(Пресуда Основног суда у Врању К.бр.874/10 17.03.2011. године и пресуда Апелационог суда у Нишу IКж.1.бр.3391/11 од 27.09.2012.год.)

Приредиле: Вера Милошевић, судија и
Ивана Лазовић, Виши судијски помоћник

КРИВИЧНО ДЕЛО УБИСТВО

(Чл. 113. КЗ)

Постојање умишљаја код кривичног дела убиство из чл. 113. КЗ процењује се на основу целокупног понашања оптуженог, како у моменту наношења повреде, тако и након тога.

Из образложења:

По налажењу Апелационог суда, у конкретном случају оптужени је извршио кривично дело које му се ставља на терет са директним умишљајем, јер је био свестан да на описани начин може оштећеног лишити живота, па је то и хтео, а имајући у виду све утврђене чињенице, које се односе на поступање оптуженог, као и на начин наношења повреде оштећеном, њену тежину и последице. Наиме, оптужени је критичном приликом оштећеном задао један ударац у пределу главе, док је стајао иза њега, при чему је био свестан да му на тај начин задаје повреду која може довести до смрти оштећеног, па је то и хтео, имајући у виду средство наношења повреде, као и да је оштећеног ударио по глави, знајући да на тај начин може наступити смрт оштећеног. Ово произилази и из целокупног понашања оптуженог, како у моменту наношења повреде, тако и након тога, с обзиром да је после наношења повреде оштећеном истрчао из подрума носећи секиру, коју је бацио на кров трафостанице, дакле са намером да исту сакрије.

(Пресуда Вишег суда у Нишу IК.бр.17/10 од 17.03.2010. године и пресуда Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.4099/10 од 20.09.2011. године)

Приредила: судија Горана Митић

УЧЕСТВОВАЊЕ У ТУЧИ

(Чл. 123. КЗ)

Нема кривичног дела учествовања у тучи ако лицима која физички нападну оштећеног, оштећени нити неко друго лице не узврате напад.

Из образложења:

Предлогом за изрицање васпитне мере малолетном сада пунолетном С.С. стављено је на терет да је са два пунолетна лица, према којима је поступак издвојен, учествовао у тучи у којој је оштећени М.С. задобио тешку телесну повреду на тај начин што је најпре пунолетни М.С. песницом неколико пута ударио оштећеног у пределу главе, од којих удараца се оштећени сагао и рукама прекрио лице како би се заштитио, те су малолетни сада пунолетни С.С. и пунолетни М.С., више пута песницама ударали и ногама шутирали оштећеног у пределу главе, на који начин је оштећени задобио тешку телесну повреду у виду прелома доње вилице.

Првостепени суд је правилно нашао да наведене радње извршења, према опису из предлога за изрицање васпитне мере, не представљају радње извршења кривичног дела учествовања у тучи које му је стављено на терет. Ово из разлога што кривично дело учествовања у тучи у смислу чл. 123. Кривичног законика, чини онај ко учествује у тучи у којој је неко лишен живота, или је другом нанешена тешка телесна повреда.

У конкретном случају, у чињеничном опису дела које је малолетном сада пунолетном С.С. стављено на терет описано је да су С.С. и пунолетна лица М.С. и М.С. ударали оштећеног рукама и ногама у пределу главе, да се је оштећени сагао и прекрио лице рукама како би се заштитио, а да су исти наставили да га ударају, услед чега је оштећени задобио описану тешку телесну повреду.

Апелациони суд налази да је правилно првостепени суд утврдио да из оваквог описа радње извршења, која је малолетном сада пунолетном С.С. стављена на терет, не произилази да је са наведеним лицима учествовао у тучи, већ да су исти тукли оштећеног. Ово из разлога што учествовање у тучи подразумева размену удараца више лица, при чему се учесници у тучи или међусобно нападају или једни нападају, а други се бране, тако што и сами нападају. Из предлога тужиоца и чињеничног утврђења

првостепеног суда произилази да су наведена лица тукла оштећеног, а да им оштећени ударце није узвраћао, већ да је рукама покрио главу покушавајући да се заштити што указује на пасивно учешће оштећеног.

С тога, правилно је првостепени суд утврдио да из оваквог описа радње извршења не произилази да је малолетни сада пунолетни С.С. учествовао у тучи јер недостаје битан елемент овог кривичног дела, а то је туча, обзиром да из наведеног описа радње не произилази да је било узвраћеног напада, а самим тим ни туче, због чега је правилно утврђено да наведене радње нису кривично дело.

(Решење Апелационог суда у Нишу 5Кжм.1.бр.43/12 од 14.08.2012. године, решење Вишег суда у Лесковцу Км.бр. 15/12 од 21.06.2012. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

РАЗБОЈНИШТВО

(Чл. 169. ст. 1. КЗ РС)

Тиме што је у изреци пресуде изостао идентитет оштећеног лица према коме је упућена сила и претња, што представља битан елемент кривичног дела разбојништво, учињена је битна повреда одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП .

Из образложења:

Одредба чл. 169. ст. 1. КЗ РС прописује да кривично дело тешки случајеви разбојничке крађе и разбојништва постоји ако је при извршењу разбојничке крађе или разбојништва нанесена неком лицу са умишљајем тешка телесна повреда или ако је разбојништво учињено у саставу групе или банде. Тумачењем ове одредбе произилази да је за постојање предметног кривичног дела нужно да је учинилац или један од учесника у извршењу овог кривичног дела употребио силу или претњу према неком лицу, те да је претња непосредна и конкретна која код тог лица изазива осећај страха за његов живот и тело.

Из изреке пресуде произилази да су оптужени у намери да себи прибаве противправну имовинску корист озбиљном претњом да ће напасти на живот непознатих оштећених применом силе од оштећених одузели ствари, те је јасно да се не зна која су то лица и да ли су код истих изазвани цитирани осећаји и конкретно да ли је према њима употребљена сила или претња нападом на њихове животе.

На наведени начин учињена је битна повреда одредбе из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП, те је првостепена пресуда морала бити укинута.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 2Кж.1 4280/11 од 04.09.2012.г. и пресуда Окружног суда у Косовској Митровици К.бр.3/00 од 15.03.2001.г.)

Приредила: судија Љиљана Миљковић

СУБЈЕКТИВНО ОБЕЛЕЖЈЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА КЛЕВЕТА

(Чл. 171. КЗ)

Умишљај код кривичног дела клевета обухвата све битне елементе овог дела и то да је учинилац свестан да износи или преноси нешто што је неистинито, да то може да шкоди части и угледу неког лица и да то хоће.

Из образложења:

Дати разлози побијане пресуде о постојању директног умишљаја у поступању окривљеног који се огледа у свести да потписивањем петиције и достављањем фонду Пензијског и инвалидског осигурања заједно са захтевом и дописом у коме се износе неистините тврдње у смислу да је право на туђу помоћ и негу остварено на основу лажних докумената и помоћу својих пријатеља и да је способан за рад а да штети државу, по налажењу Апелационог суда за сада не могу да буду прихваћени као правилни.

За постојање кривичног дела клевета из чл. 171. КЗ је неопходно да поред изношења неистине која може да шкоди части и угледу оштећеног постоји субјективни однос према кривичном делу, изражен кроз умишљај који обухвата све битне елементе кривичног дела, и то да је учинилац све-

стан да износи или преноси нешто што је неистинито, да то може да шкоди части и угледу неког лица и да то хоће односно да на то пристаје.

Жалбом браниоца се основано указује да намера и циљ окривљеног и осталих потписника петиције коју су потписали 23 мештана села Ораовица, није обухватала свест о неистинитости, нити може да представља исполњен вољни елемент умишљаја код субјективног обележја кривичног дела кроз хтење наступања последица. Сама чињеница да је петиција писана од стране више од двадесет лица, да је њена суштина изражена кроз предлог да Републички фонд ПИО Филијала Пирот испита и укине право на туђу негу и помоћ и да подносиоци петиције сматрају да је приватни тужилац право на туђу негу и помоћ остварио на основу лажне документације и својих пријатеља, јер знају да он чува козе и обавља кућне послове, доводе у сумњу закључке првостепеног суда о постојању умишљаја.

Из наведених разлога није прихватљив закључак првостепеног суда да је одредбом чл. 56 Устава РС утврђено право сваког да сам и заједно са другима упућује петиције државним органима или организацијама којима су поверена јавна овлашћења и да на њих добија одговоре, и да због упућене петиције нико не може да трпи штетне последице, осим ако је тиме учињено кривично дело, јер на овај начин Устав гарантује грађанима право на петицију и приговоре, али овим начелом никако не искључује примену основа утврђења и искључења постојања кривичног дела предвиђеног кривичним законом.

Да би применио ову одредбу Устава првостепени суд је морао да савесно и свестрано цени све изведене доказе и то самостално и у међусобној повезаности али и у вези са одбраном окривљеног у смислу чл. 352. ЗКП, да утврди одлучне чињенице за постојање субјективног односа окривљеног према делу као чињеничног питања и да затим донесе правилну одлуку у којој ће изнети потпуне разлоге о свим одлучним чињеницама на основу којих је утврђено постојање дела и кривица окривљеног.

(Пресуда Основног суда у Пироту 1К.бр. 1081/10 од 22.12.2011. године, и пресуда Апелационог суда у Нишу 4Кж.1.бр. 1470/12 од 05.06.2012. године)

Приредио: судија Братислав Крстић

КРИВИЧНО ДЕЛО НЕДАВАЊЕ ИЗДРЖАВАЊА

(Чл. 195. ст. 1. КЗ)

Кривично дело недавање издржавања може се извршити само са директним умишљајем.

Из образложења:

У образложењу пресуде, првостепени суд је утврдио да се у радњама окривљеног стичу сви битни елементи кривичног дела које му се ставља на терет, налазећи да је окривљени поступао са евентуалним умишљајем и у стању урачунљивости. Овакви разлози првостепеног суда су нејасни и противречни, с обзиром да је окривљени изреком пресуде оглашен кривим да је кривично дело извршио са умишљајем, јер је био свестан забрањености свог дела, па се стога не може поуздано утврдити да ли је кривично дело окривљени извршио са директним умишљајем, како произилази из изреке пресуде или са евентуалним умишљајем, како је наведено у образложењу пресуде.

Кривично дело недавање издржавања из чл. 195. ст. 1. КЗ које се окривљеном ставља на терет, може се извршити само са умишљајем, јер учинилац треба да је свестан да не даје издржавање потпуно или делимично. Стога је неопходно поуздано утврдити да ли је окривљени био свестан свог дела, односно да не даје издржавање за свог малолетног сина, јер у случају постојања евентуалног умишљаја, како је утврдио првостепени суд, учинилац је свестан радње извршења и других обележја кривичног дела, али у односу на последицу код њега постоји вероватноћа у њено наступање, јер је свестан да може доћи до наступања последице и ту могућност прихвата.

(Пресуда Основног суда у Врању К.бр.384/11 од 06.09.2011.године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж.1.бр.1172/12 од 29.03.2012.године)

Приредила: судија Горана Митић

КРИВИЧНО ДЕЛО НЕДАВАЊЕ ИЗДРЖАВАЊА**ИЗ ЧЛ. 195. СТ. 1. КЗ**

Приликом одлучивања да ли окривљени извршава обавезу издржавања своје деце, потребно је утврдити да ли су деца окривљеног постала пунолетна и када, као и да ли се налазе на редовном школовању.

Из образложења:

У образложењу пресуде цитира се исказ законског заступника оштећених, њихове мајке, која је изјавила да је оштећена у међувремену постала пунолетна, при чему се није изјаснила о томе када је наступила ова чињеница, нити је првостепени суд изводио доказе у том правцу. Стога је изрека пресуде, у којој стоји да су обе оштећене малолетне, противречна датим разлозима. Осим тога, ради се о чињеници која је од утицаја, јер окривљени има законску обавезу издржавања своје деце до њиховог пунолетства, а након тога уколико се налазе на редовном школовању, што првостепени суд није утврдио, тако да се за сада не може прихватити закључак првостепеног суда, да окривљени у наведеном периоду није извршавао своје обавезе према деци коју је био дужан да издржава. Из наведених разлога, основано се жалбом браниоца окривљеног указује на овај недостатак побијане пресуде, због чега је чињенично стање погрешно и непотпуно утврђено.

(Пресуда Основног суда у Прокупљу 5К.бр.1637/10 од 16.03.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж.1.бр.1396/11 од 26.03.2012. године)

Приредила: судија Горана Митић

ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЕЛО ТЕШКА КРАЂА У ПОКУШАЈУ

(Чл. 204. ст. 1. тач. 1. у вези чл. 33. и 61. ст. 4. Кривичног законика)

Када се оптуженом оптужницом ставља на терет кривично дело тешка крађа у покушају и саизвршилаштву из чл. 204. ст. 1. тач. 1. у вези чл. 30. и 33. Кривичног законика и кривично дело крађа из чл. 203. ст. 1. Кривичног законика, суд ће радње оптуженог правно квалификовати као продужено кривично дело тешка крађа у покушају из чл. 204. ст. 1. тач. 1. у вези чл. 33. и 61. ст. 4. Кривичног законика.

Из образложења:

Одредбом чл. 61. ст. 4. КЗ прописано је да у случају када оптужени изврши више истих или истоврсних кривичних дела, при том се код истоврсних кривичних дела подразумевају лакши или тежи облици истог кривичног дела, од којих нека могу остати у покушају, као што су у овом

случају обична и тешка крађа, за квалификацију продуженог кривичног дела узима се најтеже од извршених кривичних дела. У конкретном случају, оптужени МН је извршио кривично дело крађа из чл. 203. ст. 1. КЗ и кривично дело тешка крађа у покушају из чл. 204. ст. 1. тач. 1. у вези чл. 33. КЗ, због чега је овај суд преиначио правну квалификацију и оптуженог огласио кривим за продужено кривично дело тешка крађа у покушају из чл. 204. ст. 1. тач. 1. у вези чл. 33. и 61. ст. 4. КЗ“.

(Пресуда Основног суда у Прокупљу 3К.бр.343/10 и Пресуда Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр. 2169/10)

Приредила: судија Драгана Живадиновић

КРИВИЧНО ДЕЛО ИЗНУДА ИЗ ЧЛ. 214. КЗ

Код кривичног дела изнуда претња мора бити озбиљна и као такву мора да је схвати оштећени, који се на тај начин принуђује да нешто учини или не учини на штету своје или туђе имовине.

Из образложења:

Првостепени суд је оптуженог огласио кривим за кривично дело изнуда у покушају из чл. 214. ст. 2. у вези ст. 1. у вези чл. 30. Кривичног законика, јер је критичном приликом, у намери да себи прибави противправну имовинску корист, претњом покушао да принуди оштећеног да му на штету своје имовине преда 5.000 евра. При томе, у образложењу пресуде, првостепени суд наводи да се у његовим радњама стичу сва обележја наведеног кривичног дела, јер је био свестан свог дела и тога да му оштећени ништа не дугује и да ће стављање у изглед будућег извесног зла оштећеном код њега створити осећај угрожености и страха, због чега ће оштећени предати новац. На овај начин, првостепени суд није дао разлоге о одлучним чињеницама, које се односе на законска обележја наведеног кривичног дела, односно није дао разлоге о томе да ли је на начин описан у изреци пресуде, оптужени покушао да принуди оштећеног на предају новца, односно какву силу или озбиљну претњу је према њему применио. Ово зато што код овог кривичног дела претња мора бити озбиљна и као

такву мора да је схвати оштећени, који се на тај начин принуђује да нешто учини или не учини на штету своје или туђе имовине.

(Пресуда Основног суда у Лесковцу 1К.бр.1167/11 од 19.09.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж.1.бр.3208/11 од 07.11.2011. године)

Приредила: судија Горана Митић

КРИВИЧНО ДЕЛО НЕУПЛАЋИВАЊЕ ПОРЕЗА ПО ОДБИТКУ ИЗ ЧЛ. 229а СТ. 1 КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

Доприноси не спадају у кривично дело неуплаћивање пореза по одбитку из чл. 229а ст. 1 КЗ.

Из образложења:

Пресудом Основног суда у Нишу 11К.бр.5471/10 од 06.07.2011. године, окривљени Ј. М., на основу чл. 355. тач. 2. Законика о кривичном поступку, ослобођен је од оптужбе да је извршио кривично дело неуплаћивање пореза по одбитку из чл. 229а ст. 1. Кривичног законика.

Жалбеним наводима да од стране окривљеног није извршена уплата доприноса за здравствено осигурање, по основу незапослености и на зараде, не доводи се у питање правилност и законитост побијане пресуде имајући у виду да доприноси не спадају у кривично дело, јер објект кривичног дела представља неуплаћивање пореза по одбитку. Наиме, кривичним делом неуплаћивање пореза по одбитку из чл. 229 а ст. 1 КЗ не пружа се заштита свим порезима, како је то било прописано у чл. 173. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, већ само оним који се обрачунавају и уплаћују приликом исплате одређених прихода од стране исплатилаца тих прихода. Дакле, реч је о порезима које је дужан да обрачуна и уплати исплатилац прихода, односно порески платац.

(Пресуда Основног суда у Нишу 11К.бр.5471/10 од 06.07.2011. године, пресуда Апелационог суда у Нишу 5Кж1.бр.354/12 од 13.09.2012. године)

Приредила: Милица Алексић,
судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу

ПРИТВОР

(Чл. 141. и чл. 142. ст. 1. тач. 1. Кривичног законика)

Првостепени суд нема законску могућност да продужи притвор према окривљеном по основу који је већ отклоњен ранијим решењем о одређивању притвора, а није било нових околности или су постојале, али нису биле познате првостепеном суду у време одлучивања.

Из образложења:

Првостепеним решењем против окривљеног В.Н. продужен је притвор одређен решењем истражног судије Вишег суда у Нишу, за још месец дана, по основу из чл. 142. ст. 1. тач. 1, 2. и 5. Законика о кривичном поступку и по побијаном решењу притвор према окривљеном може трајати најдуже до 12.09.2012. године.

Апелациони суд налази да се основано жалбом браниоца указује да првостепени суд није имао законских могућности да притвор према окривљеном продужи по основу из чл. 142. ст. 1. тач. 1. ЗКП јер по том основу према окривљеном притвор није ни одређен. Ово из разлога што је истражни судија решењем Вишег суда у Нишу 1Ки. бр.71/12 од 13.06.2012. године према окривљеном одредио притвор по основу из чл. 142. ст. 1. тач. 2. и 5. ЗКП, истовремено налазећи да нема разлога за одређивање притвора према окривљеном и по основу из чл. 142. ст. 1. тач. 1. ЗКП који основ је такође предложен захтевом за спровођење истраге јавног тужиоца Кт.бр.143/12 од 13.06.2012. године. Из списка предмета произилази да је истражни судија доношењем решења о одређивању притвора одлучио о предлогу јавног тужиоца за одређивање притвора по основу из чл. 142. ст. 1. тач. 1. ЗКП тако што је одбио предлог за одређивање притвора по том законском основу.

У таквој ситуацији, а имајући у виду да се у међувремену нису појавиле нове околности које нису постојале или су постојале, али нису биле познате суду у време доношења решења о одређивању притвора, кривично веће првостепеног суда није било овлашћено да према окривљеном продужи притвор и по основу из чл. 142. ст. 1. тач. 1. ЗКП.

(Решење Вишег суда у Нишу 3Кв.бр.375/12 од 11.07.2012. године, решења Апелационог суда у Нишу 5Кж.2.бр.1024/12 од 24.08.2012. године)

Приредила: Милица Алексић,
судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу

РАДЊА ИЗВРШЕЊА КОД КРИВИЧНОГ ДЕЛА КРИЈУМЧАРЕЊЕ
(Чл. 230. ст. 1. КЗ)

Кривично дело кријумчарење из чл. 230. ст. 1. Кривичног законика може се извршити једном радњом, уколико се утврди постојање умишљаја код окривљеног, односно његово хтење да се бави радњама, које представљају обележје овог кривичног дела.

Из образложења:

Разлози првостепеног суда, дати у образложењу пресуде, који се односе на одлуку суда о непостојању кривичног дела које се окривљеној ставља на терет су нејасни. Ово зато што првостепени суд тумачењем одредбе чл. 230. ст. 1. Кривичног законика закључује да је радња извршења овог кривичног дела одређена трајним глаголским обликом, због чега налази да се ово кривично дело не може извршити једном радњом, већ предузимањем две или више радњи извршења.

Међутим, првостепени суд при томе није имао у виду садржину одредбе чл. 112. Кривичног законика, којом је у ст. 30. прописано да, када је радња кривичног дела одређена трајним глаголом, сматра се да је дело учињено ако је радња извршена једном или више пута. Из наведеног произилази да су нејасни разлози првостепеног суда који закључује да се кривично дело које се окривљеном ставља на терет не може извршити једном радњом, с обзиром да је радња извршења одређена трајним глаголским обликом „ко се бави преношењем“, јер то не произилази из наведене законске одредбе.

Поред тога, у оваквој ситуацији постојања једне радње, било је потребно утврдити на основу одговарајућих доказа да ли је код окривљене постојао умишљај, односно њено хтење да се бави радњама, које представљају обележје овог кривичног дела.

Како се стога основано жалбом Основног јавног тужиоца у Нишу побија првостепена пресуда због учињене битне повреде одредаба кривичног поступка, због чега је првостепена пресуда морала бити укинута.

(Пресуда Основног суда у Нишу 15К.бр.4440/10 од 10.11.2010.године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж.1.бр.1059/11 од 27.02.2012. године)

Приредила: судија Горана Митић

**ОПОЈНА ДРОГА МАРИХУАНА КАО ПРЕДМЕТ
ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА**

(Чл. 246. ст. 1. КЗ)

За постојање кривичног дела неовлашћено стављање у промет опојних дрога из чл. 246. ст. 1. КЗ потребно је да марихуана као опојна дрога и предмет радње извршења дела буде на листи решења Министарства здравља Републике Србије.

Из образложења:

Вештак биолог В.П. у свом налазу је најпре нашао да се у конкретном случају ради о индијској конопљи која у свом саставу има највећи проценат ТХЦ супстанце, али је затим објаснио да постоје три врсте конопља, канабис сатива (индустријска), канабис рубментарис (такозвана самоникла врста) и канабис индика (индијска конопља) и да у последњој врсти има највећег процента ТХЦ супстанце. Имајући у виду да је решењем о одређивању опојних дрога и психотопних супстанци (Службени гласник РС број 2405) под редним бројем 45 утврђено да је опојна дрога канабис (индијска конопља), односно канабис биљка, смола канабиса, екстрати и тинктуре канабиса, а да се жалбама браниоца основано указује да у конкретном случају није поуздано утврђено о којој врсти ове биљке се ради, то су разлози побијане пресуде о постојању кривичног дела и кривици оптужених како у погледу производње и поседовања тако и у делу продаје или омогућавања уживања опојне дроге неразумљиви и у неким битним елементима противуречни.

Вештаци НКТ Центар Одсека у Нишу су извршили вештачење одузетих количина биљке од оптуженог М.М. а утврдили су присуство ТХЦ, али нису могли да утврде о којој врсти биљке се ради, као нити проценат присуства ТХЦ у погледу различитих количина одузете биљне материје.

У жалби браниоца оптуженог М.Ђ., као и у жалби браниоца оптуженог М.М. указује се да није утврђен степен психотропних супстанци у одузетим узорцима, што у конкретном случају може бити од важности за оцену врсте биљке конопље, али је у конкретном случају одлучујуће за постојање кривичног дела и битно и неопходно да се вештачењем утврди да ли се уопште ради о опојној дроги која је решењем Министарства здравља Републике Србије одређена као опојна дрога. Ради се о битном еле-

менту, односно предмету извршења дела, без чијег утврђења није могуће одлучити о постојању кривичног дела.

Противуречност утврђења првостепеног суда да се ради о индијској конопљи произилази из допуне вештака биолошке струке са записника од 25.11.2010. године у коме он и наводи да је на основу вештачења извршеног од стране КТЦ утврђено да се ради о индијској конопљи. У вештачењу НКТ Одсека полиције у Нишу број 720/10 и то како у налазу тако и у мишљењу говори се о марихуани и о канабису (конопљи) која је на листи опојних дрога, али се нигде не даје оцена да ли се ради о индијској конопљи. Такође, из истог вештачења произилази да је утврђено постојање присуства психоактивне супстанце, али без утврђивања количине те супстанце. У оптужници јавног тужиоца се говори о опојној дроги индијској конопљи, а у побијаној пресуди се такође говори о конопљи канабис индика (индијска конопља). Имајући у виду изнето мишљење вештака Биолошког факултета, наводи жалбе у погледу утврђивања да ли је одузета материја опојна дрога се потврђују као основани.

(Пресуда Вишег суда у Нишу 4К.бр. 398/10 од 13.01.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу 4Кж.1. 1569/11 од 20.10.2011. године)

Приредио: судија Братислав Крстић

МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ (Чл. 246. ст. 7. КЗ)

Када је у изреци пресуде наведено да се на основу чл. 246. ст. 7. Кривичног законика од окривљеног одузима опојна дрога која ће се по правноснажности пресуде уништити, а без навођења и која врста опојне дроге се одузима и у којој количини, изрека пресуде је неразумљива у делу одлуке о изреченој мери безбедности.

Из образложења:

У изреци првостепене пресуде наведено је да је на основу чл. 246. ст. 7. КЗ од окривљеног одузета предметна опојна дрога која ће се по правноснажности пресуде уништити комисијским путем. Поступањем на овакав начин, првостепени суд је изреку пресуде учинио неразумљивом у де-

лу изречене мере безбедности, јер се из исте не може утврдити која врста опојне дроге се одузима од окривљеног нити о којој количини опојне дроге се ради, па је пресуда захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП.

(Решење Апелационог суда 5Кж.1.бр.667/12 од 18.09.2012. године, пресуда Основног суда у Врању К.бр.3863/10 од 24.03.2011. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

ОПОЈНА ДРОГА – МАРИХУАНА

(Чл. 246. ст. 2. КЗ)

Ради утврђивања да ли биљна материја конопља представља предмет извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246. ст. 2. Кривичног законика, неопходно је вештачењем утврдити њену врсту и варијетет у смислу Закона о психоактивним контролисаним супстанцама.

Из образложења:

Првостепени суд је извео као доказ налаз и мишљење Национално криминалистичко – техничког центра МУП-а РС од 02.09.2010. године из којег је утврдио да испитивани узорак биљне материје која је одузета од окривљеног представља материју под називом „марихуана“, која је састављена од сасушених делова биљке *cannabis* (коноплје) која садржи психоактивну супстанцу ТНС (тетрахидроканабинол).

Прихватањем налаза и мишљења Национално криминалистичко – техничког центра првостепени суд је утврдио да биљна маса која је одузета од окривљеног представља супстанцу која се налази на листи опојних дрога и психотропних супстанци наведених у Службеном гласнику РС број 24/2005 од 15.03.2005. године. Међутим, суд је био дужан да утврди да ли се у конкретном случају ради о врсти и варијетету конопље из групе тетраидроканабинола у смислу Закона о психоактивним контролисаним супстанцама, односно да ли се ради о индијској или некој другој, што је у овој кривично правној ствари изостало. Ово је од нарочитог значаја по-

себно имајући у виду да из потврде о привремено одузетим предметима Пу. бр. 2774/10 од 27.08.2010. године произилази да су од окривљеног одузети листови биљне материје зелене боје „домаћа конопља“, а да се листи опојних дрога налази биљка канабис – индијска конопља која може бити злоупотребљена, а у том делу налаз и мишљење вештака не садржи све потребне податке.

(Решење Апелационог суда 5Кж.1.бр.667/12 од 18.09.2012. године, пресуда Основног суда у Врању К.бр.3863/10 од 24.03.2011. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

НЕОВЛАШЋЕНА ПРОИЗВОДЊА И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ОПОЈНИХ ДРОГА

(Члан 246. ст. 1. Кривичног законика)

Оптужени неовлашћено посредује у куповини опојне дроге када од сведока узме новац и купи хероин, који су након тога намерава-ли да заједно конзумирају.

Из образложења:

„И по налажењу Апелационог суда, оптужени МС је критичном приликом неовлашћено посредовао у куповини опојне дроге хероин, тако што га је сведок ЈВ питала да ли може да позове ЗК и од њега купи хероин, јер њој неће да прода зато што му од раније дугује новац, истог позвао, узео новац од ЈВ и купио „квотер“ хероина, који су хтели заједно да употребе“.

(Пресуда Вишег суда у Прокупљу К.бр.56/10 и Пресуда Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.66/11)

Приредила: судија Драгана Живадиновић

БИТНА ОБЕЛЕЖЈА КРИВИЧНОГ ДЕЛА

(Члан 256. ст. 1. КЗ)

Да би постојало кривично дело производња и стављање у промет штетних производа из чл. 256. ст. 1. КЗ потребно је да штетан производ дође у посед неког другог лица.

Из образложења:

И остали разлози пресуде су нејасни, а то се пре свега односи на правну оцену утврђеног чињеничног стања и утврђивање постојања свих битних елемената кривичног дела производња и стављање у промет штетних производа из чл. 256. ст. 1. КЗ за које је оптужени оглашен кривим. Наиме, првостепени суд у изреци пресуде наводи да је оптужени кривично дело извршио на тај начин што је ставио у промет штетну животну намирницу, али не наводи како је утврдио да је таква намирница дошла у посед неког лица, где је и код кога спорна количина шећера пронађена, а што представља битно обележје наведеног кривичног дела када се окривљени терети да је штетан производ ставио у промет.

(Пресуда Основног суда у Лесковцу 2К.бр. 336/11 од 03.02.2012. године, пресуда Апелационог суда у Нишу 4Кж.1.бр. 1825/12 од 25.06.2012. године).

Приредила: Ана Јовичић, судијски помоћник

ПУСТОШЕЊЕ ШУМА

(Чл. 274. ст. 1. Кривичног законика)

Пре утврђивања кривице окривљеног за кривично дело пустошење шума из чл. 274. ст. 1. Кривичног законика, потребно је утврдити да ли сеча стабала представља пустошење шума, у смислу чл. 40. Закона о шумама.

Из образложења:

„Битна повреда одредаба кривичног поступка састоји се у томе што је првостепени суд пре одлуке о кривици окривљеног ЗЛ био у обавези да утврди да ли сеча 254 стабала храста и цера, укупне дрвне масе

40,66 м³, представља пустошење шуме у смислу чл. 40. Закона о шумама („Службени Гласник РС“ број 46/91 од 31.07.1991. године), који је важио у време које се окривљеном ставља на терет.

Ово стога што је чланом 40. ст. 2. Закона о шумама прописано да се под пустошењем шума сматра свака радња извршена противно прописима којом се слаби плодност (приносна снага) шумског земљишта и тиме доводи у опасност или онемогућава трајност шумске производње или гајење шума на том земљишту или угрожава опстанак шума и њихове општекорисне функције (сеча већег обима која се приближава крчењу шума, пребирна сеча прејаког интензитета, подбељивање стабала, свака радња која може проузроковати закоровљавање, спирање и одношење земљишта водом или ветром и др.).

Имајући у виду овако одређен појам „пустошења шума“, првостепени суд је требало да одреди вештачење од стране вештака шумарске струке на околности да ли се извршена сеча у конкретном случају може сматрати пустошењем шуме, односно да ли су наступиле штетне последице на шуму или земљиште на којој су се посечена стабла налазила“.

(Пресуда Основног суда у Прокупљу 5К.бр.1161/10 и Решење Апелационог суда у Нишу 10Кж.1.бр.3037/12)

Приредио: Зоран Ђурђевић, судијски сарадник

ГРАЂЕВИНСКА ДИЗАЛИЦА КАО ОПШТЕОПАСНО СРЕДСТВО

(Члан 278. ст. 1. Кривичног законика)

Од момента стављања у погон грађевинска дизалица представља општеопасно средство, у смислу чл. 278. ст. 1. Кривичног законика.

Из образложења:

„Правилно је првостепени суд утврдио да је грађевинска дизалица коју је окривљени монтирао општеопасно средство, у смислу чл. 278. ст. 1. Кривичног законика, јер је њеном употребом изазвана конкретна, стварна и непосредна опасност за живот и тело оштећеног, обзиром да се критичном приликом налазио у маневарском и манипулативном простору

дизалице, прихватајући колица са бетоном које она подиже. И по налажењу Апелационог суда, околност да окривљени дизалицу није правилно монтирао, јер цев дизалице није довољно причврстио за објекат, нити је угрожено подручје оградио, односно означио видним ознакама у смислу чл. 195. Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова, због чега је оштећеном сада покојном било омогућено присуство у близини дизалице, довела је до даљег развоја опасности од дизалице и повређивања оштећеног. Имајући у виду да из исказа оштећеног и налаза вештака медицинске струке произилази да су повреде оштећеног последица укључивања мотора дизалице, односно њеног стављања у погон, жалбени наводи браниоца да дизалица у конкретном случају није општеопасно средство, одбијени су као неосновани“.

(Пресуда Основног суда у Нишу 2К.бр.4234/2010 и Пресуда Апелационог суда у Нишу 6Кж.1.бр.3491/11)

Приредио: Зоран Ђурђевић, судијски сарадник

КРИВИЧНО ДЕЛО РАЧУНАРСКА САБОТАЖА ИЗ ЧЛ. 299. КЗ

Радња извршења кривичног дела рачунарска саботажа из чл. 299. КЗ подразумева активно поступање учиниоца, па се ово кривично дело не може извршити нечињењем окривљеног.

Из образложења:

Према радњама извршења кривичног дела рачунарска саботажа из чл. 299. КЗ, које су алтернативно одређене, произилази да исте подразумевају активно поступање учиниоца, при чему је заштитни објект овог кривичног дела сам електронски програм, односно електронски податак, чијим манипулисањем се исти чини неупотребљивим, а у намери да се знатно омете поступак електронске обраде података. Првостепени суд је правилно утврдио да чињенични опис дела из оптужбе не садржи такве радње, јер се окривљеном ставља на терет да није инсталирао апликативни софтвер фонда РЗЗО, па је правилан закључак првостепеног суда да нечињење окривљеног у смислу неувођења у употребу новог програма, већ ко-

ришћење старог, не представља ниједну радњу извршења кривичног дела које му се ставља на терет, с обзиром да његовим радњама није био угрожен ниједан програм, нити електронски податак.

Стога је правилна одлука првостепеног суда који је нашао да у радњама окривљеног нема обележја наведеног кривичног дела, као ни неког другог кривичног дела, па је он ослобођен од оптужбе, применом чл. 355. тач. 1. ЗКП, о чему је првостепени суд дао довољне и јасне разлоге, које у свему прихвата и овај суд.

(Пресуда Основног суда у Врању К.бр.3881/10 од 07.03.2011. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 7Кж.1.бр.2607/11 од 31.08.2012. године)

Приредила: судија Горана Митић

**КРИВИЧНО ДЕЛО ПОМОЋ УЧИНИОЦУ
ПОСЛЕ ИЗВРШЕНОГ КРИВИЧНОГ ДЕЛА
(Члан 333. КЗ)**

Околност да је учинилац претходног кривичног дела непознат не чини разлоге који привремено онемогућавају кривично гоњење за учињено кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из члана 333. Кривичног законика.

Из образложења:

Побијајући првостепену пресуду због повреде кривичног закона из чл. 367. ст. 1. тач. 2. ЗКП, неосновано се у жалби наводи да окривљени није могао да буде оглашен кривим за кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из чл. 333. ст. 2. у вези ст. 1. КЗ, јер није утврђено ко је и како извршио кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл. 297. ст. 4. у вези чл. 289. ст. 3. у вези ст. 1. КЗ, а у вези ког кривичног дела је окривљени предузео радњу помоћи да учинилац истог не буде откривен.

Наиме, кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из чл. 333. КЗ мора по природи ствари да претпоставља да је из-

вршено неко друго кривично дело у односу на које се предузима радња извршења овог кривичног дела, што у одређеном смислу чини акцесорним природу кривичног дела помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из чл. 333. КЗ. Али, за постојање овог кривичног дела није потребно да извршилац претходног кривичног дела буде познат, како се то неосновано наводи у жалби, ко је и како извршио то претходно кривично дело. Ово нарочито у случају када се радња извршења, за које је окривљени оглашен кривим, односи на делатности којима се крије учинилац претходног кривичног дела тако да му се помаже да не буде откривен, што и условљава да се одговорност, кривица и кажњивост учиниоца ових кривичних дела посебно расправљају, што га и чини самосталним кривичним делом. Имајући у виду напред изнето, неосновани су жалбени наводи да су у питању околности које привремено спречавају гоњење услед којих се мора одбацити оптужница.

(Пресуда Основног суда у Лесковцу 6К.бр.102/2010 од 21.01.2011. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 13Кж1.бр.1297/11 од 23.07.2012. године)

Приредио: Владимир Станојевић,
судијски помоћник Апелационог суда у Нишу

БИТНА ОБЕЛЕЖЈА КРИВИЧНОГ ДЕЛА

(Члан 344. КЗ)

Код кривичног дела обмањивање купаца из чл. 344. КЗ потребно је да постоји намера обмањивања купаца, што подразумева постојање директног умишљаја

Из образложења:

Такође, нејасни су и разлози првостепене пресуде који се односе на кривично дело обмањивање купаца из чл. 244. КЗ, па се основано жалбом браниоца окривљеног указује да је у изреци побијане пресуде наведено да су у промет стављени производи са ознаком у коју су унети подаци који не одговарају садржини и квалитету производа, али да ни у једном делу образложења пресуде није наведено о којој се садржини и квалитету

стварно ради, да ли погрешна ознака произвођача представља податак који не одговара садржини или квалитету неког производа, шта је тачно унето у декларацију и у чему се састоји одступање означених података од стварних. Поред тога, не постоје ни одлучне чињенице на основу којих је првостепени суд утврдио да је предметни производ – шећер у кристалу стављен у промет, као ни да је окривљени радњу извршења кривичног дела које му се ставља на терет извршио у намери обмањивања купаца. Наиме, битна повреда кривичног поступка се огледа и у томе што побијана пресуда нема разлога у односу на облик виности са којим је поступао окривљени јер се у првостепеној пресуди наводи да је окривљени П.С. извршио кривично дело са умишљајем, односно да је био свестан свог дела и хтео његово извршење, али првостепени суд у побијаној пресуди није изнео разлоге због којих сматра да је окривљени извршио кривично дело са намером обмањивања купаца, односно да је дело извршио са директним умишљајем, те се мора утврдити и субјективни однос окривљеног према кривичном делу које му се ставља на терет оптужним актом.

(Пресуда Основног суда у Лесковцу 2К.бр. 336/11 од 03.02.2012. године, пресуда Апелационог суда у Нишу 4Кж.1.бр. 1825/12 од 25.06.2012. године).

Приредила: Ана Јовичић, судијски помоћник

НЕДОЗВОЉЕНО ДРЖАЊЕ ОРУЖЈА И ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА

(Чл. 348. КЗ)

Вештачење муниције је неопходно да би се утврдило да ли се ради о муницији у смислу Закона о оружју и муницији, као и да ли се ради о кривичном делу или о прекршају.

Из образложења:

Пресуда је донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП, јер не садржи разлоге о неким одлучним чињеницама док су дати разлози нејасни.

Предмет кривичног дела недозвољено држање оружја и експлозивних материја из чл. 348. ст. 1. Кривичног законика су ватрено оружје, муниција и експлозивне материје, а муницијом се сматрају меци, зрна, патрони, чауре са упаљачем, сачма и друго. Ово кривично дело је са бланкетном диспозицијом тако да се његово постојање мора утврђивати с обзиром на прописе о производњи и промету ватреног оружја и муниције. Из побијане пресуде не може се утврдити, да ли се ради о правој муницији која је исправна и која може бити испалена, у ком смислу пресуда уопште не садржи разлоге.

Побијајући правилност утврђеног чињеничног стања, основано се жалбама бранилаца окривљеног указује да је првостепени суд пропустио да преко вештака одговарајуће струке утврди да ли се ради о правој, исправној и функционалној муницији, имајући у виду да из потврде о привремено одузетим предметима коју је оптужени потписао произилази да је од њега одузето осам комада метака за малокалибарску пушку калибра 5,56 мм, 22 1р, а вештачење муниције није обављено.

Поред тога, чињенично стање утврђено у побијаној пресуди доводи у питање и тиме што Закон о оружју и муницији предвиђа кажњавање за прекршај у прекршајном поступку за набављање муниције за оружје са неолученим цевима, без одобрења надлежног органа, а у поступку није утврђено да ли се ради о муницији за оружје са неолученим цевима или са олученим цевима.

(Решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр. 2783/10 од 05.08.2010. године, пресуда Општинског суда у Нишу К.бр.2205/09 од 27.10.2009. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

КРИВИЧНО ДЕЛО НАВОЂЕЊЕ НА ОВЕРАВАЊЕ НЕИСТИНИТОГ САДРЖАЈА ИЗ ЧЛ. 358. СТ. 1. КЗ

Власник предузећа за пружање књиговодствених услуга није одговорно лице у предузећу за које су поднете пореске пријаве.

Из образложења:

Првостепени суд није извршио оцену доказа, на основу које је требало утврдити да ли је постојао умишљај код окривљеног, јер је за ово кривично дело неопходно постојање умишљаја, који обухвата свест да се надлежни орган довођењем у заблуду наводи на оверавање нечег неистинитог. При томе треба имати у виду да је окривљени поступао као власник предузећа за пружање књиговодствених услуга, дакле, не као одговорно лице у предузећу, за које су поднете пореске пријаве, због чега је неопходно поуздано утврдити да ли је он знао да су у пореској пријави неистинити подаци, да ли је имао интереса и каквог да у исту унесе неистините податке, на који начин је навео директора да исту потпише и овери, те да ли је могуће да је дошло до грешке и какве, како је тврдио окривљени у својој одбрани.

(Пресуда Основног суда у Врању К.бр.2364/10 од 16.06.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу 2Кж.1.бр.199/11 од 01.12.2011. године)

Приредила: судија Горана Митић

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО

ПРИМЕНА

(Чл. 5. ст. 2. КЗ и чл. 351. ст. 2. ЗКП)

Првостепени суд није везан правном квалификацијом дела у оптужби. Наиме радње оптужених које су правно квалификоване у оптужници као радње кривичног дела тешка крађа из чл. 166 ст. 1 КЗ РС, а потом применом чл. 5 ст. 2 КЗ квалификоване као кривично дело тешка крађа из чл. 204 ст. 1 КЗ а које се односи на крађу путничког моторног возила правилно је првостепени суд применом чл. 351 ст. 2 КЗ правно квалификовао као радње кривичног дела крађа возила из чл. 174 КЗ РС.

Из образложења:

Дела која су оптуженима А.А. и Б.Б. стављена на терету подигнутом оптужницом Општинског јавног тужиоца у Нишу Кт. бр. 1670/03 од 08.05.2003. г. са правном квалификацијом и то у односу на окривљеног А.А. да је у питању кривично дело тешка крађа из чл. 204. ст. 1. тач. 1. КЗ, а у односу на окривљеног Б.Б. да је у питању кривично дело тешка крађа из чл. 204. ст. 1. тач. 1. и 2. КЗ, и у односу на која је према окривљенима одбијена оптужба, правилно је првостепени суд квалификовао као кривична дела крађа возила из чл. 174. КЗ РС и правилно закључио да је у односу на иста наступила апсолутна застарелост кривичног гоњења.

Наиме, кривично дело крађа возила из чл. 174. КЗ РС гласи ко противправно одузме туђе моторно возило у намери да га употреби за вожњу или у намери да његовим присвајањем прибави себи или другом противправну имовинску корист, казниће се за то дело од три до пет година.

Очигледно је да су у тако прописаном кривичном делу крађа возила садржана истовремено и обележја кривичног дела крађа. Међутим, с обзиром на предмет противправног присвајања у кривичном делу крађа возила из чл. 174. КЗ РС, јасно је да се ради о посебном кривичном делу крађе, код кога је

предмет крађе моторно возило. Код таквог стања ствари, противправно присвајање возила у намери да се његовим присвајањем прибави себи или другом имовинска корист, не може да представља кривично дело крађа, а самим тим ни кривично дело тешка крађа, без обзира на специфичан начин извршења, већ једино кривично дело крађа возила из чл. 174. КЗ РС, које се у конкретној ситуацији примењује по посебном предмету извршења, које кривично дело је било прописано као јединствено кривично дело без теже квалификације, а које је егзистирало након извршења кривичних дела за које се терете окривљени А.А. и Б.Б. у подигнутој оптужници.

Имајући у виду напред наведено, с обзиром да суд није везан правном квалификацијом дела у оптужби, и по оцени Апелационог суда правилно је првостепени суд закључио да треба применити блажи кривични закон сходно чл. 5. ст. 2. КЗ у односу на правну квалификацију дела и правилно извршио оцену радњи ових окривљених, које су им стављене на терет оптужбом, као кривична дела крађа возила из чл. 174. КЗ РС.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 2Кж. 1 2418/11 од 03.04.2012. г. и пресуда Основног суда у Нишу 7К. бр. 4837/10 од 30.05.2011. године.)

Приредила: судија Љиљана Миљковић

ПРОТИВТУЖБА

(Члан 53. ст. 2. Законика о кривичном поступку)

Окривљени може до завршетка главног претреса и после протека рока из става 1. чл. 53. ЗКП да подигне тужбу против тужиоца који му је увреду нанео истом приликом.

Из образложења:

Побијана пресуда је донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. и става 2. ЗКП, јер не садржи разлоге о одлучним чињеницама, а дати разлози су неразумљиви или противуречни и из разлога што првостепени суд није применио одредбу члана 53. став 2. ЗКП, а то је имало утицаја на законито и правилно доношење пресуде. Окривљени је на записнику о главном претресу предлагао преко свог браниоца, да се здружи противтужба коју је поднео пре завршетка главног

претреса, како је то и предвиђено Закоником о кривичном поступку, али је првостепени суд одбио овај предлог и на тај начин начинио битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368. став 2. у вези члана 53. став 2. Законика о кривичном поступку. Ове околности су наведене у жалби окривљеног и уз жалбу је приложена противтужба од 05.09.2011. године заведена у Основном суду у Врању под бр К. 1084/11 из које се утврђује да је поднета пре завршеног главног претреса у предмету К. бр. 634/11 против окривљене, приватне тужиље О.Ј, због кривичног дела увреде из чл. 170. ст. 1. КЗ, извршеног 04.04.2011. године.

Одредбом чл. 53. ст. 2. ЗКП, је предвиђено да уколико је подигнута приватна тужба због кривичног дела увреде, да окривљени може до завршетка главног претреса и после протека рока из става 1. овога члана подићи тужбу против тужиоца који му је увреду нанео истом приликом. Овај члан предвиђа могућност подношења противтужбе окривљеног по протеку рока од три месеца од сазнања за кривично дело и учиниоца, а суд је обавезан да у таквој ситуацији донесе једну пресуду. И поред предлога окривљеног да се здружи противтужба првостепени суд то није учинио, већ је одбио предлог наводећи као разлог да је предмет при крају.

Оваква одлука првостепеног суда је неразумљива и супротна цитираној одредби чл. 53 ЗКП, на тај начин је повређено и право окривљеног на одбрану због чега се утврђено чињенично стање и примена закона не могу прихватити.

(Пресуда Основног суда у Врању К. бр. 634/11 од 06.09.2011. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 4Кж. 1. бр. 1457/12).

Приредио: судија Братислав Крстић

ОЦЕНА ДОКАЗА (Чл. 18. ст. 3. ЗКП)

Ако се одлучне чињенице не могу утврдити са обележјем извесности, то се исте тумаче у корист окривљеног, применом чл. 18. ст. 3. ЗКП.

Из образложења:

На основу наведеног закључује се да током поступка није могло бити поуздано утврђено ко је издао спорну саобраћајну дозволу, те да ли су печати и потписи на њој аутентични. Из тог разлога није било могуће утврдити да ли је окривљени набавио спорну саобраћајну дозволу ради употребе и исту употребио, како му се ставља на терет, знајући да употреба лажну јавну исправу до дана када му је иста одузета. С обзиром на достављено обавештење Полицијске управе у Београду, као и обављено вештачење, могуће је да се ради о лажној јавној исправи, односно саобраћајној дозволи са којом је окривљени управљао возилом до 07.01.2006. године када му је иста одузета. Из списка предмета произилази да је возило било регистровано до 27.09.2002. године, те да након тога регистрација није продужавана. Међутим, с обзиром да се одлучне чињенице у овом предмету, односно да ли је окривљени набавио ради употребе лажну јавну исправу и исту употребио као праву, не могу утврдити са степеном извесности, из горе наведених разлога, то се исте тумаче у корист окривљеног, применом одредбе чл. 18. ст. 3. Законика о кривичном поступку.

(Пресуда Основног суда у Прокупљу 4К. бр. 747/10 од 20.06.2011. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 7Кж. I. бр. 2377/11 од 13.08.2012. године)

Приредила: судија Горана Митић

**НАДЛЕЖНОСТ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДУЗИМАЊУ
ПРЕДМЕТА НАКОН ПРАВНОСНАЖНОСТИ ПРЕСУДЕ
(Чл. 24. ст. 6. ЗКП)**

За доношење решења о одузимању моторног возила након правноснажности пресуде надлежно је веће (из члана 24. ст. 6. ЗКП) суда који је донео првостепену пресуду, а не председник већа суда који је судио у првом степену.

Из образложења:

Решењем Вишег суда у Врању К. бр. 64/11 од 08. 6. 2012. године од Х.Р. одузето је путничко моторно возило марке „Сеат ибиза“ број шасије

VSSZZZ6LZ7R102583, регистарских ознака АМ 590 ЕА које је привремено одузето потврдом о привремено одузетим предметима Царинарнице Приштина - Царински пункт Кончуљ 05/1 Д-бр. 431/2010 од 21.05.2010. године.

Апелациони суд је у седници већа размотрио све списе предмета, са побијаним решењем те је испитујући побијано решење по службеној дужности у смислу чл. 401. ст. 5. ЗКП, нашао:

Првостепено решење је поводом изјављене жалбе нужно укинути по службеној дужности.

Наиме, првостепено решење је донео председник већа суда који је поступао у првом степену иако одредба члана 24. ст. 6. ЗКП, предвиђа да првостепени судови у већу састављеном од тројице судија доносе одлуке у првом степену ван главног претреса. Из тога произилази да је првостепено решење донео стварно ненадлежан орган о чему Апелациони суд као другостепени пази по службеној дужности због чега је укидање ожалбеног решења било нужно.

(Решење Вишег суда у Врању К. бр. 64/11 од 08. 6. 2012 и Решење Апелационог суда у Нишу 12. Кж. 2. 912/12 од 22. 8. 2012. године)

Приредио: судија Зоран Поповић

ЗАСТУПАЊЕ ОКРИВЉЕНОГ

(Чл. 68. ст. 3. ЗКП)

Није учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 2. ЗКП тиме што је првостепени суд као сведока саслушао супруга окривљене кога је окривљена овластила да је заступа у кривичном поступку.

Из образложења:

Из списка предмета произилази да је окривљена суду доставила овлашћење оверено пред судом којим је свог супруга овластила да је заступа-брани у кривичном поступку, као и да је првостепени суд то лице саслушао у својству сведока.

Неосновано бранилац окривљене жалбом побија првостепену пресуду због битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 2. ЗКП указивањем да лице коме је овлашћење дато није могло бити саслушано као сведок јер је по оцени Апелационог суда овлашћење којим је окривљена свог супруга овластила да је заступа у овом кривичном поступку без икаквог утицаја на законито и правилно доношење пресуде. Ово из разлога што такво овлашћење није произвело никакве последице у поступку јер окривљена од стране лица коме је овлашћење дала није заступана нити је исто у складу са чл. 68. ст. 3. ЗКП могло бити дато лицу које није адвокат. Стога није било никаквих сметњи да лице коме је окривљена дала овлашћење за заступање буде саслушан као сведок.

(Пресуда Основног суда у Пироту ЗК. бр. 1502/10 од 28.10.2011. године и пресуда Апелационог суда у Нишу I Кж. 1. бр. 4279/11 од 20.09.2012. год.)

Приредиле: судија Вера Милошевић и
Виши судијски помоћник Ивана Лазовић

РАДЊА ПРЕПОЗНАВАЊА СЕ МОРА ОБАВИТИ ПРЕМА ОДРЕДБИ ЧЛ. 104. ЗКП

Препознавање окривљеног од стране сведока не може се обавити само на основу фотографије показане у полицији, већ на основу личне идентификације.

Из образложења:

Основано се жалбом браниоца окривљеног првостепена пресуда побија због битне повреде одредаба кривичног поступка, наводима да је првостепени суд пресуду засновао на препознавању окривљеног од стране сведока З.М., које је извршено у Полицијској управи у Врању са показане фотографије, а не на основу личне идентификације, чиме је, по налажењу Апелационог суда, учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 2. Законика о кривичном поступку, јер је првостепени суд неправилно применио одредбу чл. 104. ЗКП, што је било од утицаја на законито и правилно доношење пресуде.

Наиме, побијаном пресудом окривљени је оглашен кривим због кривичног дела крађа из чл. 203. ст. 1. Кривичног законика, при чему је првостепени суд прихватио исказ сведока З.М., који је дао у истражном поступку, налазећи да је исти сагласан са исказом оштећеног Б.П. и осталим изведеним доказима. Такође, првостепени суд прихвата наводе овог сведока да је препознао окривљеног у полицији, јер се са њим договарао око трампе возила, што је утицало на његово јаче опажање.

Међутим, из списка предмета се утврђује да је сведок З.М. саслушан у истражном поступку и да је на записнику од 03.04.2009. године изјавио да је у полицији, када је дао изјаву, препознао окривљеног на фотографији, која му је показана од стране инспектора. При томе нема никаквих података да је вршено препознавање у полицији на начин који је прописан одредбом чл. 104. ЗКП, односно да је овом сведоку окривљени показан заједно са другим лицима, те да се он након тога изјаснио да ли може да га препозна. Такође, у истражном поступку није вршено препознавање окривљеног од стране овог сведока, а на главном претресу исти није саслушан, већ је прочитан његов исказ из истражног поступка.

(Пресуда Основног суда у Врању К. бр. 952/10 од 06.09.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу 2Кж. 1. бр. 388/11 од 12.12.2011. године)

Приредила: судија Горана Митић

УРАЧУНЉИВОСТ ИЗВРШИОЦА КРИВИЧНОГ ДЕЛА (Чл. 130. ЗКП)

Урачунљивост извршиоца кривичног дела не може се утврђивати на основу исказа сведока, већ је потребно обавити неуропсихијатријско вештачење.

Из образложења:

Првостепени суд је окривљену ослободио од оптужбе да је извршила кривично дело скидање и повреда службеног печата и знака из чл. 327. ст. 1. Кривичног законика, налазећи да се на основу изведених доказа није могло несумњиво утврдити и доказати да је окривљена извршила кривично

дело које јој се ставља на терет. При томе, у образложењу пресуде првостепени суд наводи да је прихватио исказ сведока, комшинице окривљене, која је изнела своје мишљење да је окривљена неурачунљива и психички болесна, с обзиром да је једном приликом по зими и хладноћи изашла у двориште у комбинезону и чешљала се, због чега је она закључила да окривљена има психичке проблеме. Првостепени суд услед тога закључује да није могуће утврдити да ли је окривљена урачунљива, те да ли је кривично дело можда извршено у стању неурачунљивости, због чега би било неопходно ову чињеницу утврдити на основу психијатријског вештачења.

Овакви разлози првостепеног суда су нејасни и противречни, јер се чињеница да ли је извршилац кривичног дела урачунљив или није не може утврђивати на основу исказа сведока, нити се неурачунљивост може претпостављати, већ обратно, претпоставља се да је извршилац кривичног дела урачунљив, док се та чињеница не доведе у сумњу и не докаже супротно. У случају сумње потребно је обавити неуропсихијатријско вештачење, што у конкретном случају није учињено, с обзиром да окривљена није била присутна током главног претреса, већ јој се судило у одсуству. Стога се овакви разлози првостепеног суда за сада не могу прихватити, јер се на заснивају на поуздано утврђеним чињеницама, већ на претпоставкама о неурачунљивости окривљене.

(Пресуда Основног суда у Нишу 6К. бр. 1581/10 од 24.02.2012. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж. 1. бр. 1273/12 од 02.04.2012. године)

Приредила: судија Горана Митић

ЈЕМСТВО

(Чл. 138. ст. 1. и 2. ЗКП.)

Приликом одлучивања да ли ће прихватити понуђено јемство, суд по слободној оцени одређује да ли висина понуђеног јемства представља довољну гаранцију да окривљени неће побећи.

Из образложења:

Правилно је првостепени суд поступио када је прихватио, понуђено јемство у износу од 40. 000, 00 еура, ценећи тежину кривичног дела, личне и породичне прилике окривљеног као и имовно стање лица које даје јемство. Наиме, околности да се ради о младом човеку који се школује у Немачкој, и кога издржавају родитељи, обећање да се неће крити и без одобрења напуштати место боравишта, да је породица оптуженог доставила потврду банке из које произилази да је новац за полагање јемства обезбедио отац оптуженог, и по оцени овог суда представљају довољну гаранцију да оптужени уколико би се нашао на слободи неће побећи или се крити, како то правилно закључује првостепени суд. Такође, је приликом одлучивања, првостепени суд ценио да ли и даље стоје разлози из чл. 142. ст. 1 тач. 1. Законика о кривичном поступку, због којих је притвор одређен и продужаван, јер се јемство састоји у полагању одређене суме новца коју одређује суд по слободној оцени, као залог да окривљени коме је притвор одређен само из разлога предвиђених чл. 142. ст. 1. тач. 1. Законика о кривичном поступку, да се неће крити или побећи и да неће без дозволе суда напуштати место боравишта, односно само у случају ако постоје околности које указују на опасност од бекства. С тога, како је у конкретном случају првостепени суд нашао да и даље стоји разлози предвиђени чл. 142. ст. 1. тач. 1. Законика о кривичном поступку, због којих је притвор одређен и продужаван, јер и даље постоје околности које указују на опасност од бекства, правилно је првостепени суд меру обезбеђења присуства окривљеног у кривичном поступку заменио блажом мером, прихваћеним понуђеним јемством. Наиме приликом одлучивања коју ће од мера обезбеђења присуства окривљеног за несметано вођење кривичног поступка применити, суд је дужан да води рачуна о томе да се тежа мера неће применити ако се иста сврха може постићи применом блаже мере како је то предвиђено чл. 133. ст. 2. Законика о кривичном поступку.

Следствено томе, неосновано се жалбом Вишег јавног тужиоца указује, да првостепени суд није ценио тежину кривичног дела, затим да се ради о страном држављанину, као и да су нејасни разлози којима се оправдава износ прихваћеног јемства. Наиме приликом оцене да ли ће прихватити понуђено јемство, суд треба да цени да ли висина понуђеног јемства представља довољну гаранцију да оптужени неће побећи, имајући

у виду при том све околности битне за ту оцену, из чега произилази да суд по слободној оцени одређује да ли утврђени новчани износ представља довољну гаранцију да оптужени неће побећи.

(Решење Вишег суда у Врању 2К. бр. 69/12 од 03.09.2012. године, решење Апелационог суда у Нишу 7Кжс. 2. бр. 1098/12 од 12.09.2012. године)

Приредила: Слађана Лендра,
судијски помоћник Апелационог суда у Нишу

РАЗУМАН РОК ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРИТВОРА

(Члан 141. Законика о кривичном поступку и
члан 31. Устава Републике Србије)

Неажурно поступање првостепеног суда у преиспитивању даљег трајања притвора и разуман рок за поступање као одлучне чињенице за утврђивање законских основа даљег трајања притвора.

Из образложења:

Основано се истиче у жалби браниоца оптуженог да притвор према оптуженом В.Н. предуго траје, скоро годину дана и да нема сврхе да оптужени и даље остане у притвору. Наиме, чл. 141. ст. 1. ЗКП предвиђено је да се притвор може одредити само одлуком суда, ако је притварање неопходно ради вођења кривичног поступка и ако се иста сврха не може постићи другом мером, а ст. 2. истог члана да је дужност свих органа који учествују у кривичном поступку и органа који им пружају правну помоћ да трајање притвора сведу на најкраће неопходно време и да поступају са нарочитом хитношћу ако се окривљени налази у притвору, док је одредбом чл. 31. Устава Републике Србије предвиђено да трајање притвора суд своди на најкраће неопходно време, имајући у виду разлоге притвора, да притвор одређен одлуком првостепеног суда траје у истрази најдуже три месеца, а виши суд га може, у складу са законом, продужити на још три месеца, ако до истека овог времена не буде подигнута оптужница, окривљени се пушта на слободу, а после подизања оптужнице трајање притвора суд своди на најкраће неопходно време, у

складу са законом, а притвореник се пушта да се брани са слободе чим престану разлози због којих је притвор одређен.

Имајући у виду стање ствари у списима предмета, с обзиром на то да је захтев за спровођење истраге и одређивање притвора против оптуженог В. Н. поднет дана 23.11.2011. године и да је истрага трајала скоро шест месеци, да је притвор више пута продужаван из разлога предвиђених чл. 142. ст. 1. тач. 5. ЗКП, као и да је Виши јавни тужилац у Прокупљу подигао оптужницу против оптуженог дана 21.05.2012. године против које није изјављен приговор, а главни претрес ни после три месеца није заказан, по налажењу Апелационог суда, дужини поступка пресудно је допринело поступање првостепеног суда који није показао потребну ажурност у вођењу поступка, с обзиром да је у надлежности првостепених судова да осигурају да притвор окривљеног лица не прелази разумни рок и да пажљиво испитају оправданост продужења притвора с обзиром на околности сваког конкретног случаја. Апелациони суд у Нишу налази да извођење доказа саслушањем сведока и обављања медицинских вештачења није изискивало максимално трајање истражног поступка, као и притвора и да првостепени суд није благовремено и у разумном року предузимао све процесне радње у смислу одговарајућих одредби ЗКП, а у вези са спровођењем истраге и поступка по подизању оптужнице и заказивања главног претреса у смислу чл. 283. ст. 1. и 2. ЗКП, имајући у виду и начин и околности извршења дела која се оптуженом ставља на терет подигнутом оптужницом и то да је дело извршио у тешком пијаном стању након присуства прослави славе код оштећеног управљајући путничким аутомобилом, представљају чињенице које указују да су околности кривичног дела које је првостепени суд узео за посебно тешке због којих је притвор одређен и продужаван изгубиле на свом значају и снази и да више не оправдавају примену одредбе чл. 142. ст. 1. тач. 5. ЗКП за даље трајање и продужење притвора.

Такође, Апелациони суд оцењује да првостепено решење не садржи разлоге о релевантним околностима које би оправдавале даље трајање мере притвора и које би указивале на ажурно вођење поступка и хитно поступање првостепеног суда, с обзиром да се ради о најтежој мери за обезбеђење присуства оптуженог, то је из свих наведених разлога, а на основу чл. 141, 146. и 269. ЗКП и у смислу чл. 31. Устава Републике Српске,

публике Србије, укинуо притвор према оптуженом и одредио да се исти пусти на слободу.

(Решење Вишег суда у Прокупљу Кв. бр. 89/12 од 17.08.2012. године и решење Апелационог суда у Нишу 4Кж. 2. бр. 1049/12. од 30.08.2012. године)

Приредио: судија Братислав Крстић

ЗАМЕНА ПРИТВОРА МЕРОМ ЗАБРАНЕ НАПУШТАЊА МЕСТА БОРАВИШТА

(Чл. 141. у вези чл. 136. ЗКП)

Уколико из списка предмета произилазе околности које не оправдавају даље трајање притвора, притвор се према окривљеном може укинути и заменити мером забране напуштања места боравишта, као блажом мером за обезбеђење његовог присуства.

Из образложења:

Истовремено, Апелациони суд налази да у конкретном случају постоје околности које указују да би окривљени могао побећи и сакрити се, како то налази првостепени суд, из разлога што из списка предмета произилази да је окривљени напустио место догађаја, да је за њим била расписана потерница, по којој је лишен слободе на Власинском језеру дана 21.07.2012. године, што значи да је био недоступан државним органима дуже од три месеца након критичног догађаја, а скоро два месеца од доношења решења о спровођењу истраге.

Међутим, наведене околности су такве да самим тим не оправдавају даље трајање притвора, те да задржавање окривљеног у притвору није неопходно, ради вођења кривичног поступка, имајући у виду да је окривљени пре лишења слободе дана 04.06.2012. године упутио молбу Вишем суду у Лесковцу, наводећи да не бежи, нити се крије и да обећава да неће напустити Лесковац и да ће се свакодневно јављати полицији. Поред тога, окривљени је у својој одбрани објаснио да је након критичног догађаја напустио место боравишта заједно са својом породицом, због претњи убиством, из страха за своју безбедност и безбедност своје породице, што се може сматрати оправданим разло-

гом, с обзиром да се Г.И. оптужником Вишег јавног тужиоца у Лесковцу Кт. бр. 43/12 од 22.06.2012. године, ставља на терет да је критичном приликом покушао да га лиши живота, испаливши укупно 14 пројектила из аутоматске пушке у његовом правцу, због чега се он сматрао оштећеним све до доношења решења о проширењу истраге.

Из наведених разлога, по налажењу Апелационог суда, изрицањем мере забране напуштања боравишта, као блаже мере за обезбеђење присуства, може се обезбедити присуство окривљеног у даљем току кривичног поступка, уз упозорење да ће се против њега поново одредити притвор ако прекрши изречене забране.

(Решење Вишег суда у Лесковцу Кв. бр. 153/12 од 30.07.2012. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж. 2. бр. 964/12 од 06.08.2012. године)

Приредила: судија Горана Митић

ПОСЕБНО ТЕШКЕ ОКОЛНОСТИ ДЕЛО И ПРИТВОР (чл. 142. ст. 1. тач. 5. ЗКП.)

Чињеница да је окривљени помогао неидентификованим лицима у извршењу кривичног дела убиство у покушају, на тај начин што је ставио возило на располагање за превоз и бекство, да су та лица испалила 27 хитаца из ватреног оружја, у близини центра града, где се налазе стамбени и угоститељски објекти и где је велика фреквенција људи, не представља посебно тешке околности дела.

Из образложења:

Истражни судија Вишег суда у Нишу ставио је предлог да се против окривљеног В. Н. продужи притвор по основу из чл. 142. ст. 1. тач. 2. и 5. ЗКП. У предлогу је наведено да истражни поступак још увек није окончан, јер нису саслушани сведоци које је предложио Виши јавни тужилац у предлогу и то држављани Републике Бугарске, чије се саслушање има обавити замолним путем, и окривљеног који се брани ћутањем. У предлогу се наводи да стоји разлог за притвор из чл. 142. ст. 1. тач. 5. ЗКП, јер је за кривично дело које се окривљеном ставља на терет предви-

ђена казна преко десет година, а тешке околности кривичног дела су у томе што је возило за које постоји основана сумња да га је окривљени набавио, ставио на располагање за превоз и бекство, приликом извршења дела убиство у покушају од стране више лица која нису идентификована, употребом ватреног аутоматског оружја, на месту испред ноћног клуба где је велика френквенција људи.

Апелациони суд налази да законски основ за продужење притвора из чл. 142. ст. 1. тач. 5. ЗКП треба отклонити, јер из захтева за спровођење истраге произилази, да се окривљеном ставља на терет да је помогао неидентификованим лицима у извршењу кривичног дела убиство у покушају, да су та лица испалила 27 хитаца из ватреног оружја, у близини центра града, где се налазе стамбени и угоститељски објекти и где је велика френквенција људи, и да те околности представљају посебно тешке околности. Међутим, по оцени Апелационог суда, а имајући у виду стање у списима предмета, овакав закључак првостепеног суда се за сада не може прихватити, ово из разлога што из напред наведеног не произилази да је окривљени знао да ће дело бити извршено под околностима која га чине посебно тешким. Стога се ова околност не може ценити као посебно тешка околност, која оправдава даље задржавање окривљеног по овом основу.

(Предлог Истражног судије Вишег суда у Нишу 1Ки. бр. 71/12 од 05.09.2012. године, решење Апелационог суда у Нишу 7Кр. бр. 39/12 од 10.09.2012. године)

Приредила: Слађана Лендра,
судијски помоћник Апелационог суда у Нишу

ПРИМЕНА ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 171. СТ. 3. ЗКП

Позив приватном тужиоцу да у смислу одредбе члана 171. ст. 3. ЗКП поднесак исправи или допуни, врши се у форми наредбе против које није дозвољена жалба, а не у форми решења.

Из образложења:

Решењем Основног суда у Прокупљу 2К. 518/11 од 30.05.2011. године, наложено је приватном тужиоцу С.З. да сходно чл. 438. ЗКП уреди

приватну тужбу и дозвољено му је право жалбе на наведено решење у року од 8 дана.

Жалба С.З. против решења Основног суда у Прокупљу 2К 518/11 од 30.05.2011. године је недозвољена.

Наиме, одредбом чл. 171. ст. 3. и 4. ЗКП је предвиђено да ће суд подносиоца поднеска који је неразумљив и не садржи све што је потребно да би се по њему могло поступати, позвати да поднесак исправи односно допуни, а уколико то не учини суд ће поднесак одбацити и поучиће га на последице пропуштања. Према томе садржина решења првостепеног суда упућује да се у ствари ради о наредби суда којом се странци налаже да у одређеном року исправи или допуни поднесак како би се по њему могло поступити. У конкретном случају првостепени суд је налог странци погрешно дао у форми решења при чему му је дао и право на жалбу. Пошто се у конкретном случају не ради о решењу којим се одлучује о току поступка већ о наредби којом се странци нешто налаже, жалба против такве наредбе није дозвољена због чега је жалба приватног тужиоца С.З. одбачена као недозвољена.

(Решење Основног суда у Прокупљу 2К. 518/11 од 30. 5. 2011. године и Решење Апелационог суда у Нишу 12 Кж2. бр. 1224/11 од 05.12.2011. године.

Приредио: судија Зоран Поповић

ТРАЈНО КРИВИЧНО ДЕЛО И ЗАСТАРЕЛОСТ

(Члан 219. став 1. КЗ)

За утврђивање наступања застарелости кривичног гоњења код трајних кривичних дела рок се рачуна од момента престанка дејства последица дела.

Из образложења:

Одлучујући о заједничкој жалби пуномоћника тужиље Д.Р. и жалби тужиље В.М. Апелациони суд налази да се основано жалбом указује да

решење не садржи јасне и довољне разлоге за утврђивање застарелости кривичног гоњења у односу на кривична дела из оптужног предлога.

Суд је оцену протекла рока застарелости ценио у односу на сва дела од дана када је радња извршења ових дела учињена. Жалбом се основано указује да су нека од наведених дела трајног карактера утолико што њихова последица и даље траје. И по налажењу Апелационог суда кривично дело противправно усељење из чл. 219. ст. 1. КЗ, припада групи трајних кривичних дела, јер је то дело чија последица траје дуже или краће време, при томе то трајање последице улази у појам кривичног дела, па се због тога сматра да ово кривично дело траје све док траје последица, у конкретном случају последица противправног усељења. Такође, за ова кривична дела застарелост гоњења почиње да тече од момента престанка дејства те последице, а не само од тренутка извршења радње кривичног дела.

Из побијаног решења не произилазе разлози за оцену трајања последице код наведених кривичних дела и самим тим жалбом су доведени у сумњу закључци о наступању застарелости кривичног гоњења, тако да се и примена кривичног закона за сада не може да прихвати као правилна.

(Решење Основног суда у Нишу 15К. бр. 2533/11 од 14.10.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу 4Кж. 2. бр. 145/12 од 10.08.2012. године).

Приредио: судија Братислав Крстић

ЗАХТЕВ ОШТЕЋЕНОГ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ПРЕМА МАЛОЛЕТНОМ ЛИЦУ

(Чл. 221. тач. 6. У вези чл. 59. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица)

За подношење захтева у циљу покретања припремног поступка према малолетном лицу овлашћен је оштећени, у конкретном случају Републичко јавно правобранилаштво Републике Србије, а не Министарство унутрашњих послова, Полицијска станица, јер се ради о покретној ствари у јавној својини.

Из образложења:

Чланом 221. тач. 6. Законика о кривичном поступку је прописано ко се у складу са законом може сматрати оштећеним, то је Апелациони суд нашао да је захтев за покретање припремног поступка Министарства унутрашњих послова Републике Србије Полицијска управа Врање Полицијска станица Босилеград од 20.04.2012. године према малолетном Ј.Н. због кривичног дела ситна крађа из чл. 210. ст. 1. Кривичног законика, недозвољен јер је исти поднет од неовлашћеног лица и да га треба одбацити.

Наиме, чл. 221. тач. 6. Законика о кривичном поступку прописано је да је оштећени лице чије је какво лично или имовинско право кривичним делом повређено или оштећено. Како је чл. 2 Закона о јавном правобранилаштву ("Службени гласник РС", бр. 43/91) прописано да послове правне заштите имовинских права и интереса Републике Србије обавља Републичко јавно правобранилаштво, док је чл. 7. истог закона прописано да Републичко јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Републике Србије, њених органа и организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Републике или из других средстава Републике. Такође, чл. 3. Закона о јавној својини (Службени гласник РС", бр. 72/2011) је прописано да су у јавној својини природна богатства, добра од општег интереса и добра у општој употреби за која је законом утврђено да су у јавној својини, ствари које користе органи и организације Републике Србије, аутомномне покрајине и јединице локалне самоуправе, установе, јавне агенције и друге организације чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и друге ствари које су у складу са законом у јавној својини, а чл. 12. ст. 1. је прописано да ствари у јавној својини које користе органи и организације Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе чине непокретне и покретне ствари и друга имовинска права која служе за остваривање њихових права и дужности. С обзиром да је у конкретном случају у питању одузети мобилни телефон и да је извршењем кривичног дела оштећена Република Србија, а не Министарство унутрашњих послова Републике Србије, односно Полицијска управа Врање Полицијске станице Босилеград, то Апелациони суд налази да је захтев недозвољен и да га треба одбацити, а да је на основу свега изнетог обавештење Вишег јавног тужиоца у Врању Ктм. бр. 19/12 од

03.04.2012. године требало да се достави Републичком јавном правобраниоцу као заступнику оштећеног.

(Решење Апелационог суда у Нишу 4Крм. 1. бр. 1/12 од 24.05.2012. године).

Приредили: судија Братислав Крстић и
судијски помоћник Марија Димитријевић

ОДЛАГАЊЕ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА

(Чл. 236. ст. 6. и 7. ЗКП)

За примену института одлагања кривичног гоњења није од значаја да штета остварена кривичним делом није у потпуности надокнађена оштећеном.

Из образложења:

Основано се жалбом браниоца окривљеног М.У. указује да побијано решење не садржи јасне разлоге из којих првостепени суд није, по предлогу одбране дао сагласност Основном јавном тужиоцу за примену института одлагања кривичног гоњења у смислу чл. 236. ст. 6. и 7. ЗКП и да је тиме решење неразумљиво због чега је захваћено битном повредом одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП, тако да се и примена кривичног закона не може да прихвати као правилна.

Одбијање давања одобрења за примену одлагања института кривичног гоњења, првостепени суд образлаже чињеницом да оштећеном није надокнађена штета, већ да је бранилац само понудио надокнаду штете, са чиме се сагласио тужилац. Део одлуке о несагласности оштећеног у погледу исплате одређеног износа новца у хуманитарне сврхе првостепени суд образлаже истим разлозима наводећи да оштећеном није у потпуности надокнађена штета, односно да штета није ни у једном делу исплаћена и да стога нису испуњени законски услови за одлагање кривичног гоњења.

Одредбом чл. 236. ЗКП одређен је поступак одлагања кривичног гоњења и то у ставу 1. за кривично дело за које је прописана новчана ка-

зна или казна затвора до три године када је предвиђена могућност да надлежни јавни тужилац одложи кривично гоњење када сагласност суда није потребна, јер изричито у наведеном члану није прописана. Уколико се ради о извршењу обавезе из ст. 1. тач. 2. и 3. наведеног члана потребна је сагласност оштећеног, а уколико он не да своју сагласност применом тач. 5. истог члана, јавни тужилац може да затражи од већа суда да својим решењем одобри извршење тих обавеза.

У ставу 2. истог члана је прописано да по одобрењу већа суда из чл. 24. ст. 6. ЗКП јавни тужилац може да одложи кривично гоњење и за кривична дела за која је предвиђена казна затвора преко три године, а до пет година. У ставу 6. истог члана дата је могућност да јавни тужилац уз сагласност суда пред којим се води главни претрес до завршетка главног претреса за кривична дела за која је предвиђена новчана казна или казна затвора до три године, као и за кривична дела за које је предвиђена казна затвора преко три године, а до казне затвора до пет година уз одобрење већа суда из чл. 24. ст. 6. овог законика да одустане од кривичног гоњења. За наведене ситуације у ставу 3. чл. 236. ЗКП прописано је да је осумњичени дужан да прихваћену обавезу изврши у року који не може да буде дужи од 6 месеци. У ставу 5. истог члана дато је право јавном тужиоцу да оцени да ли је оштећеном у потпуности надокнађена причињена штета и да у случају несагласности оштећеног са применом одредбе ст. 1. тач. 2. и 3. ЗКП који се односе на уплате одређеног новчаног износа у корист хуманитарне организације или обављање друштвено корисног рада или тужилац нађе да је несагласност оштећеног очигледно из неоправданог разлога, а да је извршење обавеза целисходно, да затражи одлуку већа суда из чл. 24. ст. 6. ЗКП.

Без анализирања недостатака у систематизацији и временској одређености обавеза и права јавног тужиоца и осумњиченог односно окривљеног, Апелациони суд налази да је одредбом чл. 236. ЗКП предвиђено да јавни тужилац може уз сагласност суда пред којим се води поступак до завршетка главног претреса да одустане од кривичног гоњења за кривична дела за која је предвиђена казна затвора преко три године, а до пет година, као у конкретном случају где је оптужним актом јавног тужиоца окривљеном стављено на терет извршење кривичног дела тешка телесна повреда из чл. 121. ст. 1. КЗ за које је законом прописана казна затвора од шест месеци до пет година. Из садржине овог члана с обзиром да се ради

о остварењу начела опортунитета и могућности оцене целисходности вођења кривичног поступка, које је у искључивој надлежности јавног тужиоца, произилази да је најпре потребно да овлашћени јавни тужилац на основу чл. 236. ст. 7. ЗКП затражи од суда одобрење за примену одредбе чл. 236. ЗКП, а да затим по добијању одобрења за примену одређене мере из чл. 236. ст. 1. ЗКП, окривљеном буде одређен рок за извршење у смислу става 3. члана 236. ЗКП.

Уколико се ради о одобрењу мере из става 1. тач. 2. и 3. овог члана, а оштећени се не сагласи са исплатом одређеног новчаног износа у хуманитарне сврхе или са обавезом обављања друштвено корисног, односно хуманитарног рада, тада је у смислу става 5. чл. 236. ЗКП, јавни тужилац надлежан да тражи одлуку већа суда да својим решењем одобри извршење ових обавеза.

Жалбом браниоца се основано указује да у побијаном решењу није јасно на који начин, коме и који износ је осумњичени дужан да уплати и у ком року и да на тај начин изврши обавезу из чл. 236. ст. 1. тач. 1. и 2. ЗКП. По налажењу Апелационог суда извршење ове обавезе подразумева, аналогном применом одредбе чл. 236. ст. 9. ЗКП и дужност јавног тужиоца да утврди начин отклањања штетне последице настале у извршењу кривичног дела или висину накнаде почињене штете оштећеном или другу врсту мере на начин предвиђен овим чланом и да од суда тражи одобрење за примену одустанка од кривичног гоњења, да би се окривљени обавезао на извршење ове мере у одређеном року, а да затим тужилац изврши оцену да ли је мера извршена односно штета надокнађена у потпуности у датом року и да тек тада примени начело опортунитета. Не упуштајући се у оцену правилности и целисходности одредбе чл. 236. у делу сагласности оштећеног у погледу уплате одређеног износа у хуманитарне сврхе или обављања одређеног друштвено корисног рада, а не у делу договорене висине новчаног износа или начину отклањања штетне последице, без обзира што овим чланом није ускраћено право оштећеног да након примене одлагања кривичног гоњења у парници остварује сва права из накнаде штете и отклањања штетне последице настале извршењем кривичног дела, првостепени суд није дао прихватљиве разлоге из којих се није сагласио са предлогом браниоца да одобри јавном тужиоцу одлагање кривичног гоњења, а дати разлози о неуплаћи-

вању одређене штете су неразумљиви јер основано жалба указује да окривљеном и није дата могућност да изврши предложене мере.

(Решење Основног суда у Пироту 2Кв. бр. 116/12 од 16. маја 2012. године и решење Апелационог суда у Нишу 4Кж. 2. бр. 789/12 од 13.08.2012. године).

Приредио: судија Братислав Крстић

**ВРСТА ОДЛУКЕ И ПРАВА ОШТЕЋЕНОГ
У СЛУЧАЈУ ОДУСТАНКА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА ОД КРИВИЧНОГ
ГОЊЕЊА ПРЕ И НАКОН ПОЧЕТКА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
(Чл. 236. ст. 8. ЗКП)**

У случају одустанка јавног тужиоца од кривичног гоњења, након почетка главног претреса, суд ће донети пресуду којом се оптужба одбија у смислу одредбе чл. 236. ст. 8. ЗКП у складу са ст. 6. и 7. истог члана, која искључује могућност оштећеног да продужи кривично гоњење у смислу чл. 62. ЗКП, а које право му је загарантовано у случају одустанка јавног тужиоца од оптужног акта пре него што је главни претрес почео, у смислу чл. 290. ЗКП.

Из образложења:

Решењем Основног суда у Пироту 3 К. бр. 353/10 (2008) од 23.04.2012. године на основу чл. 290. ЗКП у вези чл. 236 ст. 6 и 8 ЗКП обустављен је кривични поступак против окр. К.Д. из Пирота због крив. дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл. 297. ст. 3. у вези чл. 289. ст. 3. у вези ст. 1. КЗ због одустанка Основног јавног тужиоца у Пироту од оптужног предлога Кт. бр. 670/07 од 03.11.2008. године, који је прецизиран 05.10.2011. године.

Апелациони суд је одржао седницу већа на којој је по разматрању списка предмета и жалбених навода нашао да је побијано решење засновано на битној повреди одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 2. ЗКП на коју се основано указује у жалби ОЈТ у Пироту, а која је од значаја за правилно и законито доношење одлуке у овој кривичној ствари.

Наиме, првостепени суд је побијано решење донео применом одредбе чл. 290. ст. 1. ЗКП која предвиђа обуставу кривичног поступка уколико јавни тужилац *пре почетка* главног претреса одустане од оптужног акта и исту везује за аналогну примену одредбе чл. 236. ст. 6. ЗКП која опредељује одустанак јавног тужиоца од кривичног гоњења *до завршетка* главног претреса. Наведена примена процесних одредби је нејасна и противречна сама себи, посебно ако се има у виду да је у чл. 236. ст. 8. ЗКП одређено да у случају из ст. 6 цитиране одредбе суд доноси пресуду којом се оптужба одбија.

Такође, првостепени суд предвиђа да је у конкретном предмету главни претрес отпочео, да исти представља јединствену целину и да одлука поводом одустанка јавног тужиоца од кривичног гоњења може бити донета само у форми пресуде, што је у конкретном случају изричито предвиђено одредбом чл. 236. ст. 8. ЗКП. Осим тога, у цитираној одредби је искључена могућност примене одредбе чл. 62. ЗКП, односно оштећени нема права да настави кривично гоњење које му је загарантовано у случају обуставе кривичног поступка, у смислу чл. 290. ЗКП. Дакле, изнетим поступањем суда нису повређене само процесне одредбе о врсти судске одлуке, поводом одустанка јавног тужиоца, зависно од стадијума поступка, већ се пре свега доношењем решења о обустави кривичног поступка даје дискреционо право оштећеном да настави кривично гоњење која могућност је искључена у смислу доношења одбијајуће пресуде применом чл. 354. тач. 1. ЗКП у вези чл. 236. ст. 8. у вези ст. 6 истог законика.

(Решење Основног суда у Пироту 3 К. бр. 353/10 (2008) од 23.04.2012. године и решење Апелационог суда у Нишу 11 Кж. 2 бр. 896/12 од 27.08.2012. године)

Приредила: Ивана Милошевић, судијски помоћник

ПРИВАТНИ ТУЖИЛАЦ КАО СВЕДОК

(Чл. 317. ст. 3. Законика о кривичном поступку)

Уколико је донето решење да се приватни тужилац испита као сведок, његово испитивање се врши без удаљавања осталих приватних тужилаца.

Из образложења:

„Заједничком жалбом окривљене и браниоца, првостепена пресуда се побија због битне повреде одредаба кривичног поступка и указује да је првостепени суд био у обавези да приватне тужиоце НМ и СМ испита понаособ, у смислу чл. 102. ст. 1. у вези чл. 96. ст. 2. Законика о кривичном поступку, а пошто то није учинио, побијана пресуда је донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 2. Законика о кривичном поступку.

Испитујући ове жалбене наводе, Апелациони суд је нашао да су они неосновани. Ово стога што се приликом испитивања приватних тужилаца као сведока не примењују одредбе чл. 102. ст. 1. Законика о кривичном поступку, већ чл. 317. ст. 3. Законика о кривичном поступку, којим је прописано да ако оштећени као тужилац или приватни тужилац треба да буду испитани као сведоци, неће се уклонити из заседања, те је правилна одлука првостепеног суда да сваког приватног тужиоца испита као сведока без удаљавања другог приватног тужиоца из суднице. Такође, у конкретном случају реч је о супружницима које је окривљена истовремено вређала, због чега су поднели једну приватну тужбу преко заједничког пуномоћника, те је логично и очекивано да њихови искази о критичном догађају буду идентични“.

(Пресуда Основног суда у Врању К. бр. 1188/10 и Пресуда Апелационог суда у Нишу 2Кж. 1. бр. 374/11)

Приредио: Зоран Ђурђевић, судијски сарадник

**ПРЕСУДА КОЈОМ СЕ ОПТУЖЕНИ ОСЛОБАЂА ОД ОПТУЖБЕ
ЈЕР ДЕЛО ЗА КОЈЕ ЈЕ ОПТУЖЕН НИЈЕ КРИВИЧНО ДЕЛО**

(Члан 355. тачка 1. Законика о кривичном поступку)

Ако чињенични опис у оптужби Јавног тужиоца не садржи све објективне елементе кривичног дела које се оптуженом ставља на терет оптужбом, суд ће донети пресуду из члана 355. тачка 1. Законика о кривичном поступку.

Из образложења:

Из изложеног неоспорно произилази, а како то правилно утврђује и првостепени суд, да чињенични опис оптужнице не садржи опис наведених кривичних дела, па у таквој ситуацији када оптужни акт нема објективне елементе кривичних дела, једино је и било могуће донети ослобађајућу пресуду, сходно одредби чл. 355. тач. 1. ЗКП, с обзиром да описана дела у оптужници са недостајућим напред наведеним објективним обележјима кривичног дела напад на службено лице у вршењу службене дужности из чл. 323. ст. 4. у вези ст. 1. и 3. КЗ и кривичног дела изазивање опште опасности из чл. 278. ст. 3. у вези ст. 1. КЗ, нису кривична дела.

Како опис делатности оптужених, онако како је то утврђено и изнето у првостепеној пресуди, не садржи сва битна обележја ниједног од кривичних дела која су оптуженима стављена на терет, имајући у виду начело легалитета у кривичном праву, који налаже прецизно законско регулисање свих елемената кривичног дела, па самим тим и прецизан чињенични опис у оптужници, произилази, супротно наводима из жалбе, да се из постојања једног елемента кривичног дела не може аналогијом извучити закључак о постојању других елемената бића одређеног кривичног дела. Даље, неосновани су жалбени наводи да је првостепени суд требало сам да прилагоди чињенични опис изнет у оптужници са чињеничним стањем утврђеним на главном претресу, јер би по налажењу овог суда, на тај начин првостепени суд управо прекорачио предмет оптужбе садржане у поднетој оптужници, супротно одредби чл. 351. ст. 1. ЗКП.

Такође, неосновани су жалбени наводи да је првостепени суд требало да преквалификује наведена дела из оптужнице, јер иако суд у смислу одредбе чл. 351. ст. 2. ЗКП није везан за предлоге тужиоца у погледу правне оцене дела, правилан је закључак првостепеног суда да чињенични опис делатности оптужених онако како је наведен у оптужници не садржи ни обележја других кривичних дела предвиђених законом код којих се гоњење предузима по службеној дужности, те самим тим није ни било услова да би првостепени суд извршио преквалификацију изнетог чињеничног описа.

Дакле, с обзиром да чињенични опис делатности оптужених у оптужном акту не садржи битна обележја предметних кривичних дела, па како Јавни тужилац до закључења главног претреса није изменио оптуж-

жницу на начин којим би обухватио сва обележја наведених кривичних дела, правилном применом одредбе чл. 355. тач. 1. ЗКП, оптужене ослободио оптужбе за наведена дела јер по закону нису кривична дела.

(Пресуда Основног суда у Врању К. бр. 3548/10 од 29.12.2010. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 13Кж1. бр. 1352/11 од 09.04.2012. године)

Приредио: Владимир Станојевић,
судијски помоћник Апелационог суда у Нишу

БИТНА ПОВРЕДА

(Чл. 368. ст. 1. тач. 1. ЗКП)

Учињена је битна повреда одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 1. ЗКП када о предлогу јавног тужиоца за изрицање мере напуштања стана или места боравишта из чл. 136. ЗКП одлучи веће из чл. 24. ст. 6. ЗКП.

Из образложења:

Испитујући побијано решење у смислу чл. 401. ст. 5. ЗКП Апелациони суд је нашао да је исто захваћено битном повредом одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 1. ЗКП.

Наиме, одредбом чл. 136. ст. 6. ЗКП прописано је да меру забране напуштања стана или места боравишта у току истраге одређује и укида истражни судија, а после подигнуте оптужнице председник већа или веће, док је ст. 8 истог члана прописано да о жалби на решење којим се наведена мера одређује, продужава или укида одлучује веће из чл. 24. ст. 6. ЗКП.

Како је о предлогу јавног тужиоца да се према окривљеном изрекне мера забране напуштања места боравишта одлучило веће из чл. 24. ст. 6. ЗКП побијано решење је донето од стране функционално ненадлежног органа, те је исто морало бити укинато и предмет враћен председнику већа или већу првостепеног суда на поновно одлучивање, а ово из разлога што се у конкретном случају не може применити правни принцип „ко мо-

же више може и мање“ јер је решење донето од стране органа који је у складу са чл. 136. ст. 8. ЗКП овлашћен да одлучује у другом степену.

(Решење Вишег суда у Врању 2Кв. бр. 237/12 од 13.09.2012. године и решење Апелационог суда у Нишу 1Кж. 2. бр. 1180/12 од 04.10.2012. године)

Приредиле: судија Вера Милошевић и
Виши судијски помоћник Ивана Лазовић

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

(Члан 368. став 1. тачка 11. Законик о кривичном поступку)

Сама околност да је покренут прекршајни поступак против окривљених за исте радње, не представља околност која привремено спречава кривично гоњење.

Из образложења:

Наиме, из списка предмета произилази, да је решењем Основног суда у Нишу 6К. бр. 1515/11 од 09.05.2012 године, одбачен оптужни предлог ОЈТ у Нишу 16Кт. бр. 3742/10 од 08.06.2011 године, против окривљеног З. И. из села Облацина, Општина Меровина и окривљеног М. П. из села Мрамор, Општина Ниш, који су оптужени због по једног кривичног дела насилничко понашање из чл. 344. ст. 2. у вези ст. 1. Кривичног законика, јер постоје околности које привремено спречавају кривично гоњење, јер се против окривљених у вези истог догађаја води прекршајни поступак пред Прекршајним судом у Нишу Пр. бр. 04-34920/10.

Основано се жалбом ОЈТ у Нишу указује, да је побијано решење захваћено битним повредама одредаба кривичног поступка, јер је по налажењу Апелационог суда учињена битна повреда из члана 368. став 1. тачка 11. Законика о кривичном поступку, из разлога што су дати разлози о одлучним чињеницама, које се односе на одлуку суда о одбачају оптужног предлога, нејасни.

По налажењу Апелационог суда у Нишу, овакав закључак првостепеног суда се не може прихватити, из разлога што је првостепени суд

приликом одлучивања погрешно тумачио одредбу члана 6. став 1. Законика о кривичном поступку. Наиме овом одредбом је предвиђено да нико не може да буде гоњен и кажњен за кривично дело за које је правноснажном пресудом ослобођен или осуђен или је за то дело поступак против њега правноснажно обустављен или оптужба правноснажно одбијена. Из наведеног произилази да сама околност да је покренут прекршајни поступак против окривљених за исте радње, није довољна и по оцени овог суда не представља околност која привремено спречава кривично гоњење како то погрешно закључује првостепени суд побијаним решењем. У конкретном случају, није испуњен основни услов забране начела *ne bis in idem*, чији је смисао да спречи вођење новог поступка после суђења, где је окривљени за исто дело већ правноснажно осуђен, ослобођен од оптужбе или оптужба против њега правноснажно одбијена или поступак против њега решењем правноснажно обустављен.

(Решење Основног суда у Нишу 6К-1515/11 од 09.05.2012 године и Решење Апелационог суда у Нишу 14Кж2 бр. 1087/12 од 12.09.2012 године)

Сентенцу обрадио: Горан Димитријевић,
виши судијски сарадник

ПОВРЕДА КРИВИЧНОГ ЗАКОНА

(Члан 369. ст. 1. ЗКП)

Да би постојало кривично дело самовлашће из чл. 330 КЗ потребно је да се наведе које своје право или право за које сматрају да им припада су окривљени самовласно прибавили.

Из образложења:

Наиме, чл. 330. ст. 1. Кривичног законика прописано је да ко самовласно прибавља неко своје право или право за које сматра да му припада, казниће се новчаном казном или затвором до једне године. Окривљени П.М., В.Н. и М.Н. оглашени су кривим да су кривично дело извршили тако што су по претходном договору самовласно прибавили право за које сматрају да им припада и без знања приватне тужиље обили браву на улазним вратима – вратима од гараже приватне тужиље од којих је кључ има-

ла приватна тужила, након чега су променили браву на улазним вратима и у истој кући отпочели да живе. По налажењу Апелационог суда у конкретном случају, дело за које су окривљени оглашени кривим, по закону није кривично дело. Ово из разлога што у изреци првостепене пресуде није наведено које право за које сматрају да им припада су окривљени самовласно прибавили односно које право су остварили извршењем конкретног кривичног дела, а управо постојање тог права је основно обележје кривичног дела самовлашће из чл. 330. ст. 1. КЗ. За постојање кривичног дела потребно је да се остваре сви елементи општег појма, али и сва обележја конкретног кривичног дела – у овом случају битно обележје кривичног дела описаног у изреци је постојање права за које окривљени сматрају да им припада, а с обзиром да није наведено о којем се праву ради, нема ни кривичног дела.

На основу свега изнетог, првостепени суд је правилно утврдио чињенично стање али је повредио кривични закон на штету окривљених у смислу чл. 369. ст. 1. ЗКП у питању да ли је дело за које се оптужени гони кривично дело, када је окривљене П.М., В.Н. и М.Н. огласио кривим за кривично дело самовлашће из чл. 330. ст. 1. КЗ, јер је погрешно узео да је догађај описан у изреци првостепене пресуде кривично дело.

(Пресуда Основног суда у Нишу 8К. бр. 266/11 од 23.12.2011. године, пресуда Апелационог суда у Нишу 4Кж. 1. бр. 2090/12 од 04.06.2012. године).

Приредила: Ана Јовичић, судијски помоћник

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА И ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЕЛО

(Члан 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП)

Када се ради о продуженом кривичном делу, а за поједина дела која улазе у састав продуженог дела није доказано да их је окривљени учинио, иста ће се изоставити из изреке пресуде, неће се окривљени ослободити од оптужбе за та дела, јер би то изреку пресуде чинило неразумљивом (битна повреда одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП).

Из образложења:

Наиме, по налажењу Апелационог суда, првостепени суд није оптуженог ослободио оптужбе за кривична дела извршена на штету М.Д. и С.Т., како се наводи у жалбама браниоца оптуженог и Основног јавног тужиоца у Врању, већ их је само изоставио из изреке пресуде, с обзиром на то да се овде не ради о више кривичних дела, већ о продуженом кривичном делу, у смислу чл. 61. Кривичног законика, које представља једно дело, које је извршено из више радњи, те се не може за неке радње осудити, а за друге ослободити. Првостепеном пресудом је јасно и разумљиво наведено да ниједним доказом током доказног поступка првостепени суд није утврдио чињенично стање на основу кога би се на несумњив начин могла утврдити кривица оптуженог С.Ђ. и за део оптужбе која је извршена на штету М.Д. и С.Т.

(Пресуда Основног суда у Врању К. бр. 890/11 од 26.01.2012. године, пресуда Апелационог суда у Нишу 4Кж. 1. бр. 1298/12 од 28.05.2012. године).

Приредила: Ана Јовичић, судијски помоћник

ОСНОВ ОСЛОБАЂАЊА

(Члан 355. тач. 2. ЗКП)

Када није доказано да је постојала намера окривљеног да не изврши плаћање пореза по одбитку, основ ослобађања је по основу чл. 355. тач. 2, односно да није доказано да је оптужени учинио дело за које је оптужен.

Из образложења:

1) На основу свега наведеног првостепени суд је правилно поступио када је окривљеног З.Ј. ослободио од оптужбе по основу чл. 355. тач. 2. ЗКП, јер није доказано да је окривљени извршио кривично дело за које је оптужен, а супротни наводи из жалбе о погрешном основу ослобађања су неосновани с обзиром да је првостепени суд у разлозима побијане пресуде изнео правилан закључак да у току поступка није доказано умишљај-

но поступање окривљеног и ослободио окривљеног од оптужбе јер није доказано да је извршио кривично дело за које је оптужен.

2) Неосновани су наводи Основног јавног тужиоца у Нишу да из диспозитива пресуде произилази да је оптужени Б.А. ослобођен од оптужбе јер нема доказа да је извршио кривично дело, док из разлога датих у образложењу произилази да дело по закону није кривично дело, с обзиром да недостаје битан елемент кривичног дела неуплаћивање пореза по одбитку из чл. 229а ст. 1. Кривичног законика, а то је намера да се плати порез. По налажењу Апелационог суда, управо чињеница да није доказана намера да се изврши конкретно кривично дело представља основ за ослобођење од оптужбе у смислу чл. 355. ст. 2. ЗКП.

(Пресуда Основног суда у Нишу 8К. бр. 458/10 од 01.12.2011. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 4Кж. 1. бр. 1482/12 од 14.06.2012. године).

Приредила: Ана Јовичић, судијски помоћник

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА (Чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП)

То што првостепени суд није у изреци пресуде навео докле траје притвор окривљеном приликом изрицања казне затвора и урачунавања временаведеног у притвору у изречену казну, не чини изреку првостепене пресуде неразумљивом.

Из образложења:

Изреку пресуде не чини неразумљивом то што првостепени суд у изреци није навео докле је притвор окривљеном трајао, имајући у виду време изрицања и доношења ожалбене пресуде. Наиме, ожалбена пресуда је донета дана 15.10.2010. године, окривљени је осуђен на казну затвора у трајању од два месеца а у притвору се налазио од 28.08.2010. године. Према томе јасно је да првостепени суд у изреци пресуде није могао да наведе завршни дан трајања притвора јер у тренутку објављивања пресуде, окривљени се налазио у притвору а још увек није била истекла казна затвора у трајању од два месеца на коју је окривљени осуђен већ је правилно навео

да се у изречену казну затвора има урачунати време проведено у притвору почев од 28.08.2010. године па надаље.

(Пресуда Основног суда у Врању К. 3816/10 од 15.10.2010. године и Апелационог суда у Нишу 12. Кж. 1. 1350/11 од 06.02.2012. године)

Приредио: судија Зоран Поповић

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

(Чл. 368. ст. 1. тач. 10. ЗКП)

Решење о спровођењу истраге се не може побијати због битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 10. ЗКП.

Из образложења:

Решењем Вишег суда у Пироту Кв. 18/12 од 23.02.2012. године одлучено је да се спроведе истрага против Н.С. из Ниша, због основане сумње да је извршио кривично дело насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из чл. 344а ст. 4. у вези ст. 1. Кривичног законика.

Првостепени суд је на основу чл. 243. ст. 7. ЗКП одлучио да се спроведе истрага против окривљеног Н. С. из Ниша, због кривичног дела насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из чл. 344а ст. 4. у вези ст. 1. Кривичног законика, јер из доказног материјала прикупљеног од органа унутрашњих послова уз кривичну пријаву ПУ Пирот – ПС Бела Паланка, те допуне кривичне пријаве - извештаја исте Полицијске станице и отпусне листе са епикризом Опште болнице Пирот издате на име оштећеног И. К., произилази основана сумња да је окривљени извршио кривично дело које му се захтевом за спровођење истраге ставља на терет.

Неосновано се жалбом браниоца окривљеног Н.С. побија првостепено решење због битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 10. ЗКП, наводима да је ванрасправно веће засновало решење на кривичној пријави ПУ Пирот, ПЦ Бела Паланка и извештају исте Полицијске станице, као доказима на којима се према одредбама Законика о кривичном поступку, по ставу жалбе, ниједна судска одлука, па самим

тим ни решење о спровођењу истраге не може заснивати. Ово због тога што истражни судија или веће у седници могу користити, приликом оцене да ли постоји основана сумња да је неко лице учинило кривично дело, доказни материјал који може бити користан за успешно вођење поступка у смислу одредбе чл. 226. ст. 11. ЗКП, а који су органи унутрашњих послова прикупили ван кривичног поступка, на неформалан начин и који је јавни тужилац у обавези да достави суду уз кривичну пријаву на основу чл. 242. ст. 5. ЗКП. Наиме, истражни судија је овлашћен да тек кад се истрага заврши издвоји записнике и обавештења на основу чл. 178. ст. 3. у вези ст. 1. ЗКП, осим записника из чл. 226. ст. 9. ЗКП. Како се докази на којима се судска одлука не може заснивати не могу издвајати у фази покретања кривичног поступка и како се решење о спровођењу истраге на истима може заснивати, то овај суд налази да се првостепено решење не може побити због битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 10. ЗКП, те су супротни жалбени наводи браниоца окривљеног оцењени као неосновани.

(Решење Вишег суда у Пироту Кв. бр. 18/12 од 23.02.2012. године и решење Апелационог суда у Нишу 8 Кж. 2. бр. 294/12 од 16.03.2012. године)

Припремила: Марија Петровић,
виши судијски сарадник

БИТНА ПОВРЕДА ИЗ ЧЛ. 368. СТ. 1. ТАЧ. 11. ЗКП

У кривичном поступку који се води због кривичног дела давања лажног исказа, морају се здружити списи предмета у којима је наведено дат лажан исказ.

Из образложења:

У образложењу пресуде, првостепени суд цитира одбрану оптуженог, који је признао извршење кривичног дела, као и остале изведене доказе, односно исказ оштећеног и сведока, супруге оптуженог, као и писане доказе, односно да је извршен увид у фотокопију пресуде Окружног суда у Прокупљу. Након тога, првостепени суд је утврдио чињенично ста-

ње као у изреци пресуде, које је првенствено утврђено на основу признања оптуженог. Међутим, у образложењу пресуде нема разлога о одлучним чињеницама, јер првостепени суд није здружио списе предмета у коме је вођен кривични поступак и у коме је овде оптужени дао лажан исказ, како стоји у изреци пресуде и због чега је осуђен. Стога су нејасни разлози о утврђеном чињеничном стању, јер се из образложења пресуде, као ни из списка предмета, не може проверити закључак првостепеног суда да је оптужени у наведеном кривичном предмету дао лажан исказ и када, с обзиром да му се ставља на терет да је то учинио у три наврата, најпре у истражном поступку, а затим два пута на главном претресу.

(Пресуда Основног суда у Прокупљу 5К. бр. 647/11 од 16.09.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж. 1. бр. 3240/11 од 01.03.2012. године)

Приредила: судија Горана Митић

ПРОВЕРА ОДБРАНЕ ОКРИВЉЕНОГ

(Чл. 368. ст. 2. ЗКП)

Одбрана окривљеног да му је намера била да прибави малу имовинску корист мора се проверити оценом исте у склопу свих осталих изведених доказа јер се ради о утврђивању одлучне чињенице.

Из образложења:

Имајући у виду да из изведених доказа произилази да је окривљени обио стан оштећене, у њега ушао, из регала узео новчаник из којег је одузео сав новац који је у њему нашао и то 15 евра, јер се оштећена категорички изјаснила да је то сав новац који је имала у новчанику, то су разлози првостепеног суда који се тичу чињенично правног закључивања да су у радњама окривљеног садржана сва битна обележја кривичног дела ситна крађа потпуно неразумљиви. Ово посебно стога што првостепени суд није изнео јасне разлоге о томе да ли је окривљени пре почетка извршења кривичног дела могао да зна да у кући коју обија нема новца у износу већем од 15 евра, а правилно утврђење ове чињенице било би услов за

правилаан закључак суда о одлучној чињеници која се тиче намере окривљеног за прибављањем противправне имовинске користи.

(Решење Апелационог суда у Нишу Кж. I. бр. 2713/10 од 29.03.2011. године, пресуда Основног суда у Лесковцу IК. бр. 1276/10 од 20.05.2010. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

ПОВРЕДА ЗАКОНА НА ШТЕТУ ОКРИВЉЕНОГ

(Чл. 369. тач. 4. у вези чл. 48. КЗ)

Тиме што је суд окривљеном уз условну осуду изрекао и новчану казну, као споредну, која законом није била прописана, прекорачио је овлашћења која има по закону и повредио закон на штету окривљеног.

Из образложења:

Жалбом јавног тужиоца првостепена пресуда се побија због повреде кривичног закона истицањем да је првостепени суд прекорачио овлашћења која има по закону тиме што је окривљеном изрекао и условну осуду и новчану казну. Изнети жалбени наводи оцењени су основанима.

Наиме, побијаном пресудом окривљени А.Н. оглашен је кривим што је дана 02.03.2009. године извршио кривично дело насиље у породици из чл. 194. ст. 1. КЗ.

У време извршења кривичног дела Кривичним закоником РС ("Службени гласник РС", бр. 85/2005) за ово кривично дело била је прописана новчана казна или казна затвора до једне године, па је стога суд био овлашћен да окривљеном изрекне једну од наведених кривичних санкција.

Тиме што је окривљеном за извршено кривично дело изрекао условну осуду и то казну затвора у трајању од шест месеци која се неће извршити уколико окривљени у року од две године по правноснажности пресуде не изврши ново кривично дело, као и новчану казну у износу од 30.000,00 динара, као споредну казну, која споредна казна законом који је

важио у време извршења кривичног дела није била прописана, првостепени суд је прекорачио овлашћење које има по закону и повредио кривични закон на штету окривљеног.

Поступајући на наведени начин првостепени суд је учинио повреду кривичног закона из чл. 369. ст. 1. тач. 5. ЗКП. Отклањајући наведени недостатак, Апелациони суд је преиначио првостепену пресуду у делу одлуке о кривичној санкцији у смислу чл. 391. ЗКП утврђујући да се по правилној примени закона има донети другачија одлука, то тако што је окривљеном А. Н. за кривично дело насиље у породици из чл. 194. ст. 1. КЗ, за које је побијаном пресудом оглашен кривим, изрекао само условну осуду као у изреци ове пресуде, која му је и била изречена првостепеном пресудом, при чему је отклонио и новчану казну, као споредну, на коју је окривљени осуђен првостепеном пресудом, јер изрицање споредне казне за наведено кривично дело у време извршења кривичног дела није било прописано, а не ради се о кривичном делу учињеном из користољубља, за која кривична дела је у смислу чл. 48 ст. 2 ЗКП, законом прописано поред главне казне изрицање и новчане казне као споредне.

Налазећи да се наведени недостатак може отклонити у другостепеном поступку преиначењем пресуде, Апелациони суд није уважио и жалбени предлог да се побијана пресуда укине.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу 5Кж. 1. бр. 3129/11 од 10.04.2012. године, пресуда Основног суда у Врању К. бр. 865/10 од 19.04.2011. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

**ОДГОВОР ОКРИВЉЕНОГ НА ЖАЛБУ
ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА КАО ЖАЛБУ ОКРИВЉЕНОГ
(Члан 373. Законика о кривичном поступку)**

Подносак окривљеног који је означен као одговор на жалбу Основног јавног тужиоца којом побија првостепену пресуду због погрешно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да се првостепена пресуда укине и предмет врати на по-

новно суђење и који садржи све податке које треба да садржи жалба у смислу чл. 366. ст. 1. ЗКП и исти је благовремен, сматраће се благовременом и дозвољеном жалбом окривљеног.

Из образложења:

Поднесак означен као одговор на жалбу Основног јавног тужиоца у Врању поднео је окривљени Р.С., којим побија првостепену пресуду због погрешно утврђеног чињеничног стања и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да се првостепена пресуда укине и предмет врати на поновно суђење. Овакав поднесак окривљеног означен као одговор на жалбу другостепени суд је третирао као жалбу окривљеног на пресуду првостепеног суда, с обзиром да исти садржи све податке које по чл. 366. ст. 1. ЗКП треба да садржи жалба, исти је благовремен, односно поднет је у року предвиђеном за изјављивање жалбе, јер је окривљени побијану пресуду, против које се жалба могла изјавити у року од 8 дана од дана пријема исте, примио дана 18.11.2011. године, што се утврђује из враћене повратнице, а поднесак означен као одговор на жалбу примљен је дана 22.11.2011. године, што се утврђује из пријемног штамбиља писарнице Основног суда у Врању и исти је достављен Основном јавном тужиоцу у Врању.

(Пресуда Основног суда у Врању К. бр. 767/11 од 17.10.2011. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 4Кж. 1. 2132/12 од 24.08.2012. године)

Приредили: судија Братислав Крстић и
судијски помоћник Ана Јовичић.

**ПОНАВЉАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
(Чл. 405. ст. 1. тач. 4. ЗКП)
ВАНРЕДНО УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ**

Одредбом чл. 405. ст. 1. тач. 4. ЗКП ("Сл. гласник РС", бр. 58/2004 и 72/2009), предвиђена је могућност преиначења правноснажне пресуде без понављања поступка у свему као у ранијој одредби чл. 415. Закона о кривичном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 70/2001 и 68/2002).

Из образложења:

Наводи из побијаног решења да су раније одредбе о захтеву за ванредно ублажавање казне као ванредном правном леку укинуте и да је то разлог за одбачај захтева осуђеног као недозвољеног и поред тога што је у новом Законнику о кривичном поступку предвиђена нова могућност за преиначење правноснажне пресуде без понављања поступка у смислу чл. 405. ст. 1. тач. 4. ЗКП су неосновани и указују на противуречност изреке и разлога побијаног решења. Одредбом чл. 405. ст. 1. ЗКП је предвиђена могућност преиначења правноснажне пресуде без понављања кривичног поступка у свему као у ранијој одредби чл. 415. Законика о кривичном поступку ("Службени лист СРЈ", број 70/2001) што значи да не стоје наводи побијаног решења да је овај ванредни правни лек укинут јер је он у свему садржан у чл. 405. ст. 1. тач. 4. ЗКП а да је једина разлика у томе да одлуку о ублажавању казне не доноси Врховни суд већ суд који је судио у првом степену. Због изнетих разлога није било места одбачају захтева за ублажавање казне јер се ради о предлогу осуђеног из чл. 405. ст. 1. тач. 4. ЗКП који се разликује од ранијег захтева за ублажавање казне само по називу због тога је првостепени суд био у обавези да поступи у смислу чл. 405. ЗКП.

(Решење Вишег суда у Пироту Кв. бр. 56/12 од 26.04.2012. године решење Апелационог суда у Нишу 4Кж. 2. бр. 669/12 од 04.06.2012. године)

Приредио: судија Братислав Крстић

**ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА
РАЗМАТРАЊА**

Ненад Стојановић,

виши судијски помоћник Апелационог суда у Нишу

ПРЕИНАЧЕЊЕ ПРАВНОСНАЖНЕ ПРЕСУДЕ БЕЗ ПОНАВЉАЊА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА (ЧЛ. 405. СТ. 1. ТАЧ. 1. ЗКП)

У очекивању почетка примене новог Законика о кривичном поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/2011), који поред многобројних и суштинских промена процесног кривичног законодавства Републике Србије, уводи као значајну новину и посебне поступке за преиначење правноснажне пресуде, и то: поступак за опозивање условне осуде и поступке за преиначење одлуке о казни, у оквиру којих је направљена разлика између поступка за изрицање јединствене казне и поступка за ублажавање казне, а који поступци су теоријски и практично оправдано издвојени из одредаба о ванредним правним лековима, указала се потреба разматрања процесне ситуације у вези примене још увек важеће одредбе чл. 405. ст. 1. тач. 1. Законика о кривичном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 70/2001, 68/2002 и "Службени гласник РС", бр. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 49/2007, 20/2009 – др. Закон и 72 од 03.09.2009.).

У поступању Апелационог суда у Нишу, јавио се одређени број предмета у којима су нижестепени судови различито поступали приликом одлучивања о захтеву за преиначење правноснажне пресуде без понављања кривичног поступка, у смислу одредбе чл. 405. ст. 1. тач. 1. ЗКП.

Овај реферат има за циљ да укаже на примену и практични значај одредбе чл. 405. ст. 1. тач. 1. ЗКП, приликом поступања судова по захтеву овлашћених лица за преиначење правноснажне пресуде без понављања кривичног поступка, у смислу наведене одредбе законика.

Наиме, у оквиру главе XXV још увек важећег Законика о кривичном поступку, као ванредни правни лекови прописани су понављање кривичног поступка и захтев за заштиту законитости. Код понављања кривичног поступка, законик теоријски прави разлику између правог и неправог понављања кривичног поступка, при чему одредбе чл. 405. ст. 1. тач.

1. ЗКП спадају у неправо понављање кривичног поступка и прописују услове за преиначење правноснажне пресуде без понављања кривичног поступка.

Према одредби чл. 405. ст. 1. тач. 1. ЗКП, правноснажна пресуда може се преиначити и без понављања кривичног поступка: ако је у две или више пресуда, односно решења о кажњавању против истог осуђеног правноснажно изречено више казни, а нису примењене одредбе о одмеравању јединствене казне за дела у стицају.

Суд који врши приначење мора да пође од тога да су казне утврђене за поједина кривична дела у посебним пресудама правноснажне и да он не може ценити да ли су правилно одмерене и поново их утврђивати. Новом пресудом изриче се само укупна казна за сва кривична дела по прописима о одмеравању јединствене казне за дела у стицају. Разлози нове пресуде треба да се тичу само онога због чега је дошло до изрицања нове пресуде и на који начин се дошло до казне новом пресудом. Нова пресуда не треба да се упушта у остале одредбе ранијих пресуда, односно решења о кажњавању и може да садржи клаузулу да остале одредбе ранијих пресуда, односно решења остају на снази, али то није неопходно. Код изрицања казне према одредбама о одмеравању јединствене казне за дела у стицају, не узимају се у обзир околности од значаја за одмеравање казне у смислу одредбе чл. 54. КЗ, које су настале после правноснажности пресуде, односно решења о кажњавању, већ се нова казна изриче само на основу оних околности које су у кривичном поступку биле узете у обзир и цењене код одмеравања казне, јер се приликом изрицања казне у смислу чл. 405. ст. 1. тач. 1. ЗКП, примењују само одредбе о одмеравању јединствене казне за дела у стицају.

Није могуће применити одредбу чл. 405. ст. 1. тач. 1. ЗКП, ако се по Кривичном закону не може изрећи јединствена казна, као што је на пример случај код две затворске казне, од којих је једна у трајању од шест месеци или дужа, а друга у трајању од месец дана. У том случају нема сагласности одредбе чл. 60. ст. 2. тач. 2. КЗ о одмеравању јединствене казне (да јединствена казна буде већа од најтеже, а мања од збира појединачно утврђених казни) и одредбе чл. 45. ст. 2. КЗ, према којој се казна затвора преко шест месеци не може изрицати на дане, јер у овом случају није могуће применити одредбе о одмеравању јединствене казне за дела у стицају.

Такође, када је у једној или више правноснажних пресуда, односно решења о кажњавању, већ била одмерена казна по одредбама о одмеравању јединствене казне за дела у стицају, онда се при изрицању укупне казне по овим пресудама, односно решењима, за основицу не узимају изречене казне по њима, већ казне утврђене за поједина кривична дела у њима. У супротном, одредбе о одмеравању јединствене казне за дела у стицају биле би два пута примењене на исто кривично дело, што би довело до повреде кривичног закона на штету осуђеног.

Исто тако, нису испуњени законски услови за преиначење правноснажне пресуде без понављања кривичног поступка, уколико је осуђени кривично дело за које је правноснажно осуђен пресудом, учинио након што је издржао казну затвора по ранијој осуди. Ово због тога што је одредбом чл. 62. КЗ, прописано да ако се одређеном лицу суди за кривично дело учињено пре него што је започело издржавање казне по ранијој осуди или за кривично дело учињено за време издржавања казне затвора или малолетничког затвора, суд ће изрећи јединствену казну за сва кривична дела применом одредбе чл. 60. истог закона, узимајући раније изречену казну као већ утврђену. Казна или део казне коју је осуђени издржао урачунаће се у изречену казну затвора.

У једном броју предмета у којима је Апелациони суд поступао, поставило се питање испуњености услова за преиначење правноснажне пресуде без понављања кривичног поступка, у смислу одредбе чл. 405. ст. 1. тач. 1. ЗКП, уколико је подносилац захтева тражио преиначење правноснажне пресуде којом је осуђен на казну затвора и казне затвора настале заменом изречене новчане казне, услед ненаплативости новчане казне.

Према правилној примени одредбе чл. 405. ст. 1. тач. 1. ЗКП, нису испуњени услови за преиначење правноснажне пресуде без понављања кривичног поступка у смислу наведене одредбе законика, уколико је подносилац захтева тражио преиначење правноснажне пресуде којом је осуђен на казну затвора и казне затвора настале заменом изречене новчане казне, услед ненаплативости новчане казне. Ово због тога што се казна затвора на коју је подносилац захтева осуђен правноснажном пресудом, не може спајати са казном затвора насталом заменом новчане казне у смислу одредбе чл. 51. ст. 2. Кривичног законика ("Службени гласник РС", бр. 85/2005, . . 72/2009), услед ненаплативости изречене новчане казне. Наиме без обзира да ли се ради о казни затвора, насталој заменом новчане казне

која није наплаћена у целости или се ради о остатку неплаћене новчане казне, овако настала казна затвора, заменом новчане казне, не може се изједначити са осудом на казну затвора, јер је овако настала казна затвора, аутономна и не може се спајати са осудом на казну затвора, нити се за овако насталу казну затвора могу везивати правне последице осуде, обзиром да се не ради о казни затвора на коју је подносилац захтева осуђен, већ о новчаној казни замењеној казном затвора, услед ненаплативости изречене новчане казне. Осим тога, осуђени се у поступку извршења новчане казне, може ослободити казне затвора настале заменом новчане казне, плаћањем изречене новчане казне у целости или њеног остатка, док се насупрот томе, осуђени не може ослободити непосредне казне затвора на коју је осуђен правноснажном пресудом.

Такође, као једно од питања у вези примене наведене одредбе чл. 405. ст. 1. тач. 1. ЗКП, поставило се и питање врсте одлуке којом надлежни суд одлучује о захтеву за преиначење правноснажне пресуде без понављања кривичног поступка у смислу наведене одредбе законика.

Према одредби чл. 405. ст. 2. ЗКП, у случају из тач. 1. ст. 1. овог члана, суд ће новом пресудом преиначити раније пресуде, односно решења о кажњавању, у погледу одлука о казни и изрећи јединствену казну. За доношење нове пресуде надлежан је првостепни суд који је судио у ствари у којој је изречена најстрожа врста казне, а код истоврсних казни – суд који је изрекао највећу казну, а ако су казне једнаке – суд који је последњи изрекао казну.

Имајући у виду судску праксу Апелационог суда у Нишу, може се закључити да су надлежни судови различито поступали приликом одлучивања о захтевима за преиначење правноснажне пресуде без понављања кривичног поступка, у смислу одредбе чл. 405. ст. 1. тач. 1. ЗКП.

У начелу није спорно да је правилно поступање судова, у случају када утврде да су испуњени услови из чл. 405. ст. 1. тач. 1. ЗКП, тада новом пресудом преиначе раније пресуде, односно решења о кажњавању, у погледу одлука о казни и изрекну јединствену казну, примењујући одредбе о одмеравању јединствене казне за дела у стицају, обзиром да није могуће да се две или више пресуда, односно решења, замене новим решењем и да то ново решење садржи осуду.

Као спорно се појавило питање, да ли у ситуацији када суд утврди да нису испуњени услови за преиначење правноснажне пресуде без понављања кривичног поступка, у смислу одредбе чл. 405. ст. 1. тач. 1. ЗКП, треба да одбије такав захтев пресудом или решењем. У том погледу је било различитих схватања, од тога да захтев треба одбити решењем, па до тога да захтев треба одбити пресудом. Према налажењу Апелационог суда, чини се да је правилније схватање да захтев треба одбити новом пресудом, јер је правилније да се о предметном захтеву мериторно одлучи новом пресудом.

У прилог томе да захтев треба одбити новом пресудом, јесте између осталог и то да се решењем по правилу одлучује о процесним недостацима поднетог захтева, тако да о предметном захтеву није оправдано мериторно одлучивати решењем и због тога што би другостепени суд у случају изјављене жалбе на решење, био у неку руку ограничен у погледу испитивања испуњености услова за преиначење правноснажне пресуде без понављања кривичног поступка, у смислу одредбе чл. 405. ст. 1. тач. 1. ЗКП. Због тога се чини да је правилније схватање да о захтеву треба одлучити новом пресудом, јер би у том случају другостепени суд одлучујући о жалби на нову пресуду, могао испитати испуњеност услова за преиначење правноснажне пресуде без понављања кривичног поступка, у смислу одредбе чл. 405. ст. 1. тач. 1. ЗКП, па би у зависности од тог утврђења, другостепени суд могао мериторно одлучити о предметном захтеву.

На крају, у овом реферату је већ указано да нови Законик о кривичном поступку, чија се примена очекује од 15. јануара 2013. године, у оквиру посебних поступака, тачније у глави XXIII, одредбе чл. 544. до 561, уводи као значајну новину и посебне поступке за преиначење правноснажне пресуде, и то: поступак за опозивање условне осуде и поступке за преиначење одлуке о казни. У оквиру поступака за преиначење одлуке о казни, нови закон прави разлику између поступка за изрицање јединствене казне и поступка за ублажавање казне. Треба напоменути да је законик у оквиру поступка за изрицање јединствене казне (одредбе чл. 552. до 556.), много конкретније уредио покретање поступка, надлежност за одлучивање и само одлучивање о захтеву. На тај начин су отклоњене многе дилеме у поступању судова, па и једна од дилема којом се овај реферат у једном делу бавио, да ли у случају одбијања захтева треба одлучити пресудом или решењем. Наиме, одредбом чл. 554. ст. 3. ЗКП, прописано

је да ће суд пресудом одбити или усвојити захтев за изрицање јединствене казне, док је одредбом чл. 555. ЗКП, прописано да ће суд пресудом одбити захтев за изрицање јединствене казне, ако утврди да нема разлога из чл. 552. овог законика. Дакле, без обзира што се у новом законiku ради о новом поступку за изрицање јединствене казне, он је несумњиво аналоган још увек важећем преиначењу правноснажне пресуде без понављања кривичног поступка у смислу одредбе чл. 405. ст. 1. тач. 1. ЗКП, па се јасно може закључити да у случају одбијања захтева треба одлучити пресудом.

У овом реферату није било могуће указати на све различите правне ситуације и сва различита поступања нижестепених судова приликом одлучивања о захтеву за преиначење правноснажне пресуде без понављања кривичног поступка, у смислу одредбе чл. 405. ст. 1. тач. 1. још увек важећег Законика о кривичном поступку, али је настојање реферата да се пробуди активност других судова и судија, да уколико имају сазнања о томе да постоје различите одлуке у идентичним правним ситуацијама, на то укажу и иницирају заузимање правних ставова, а све у циљу уједначавања судске праксе, истоветног поступања судова и законитог и правичног вођења кривичног поступка, што све води ка пружању једнаке, правичне и законите судске заштите свим грађанима.

ПРАВО НА ЖИВОТ

(Чл. 2. Европске конвенције о људским правима)

Уколико је евентуални извршилац кривичног дела убиства непознат, мора се спровести званична истрага од стране државе, ради идентификације и кажњавања одговорног лица.

Из образложења:

Првостепени суд је, одлучујући поводом неслагања истражног судије Вишег суда у Прокупљу са захтевом за спровођење истраге оштећеног као тужиоца, ценећи исти као предлог за предузимање појединих истражних радњи, закључио да у списима предмета не постоји ниједан доказ нити околност, који би указивали на постојање основане сумње да је непознати извршилац извршио кривично дело убиство из чл. 113. КЗ на штету пок. Д. С. При томе је цитирао изјашњење истражног судије, који је здружио списе предмета и утврдио да за сада не постоји основана сумња

да је извршено кривично дело убиство из чл. 113. КЗ, с обзиром да је у обдукционом записнику Завода за судску медицину у Нишу као узрок смрти наведен нагли престанак срчаног рада и последични јакостепени натоп плућа са престанком дисања, који је наступио из непознатих разлога.

Међутим, по налажењу Апелационог суда, овакав закључак првостепеног суда не може се прихватити као правилан, јер из списка предмета произилази да у конкретном случају постоји основана сумња да је учињено кривично дело. Ово из разлога што на основу извршене обдукције од стране Завода за судску медицину у Нишу, као и на основу токсиколошко-хемијске анализе извршене од стране истог Завода, као и од стране ВМА-Центар за контролу тровања-Институт за токсикологију и фармакологију-Одељење за токсиколошку хемију, није утврђено шта је узрок смрти пок. Д. С, до које је дошло дана 07.01.2011. године, јер је закључак Завода за судску медицину да је до престанка срчаног рада дошло из непознатих разлога.

С обзиром на овакав закључак, а имајући у виду да се ради о особи која је у моменту смрти имала непуних 18 година, као и да обдукцијом код ње није утврђено постојање било каквог обољења, већ је узрок смрти остао непознат, то се показује неопходним да се спроведу одређене истражне радње, с обзиром да је непознат евентуални учинилац кривичног дела, а у циљу расветљавања ствари и откривања учиниоца. При томе, Апелациони суд је нашао да у овом случају треба применити одредбу чл. 2. Европске конвенције о људским правима, која се односи на право на живот и према којој је право на живот сваке особе заштићено законом и нико не може бити намерно лишен живота, сем приликом извршења пресуде суда којом је осуђен за злочин, за који је ова казна предвиђена законом.

Према пракси Европског суда за људска права (пресуда Салман против Турске П. бр. 21986/93, пресуда Пол и Одри Едвардс против Уједињеног краљевства број 46477/99, пресуда Контрова против Словачке број 7510/04, пресуда Младеновић против Србије број 1099/08), право на живот сматра се једним од најзначајних права у Конвенцији и лишење живота је стога предмет најстрожег испитивања од стране суда. Обавеза да се заштити право на живот по чл. 2. Европске конвенције о људским правима, посматрана у вези са општом дужношћу државе по чл. 1. Конвенције, да обезбеди свакоме у оквиру њене надлежности права и слободе утврђене Конвенцијом, такође подразумева захтев да треба да постоји не-

ки облике званичне истраге, када је као последица употребе силе дошло до убиства појединца. Суштинска сврха такве истраге је да се обезбеди делотворна примена домаћих закона који штите право на живот.

Дакле, према пракси Европског суда за људска права, обавеза заштите живота по чл. 2. Конвенције, подразумева делотворну истрагу која може довести до идентификације и кажњавања одговорних лица, односно да је одговорност да обезбеди кривични прогон и да спречи некажњивост починиоца на страни државе. То даље значи да се морају предузети све разумне мере, које стоје на располагању, да обезбеде доказе у вези са тим догађајем, јер сваки недостатак у истрази који подрива ову могућност, може довести до ризика да се наведени стандард неће поштовати.

(Решење Вишег суда у Прокупљу Кв. бр. 45/12 од 05.04.2012. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж. 2. бр. 497/12 од 01.08.2012. године)

Приредила: судија Горана Митић

Зоран Ђорђевић,
судија Апелационог суда у Нишу

**ПРИМЕНА ЗАКОНА О ОДРЕЂИВАЊУ
МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
У ЛОКАЛНОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ
("Сл. гласник РС", бр. 104/2009)**

Увод

Унутрашњи извори радног права јесу Устав, закони, подзаконски акти, колективни уговори, правилници о раду, други општи акти и уговори о раду. Устав је највиши унутрашњи општи правни акт. Матични закон у области радног права јесте Закон о раду. То је општи закон који се односи на све запослене и све послодавце, ако посебним законом није друкчије одређено. У области где не постоји посебни закон примењује се Закон о раду директно. Ако посебних закона има тада се примењује делимично и супсидијарно. У појединим радним срединама, односно на одређене категорије запослених и послодаваца у примени су различити посебни закони. (Закон о државним службеницима, Закон о полицији, Царински закон, Закон о радним односима у државним органима, Закон о основама система образовања и васпитања и сл.). Подзаконски акти јесу прописи које доноси Влада и Министарство. Влада најчешће доноси уредбе, одлуке и упутства, а министарства доносе правилнике, наредбе и упутства. Подзаконски акти се доносе ради реализације законских прописа.

Колективни уговори представљају тзв. недржавне изворе радног права. Тим актима овлашћени представници синдиката радника или њихове организације и удружења послодаваца утврђују права, обавезе и одговорности радника и послодавца, те међусобне односе лица која су уговор закључила. Према Закону о раду постоје три врсте уговора. Општи колективни уговор, посебни и уговори код послодаваца. Посебни колективни уговор се закључује за одређену област рада (делатност, грана, група или подгрупа) или за одређену територију (покрајина, град, општина), или за одређену категорију послодаваца (јавна предузећа и јавне службе),

те за одређену категорију запослених као што су самостални уметници и делатници у спорту. Колективним уговором код послодавца утврђују се права, обавезе и одговорности запослених и послодавца између којих је закључен, а односи се на све запослене код послодавца. Правилник о раду доноси управни одбор послодавца, а када тај орган не постоји, онда правилник доноси директор или други орган пословођења. Тај акт се доноси у случају и под условима који су прописани одредбама из чл. 3. ст. 4. Закона о раду. Уговором о раду заснива се радни однос између запосленог и послодавца, а њиме се и уређује радни однос, односно утврђују се права и обавезе запослених и послодавца између којих је закључен.¹

Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији јесте закон у области радног законодавства. Он је један од унутрашњих извора радног права. Донет је у околностима глобалне економске кризе а у циљу смањења јавне потрошње која се финансира из буџета Републике Србије. За неиспуњење обавеза послодавца на које се односи закон у остављеним роковима, који су врло кратки, последица за послодавца је ускраћивање средстава која припадају јединицама локалне самоуправе по критеријумима из Закона о финансирању локалне самоуправе² за обављање изворних и поверених послова. За запослене код послодавца на које се закон односи јесте стицање статуса нераспоређености, а након тога престанак радног односа уз признавање права на отпремнину под условима прописаним законом и на новчану накнаду за случај незапослености, у висини утврђеној у складу са прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености.

Зато је важно посветити пажњу заштити права запослених на које се закон односи, јер све представљене околности могу увећати ризик повреда њихових права из радног односа.

Запослени и послодавци на које се закон односи

Према чл. 1. Закона произилази да се њиме одређује укупан максимални број запослених у органима јединица локалне самоуправе (укљу-

¹ Извори, и остваривање и заштита права из радног односа- Зборник радова из 2009. године

² „Сл. гл. РС“, бр. 62/2006 и 47/2011

чујући и органе градских општина), установама које се финансирају из буџета (осим установа у области образовања, здравства и предшколских установа), привредним друштвима и другим облицима организовања чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе (осим јавних предузећа), а који се финансирају из буџета оснивача (локална администрација).

Карактер закона да се ради о пропису у области радног законодавства и да се ради о посебном закону и о тзв. *lex specialis* у односу на матични Закон о раду опредељен је у самом називу и у основним нормама из цитираног члана јер се њиме лимитира број запослених код одређених послодаваца и то код органа општинске и градске управе (јединице локалне самоуправе), те у појединим установама које се финансирају из буџета наведених јединица локалне самоуправе, јер је примена закона изузета у односу на установе из области образовања, здравства и предшколских установа, а од примене закона изузета су и поједина привредна друштва, односно јавна предузећа која се оснивају за поједине делатности у погледу којих је законом прописано да се оснивају јавна предузећа.

Јединице локалне самоуправе, критеријуми за њихово оснивање, надлежности, органи и друга питања од значаја за остваривање права и дужности јединица локалне самоуправе уређени су Законом о локалној самоуправи.³ Према одредбама тог закона локална самоуправа се остварује у општини, граду и граду Београду. Надлежности општине утврђене су чл. 20. и 22. тог закона, као и поједини послови државне управе, најчешће инспекцијски надзор из области просвете, здравства, заштите животне средине, рударства, промета робе и услуга, пољопривреде, водопривреде и шумарства.

Законом прописани послови из надлежности општине и поверени послови из надлежности државне управе остварују се преко општинске управе која се образује као јединствени орган у општинама до 50. 000 становника а могу се образовати и општинске управе за поједине области у општинама са преко 50. 000 становника. То произилази из одредаба чл. 52. и 53. поменутог закона.

³ „Сл. гл. РС“, бр. 129/2007

Одредбама истог закона из чл. 65. и 66. прописано да је поред осталих органа, орган града и градска управа, која обавља послове предвиђене законом за органе општине, односно општинске управе.

У смислу чл. 54., 55. и 59. општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник који јесте постављено лице, а кад се општинска управа организује у више управа, радом управе руководи такође начелник који има статус постављеног лица. Он може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност, а који такође има статус постављеног лица. Кад се у општинској управи за вршење сродних послова образују унутрашње организационе јединице, тада руководиоце тих јединица у управи распоређује начелник. Начелник уз сагласност општинског већа доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управе.

Међутим, Законом о локалној самоуправи нису регулисани критеријуми за одређивање укупно максималног броја запослених у органима управе у наведеним јединицама локалне самоуправе и с тим у вези за решавање вишка запослених. Тај закон не садржи нити одредбе о уређивању права, обавеза и одговорности из радног односа, односно на основу рада запослених код општинске и градске управе.

Одредбама наведеног закона је прописано и то да јединица локалне самоуправе има својство правног лица. То својство нема општинска и градска управа и њихове унутрашње организационе јединице (одељења, службе и сл.).

Имајући у виду одредбе из чл. 1. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији и правила Закона о локалној самоуправи произилази да се Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији односи на запослене у општинској и градској управи, односно на те управе и њихове унутрашње организационе јединице, односно општине и градове.

Према одредбама из чл. 1. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији он се односи и на запослене код послодаваца који јесу установе а искључиво се финансирају из буџета, привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе (општина и град), а који се финансирају из

буџета оснивача, осим установа у области образовања, здравства и предшколских установа и осим јавних предузећа.

Јавне службе дефинисане су Законом о јавним службама.⁴ Према чл. 1 ст. 1. тог закона јавном службом сматрају се установе, предузећа и други облици организовања утврђени законом, који обављају делатности односно послове којима се обезбеђују остваривање права грађана односно задовољавање потребе грађана и организација, као и остваривање другог законом одређеног интереса у одређеним областима.

У смислу чл. 3. наведеног Закона јавним службама сматрају се установе из области образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студенског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања и здравствене заштите животиња. Јавним службама сматрају се и области јавног информисања ПТТ саобраћаја, енергетике, путева, комуналних услуга и друге области одређене законом, а за обављање делатности у наведеним областима оснивају се предузећа.

Према чл. 1 ст. 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса,⁵ јавно предузеће је предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива држава, односно јединица локалне самоуправе или аутономна покрајина. Према чл. 2. тог Закона делатности од општих интереса јесу делатности које су као такве одређене законом у области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије, производње и прераде угља, истраживања, производње и прераде и транспорта и дистрибуције нафте и природног и течног гаса, промета нафте и нафтиних деривата, железничког, поштанског и ваздушног саобраћаја, телекомуникација, издавања службеног гласила Републике Србије, информисања, издавања уџбеника, коришћења управљања заштите и унапређења добара од општег интереса (воде путеви минералне сировине, шуме, пловне реке, језера, обале, бање, дивљач), као и комуналне делатности. Делатности од општег интереса јесу и делатности од стратешког значаја за Републику, као и делатности неопходне за рад државних органа и органа јединице локалне самоуправе, утврђене законом. Делатност од општег интереса обављају јавна предузећа према чл. 3. Закона, а може да

⁴ „Сл. гл. РС“, бр. 42/91- 99/05

⁵ „Сл. гл. РС“ бр. 25/2000- 108/2005;

их обавља и привредно друштво, односно други облик предузећа, део предузећа и предузетник, у складу са законом којим се уређује њихов правни положај, када им надлежни орган повери обављање те делатности. Други облици предузећа, део предузећа и предузетник у обављању делатности од општег интереса имају исти положај као и јавно предузеће, уколико законом није друкчије прописано. Јавно предузеће за обављање комуналне делатности или делатности од значаја за рад органа јединице локалне самоуправе може да оснује јединица локалне самоуправе према чл. 4. истог Закона, а у смислу чл. 10. тог закона јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином, док други облици предузећа која обављају делатност од општег интереса за своје обавезе одговарају у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава. Предузетник који обавља делатност од општег интереса за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

Комуналне делатности одређене су и уређени услови и начин њиховог обављања Законом о комуналним делатностима⁶. У смислу чл. 2. тог Закона комуналне делатности су делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем.

Комуналне делатности су делатности од општег интереса. Комуналне делатности су: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије, управљање комуналних отпадом, градски и приградски превоз путника, управљање гробљима и погребне услуге, управљање јавним паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање улица и путева, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, димничарске услуге, делатност зоохигијене.

Комуналне делатности из става 3. тач. 1) до 4) овог члана су и делатности од општег економског интереса у смислу прописа о заштити потрошача.

⁶ „Сл. гл. РС“ бр. 88/2011;

Скупштина јединице локалне самоуправе може као комуналне одредити и друге делатности од локалног интереса и прописати услове њиховог обављања у складу са ставом 1. овог члана. Скоро истоветне одредбе о поменутих питањима садржи и ранији Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса.

Према одредбама Закона о јавним агенцијама⁷, јавна агенција јесте организација која се оснива за развојне, стручне или регулаторске послове од општег интереса. Оснивају се ако развојни, стручни и регулаторни послови не захтевају сталан и непосредан политички надзор и ако агенција може боље и делотворније да их врши него орган државне управе, нарочито ако се у целини или претежно могу финансирати од цене коју плаћају корисници услуга. Јединице локалне самоуправе могу да оснују јавну агенцију кад су на то овлашћене својим општим актом, ако су за то остварени услови одређени законом. Права оснивача врши орган одређен њиховим актом. Јединица локалне самоуправе може јавној агенцији поверити послове из свог делокруга који по врсти и природи одговарају пословима државне управе које јавним агенцијама може поверити Република Србија. На питања која нису уређена посебним одредбама закона а односе се на јавне агенције које оснивају јединице локалне самоуправе, примењују се одредбе закона којим се уређују јавне агенције чији је оснивач Република Србија. То подразумева да се примењују одредбе о томе да јавне агенције имају својство правног лица, које се стиче уписом у регистар, да је самостална у свом раду, да директор заступа и представља јавну агенцију, руководи радом и пословањем агенције и одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у јавној агенцији, и врши друге послове који су том органу стављени у надлежност законом, те да се на права, обавезе и одговорности и зараде директора примењују општи прописи о раду, ако овим или посебним законом није што друго одређено. То надаље подразумева да јавна агенција престаје да ради ако буде укинута одлуком оснивача или се правноснажном судском одлуком утврди ништавост њеног уписа у судски регистар. Подразумева и то да јавна агенција одговара за своје обавезе свом својом имовином. На јавне агенције чији је оснивач јединица локалне самоуправе примењују се и одредбе о томе да се послови који су поверени агенцији искључиво из надлежности органа

⁷ „Сл. гл. РС“ бр. 18/2005 и 81/2005;

општинске или градске управе могу финансирати искључиво из буџета оснивача а што даље подразумева да би се Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији односио и на запослене и послодавце који су организовани у виду јавне агенције.

Закон о локалној самоуправи, Закон о јавним службама, Закон о јавним предузећима, Закон о комуналним делатностима и ранији Закон о комуналним делатностима из 1997. године, те Закон о јавним агенцијама не садрже одредбе о правима, обавезама и одговорностима запослених, односно о критеријумима за утврђивање укупног максималног броја запослених код послодаваца на које се односе и с тим у вези о критеријумима и условима за решавање вишка запослених.

Критеријуми за решавање вишка запослених код послодаваца на које се односи закон

Одредбе из чл. 2. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији регулишу критеријуме за одређивање укупног максималног броја запослених на неодређено време код послодаваца из чл. 1. Закона, те одступања од основног критеријума из става 1. наведеног члана којим је прописано да укупан максимални број запослених на неодређено време у локалној администрацији не може бити већи од четири запослена на хиљаде становника, према последњем попису становништва (максимални број запослених). Истовремено садрже и правила о времену до када се број запослених може смањити до укупног максималног броја запослених утврђеног законом, те правила о последицама по јединице локалне самоуправе уколико се до 31.12.2009. године не изврши смањење броја запослених на неодређено време до укупног максималног броја. О томе правила из става 6. и 7. члана 2. Закона прописују: “Уколико је број запослених на неодређено време у локалној администрацији већи од максималног броја запослених, усвајањем акта о систематизацији радних места до 31.12.2009. године број запослених може се смањити до максималног броја запослених. Уколико се до 31.12.2009. године не изврши смањење броја запослених на неодређено време до максималног броја запослених, јединице локалне самоуправе, почев од 01.01.2010. године, вршиће се сразмерно смањење трансфера средстава из буџета Републике

Србије у зависности од броја запослених у локалној администрацији који прелази максималан број запослених у складу са овим законом. “

Имајући у виду наведене одредбе, произилази да се већ у тим почетним одредбама најављује прва активност послодаваца на које се односи закон у смислу утврђивања максималног броја запослених према критеријумима закона и усвајање акта о систематизацији радних места и утврђивање вишка запослених. Остале посебности закона јесу врло кратак рок послодавцима за смањење броја запослених до максималног броја који се признаје законом, а последица за послодавца уколико неиспуне обавезу из закона у року прописаном законом јесте ускраћивање трансфера средстава из буџета Републике Србије јединицама локалне самоуправе.

Одредбе из чл. 3. Закона односе се на укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основима. Тај број не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време у локалној администрацији. Поледица за послодавца је умањење трансфера средстава из буџета Републике Србије јединицама локалне самоуправе за 1 % опредељених месечних трансфера у текућој години за свако прекорачење у погледу броја запослених од 1 %. То ограничење се не односи на установе у области културе.

Правила из члана 4, 5, 6, 7. и 8. Закона садрже корективе чијом применом се утврђује максимални број запослених у локалној администрацији и с тим у вези корективе о висини трансфера средстава из буџета Републике Србије јединицама локалне самоуправе, те околности о роковима за смањење броја запослених на неодређено време и стицање права на трансфер средстава по основу стимулације јединицама локалне самоуправе које након 31.12.2009. године сведу број запослених на мањи број од коначног потребног смањења применом прописаних коректива, а у смислу увећања месечног трансфера средстава.

Међутим, све наведене одредбе без значаја су за поступање у судским поступцима у парницама за оцену законитости одлука послодаваца о утврђивању статуса нераспоређености запослених за чијим радом је престала потреба после утврђивања укупног максималног броја запослених у локалној администрацији на неодређено време, а после доношења акта о

систематизацији радних места и ради оцене законитости одлука о престанку радног односа лицима која су стекла статус незапослених. Нису важне ни одредбе из чл. 10, 11, 12. и 13. Закона.

За ту врсту спорова јесу битне одредбе из чл. 9. Закона, јер се оне примењују за расправљање и одлучивање о тужбама за поништај наведених одлука и враћање запослених на рад. Наведеним чл. 9. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији је прописано:

Запослени у органима јединица локалне самоуправе који након ступања на снагу акта о систематизацији радних места из чл. 2. ст. 6. овог закона постану нераспоређени остварују права у складу са прописима којима се уређују права запослених у органима јединица локалне самоуправе (ст. 1.).

Осталим запосленима у локалној администрацији за чијим радом престане потреба након ступања на снагу акта о систематизацији радних места из чл. 2. ст. 6. овог закона исплаћује се отпремнина и отказује уговор о раду у складу са законом (ст. 2.).

Лицу из ст. 1. и 2. овог члана исплаћује се отпремнина за сваку навршену годину рада у радном односу у висини трећине његове плате, односно зараде, с тим што се под том платом, односно зарадом сматра његова просечна месечна плата, односно зарада која му је исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у коме је донесено решење којим је утврђено да је постао нераспоређен, односно решење о отказу уговора о раду (ст. 3.).

Лица из ст. 1 и 2. овог члана имају право на новчану накнаду за случај незапослености, у висини утврђеној у складу са прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености (ст. 4.).

У поступку утврђивања статуса нераспоређеног запосленог у органу јединице локалне самоуправе и утврђивања да за радом запосленог престаје потреба у установи, привредном друштву и другом облику организовања у обзир се узимају резултати рада и имовно стање, у складу са применом општих прописа о раду и на начин и у обиму који се утврђени у тим прописима (ст. 5.).

Према наведеним одредбама произилази да није истоврсна правна регулатива када се ради о запосленима у органима јединица локалне самоуправе, дакле органима општинских управа и градске управе и у установама које се финансирају из буџета наведених јединица локалне самоуправе, те привредним друштвима и другим облицима организовања чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе а који се финансирају из буџета оснивача. На нераспоређене запослене у општинским и у градској управи примењују се права у складу са прописима којима се уређују права запослених у органима локалне самоуправе. Осталим запосленима у ситуацији за чијим је радом престала потреба исплаћује се отпремнина и отказује уговор о раду у складу са законом, при чему се не опредељује у складу са којим законом. Обема категоријама наведених лица исплаћује се отпремнина у висини прописаној Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији и признаје право на накнаду за случај незапослености у висини која се утврђује на основу критеријума који су утврђени прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености.

За утврђивање статуса нераспоређеног запосленог код послодаваца на које се Закон односи прописана су само два критеријума. Први критеријум су резултати рада, а други имовно стање, који се примењују у складу са применом општих прописа о раду и на начин и у обиму који су утврђени у тим прописима.

Код овакве регулативе неопходно је осврнути се на прописе на чију примену упућују одредбе из чл. 9. Закона.

Устав⁸ као највиши писани правни акт који је у истом нивоу са општеприхваћеним правилима међународног права, са којим морају бити усаглашени сви други унутрашњи извори права, право на рад, које јесте једно од најважнијих права човека, регулише чл. 60. тако што прописује да се јемчи право на рад, у складу са законом, да свако има право на слободан избор рада, да су свима под једнаким условима, доступна сва радна места, да свако има право на поштовање достојанства своје личности на раду, безбедне и здраве услове рада, потребну заштиту на раду, ограничено радно време, дневни и недељни одмор, плаћени годишњи одмор, пра-

⁸ „Сл. гл. РС“, бр. 98/2006;

вичну накнаду за рад и на правну заштиту за случај престанка радног односа, да се нико тих права не може одрећи и да се женама, омладини и инвалидима омогућују посебна заштита на раду и посебни услови рада, у складу са законом. Ова одредба не садржи правила о лимитирању броја запослених код било ког послодавца, те услове и разлоге за ограничење броја запослених код појединих послодаваца и с тим у вези за смањење броја запослених за чијим је радом престала потреба послодавца. То не прописује нити наредна одредба из чл. 61. Устава јер се њоме прописује право запослених на штрајк и ограничење тог права само законом, у зависности од природе или врсте делатности. Међутим, прописује право на правну заштиту за случај престанка радног односа, те да се одређеној групи лица мора омогућити посебна заштита на раду, женама, омладини и инвалидима.

Матични закон у области радних односа, Закона о раду,⁹ јесте општи пропис у овој области. Односи се на све запослене и послодавце, јер је у чл. 1. и 2. тог Закона прописано:

Права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада, уређују се овим законом и посебним законом, у складу са ратификованим међународним конвенцијама. Права, обавеза и одговорности из радног односа уређују се и колективним уговором и уговором о раду, а правилником о раду, односно уговором о раду - само када је то овим законом одређено. Одредбе овог закона примењују се на запослене који раде на територији Републике Србије, код домаћег или страног правног, односно физичког лица (послодавац), као и на запослене који су упућени на рад у иностранство од стране послодавца ако законом није друкчије одређено. Одредбе овог закона примењују се и на запослене у државним органима, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавним службама, ако законом није друкчије одређено. Одредбе овог закона примењују се на запослене стране држављане и лица без држављанства који раде код послодавца на територији Републике Србије, ако законом није друкчије одређено.

Посебни закони јесу: Закон о државним службеницима,¹⁰ Закон о радним односима у државним органима,¹¹ Закон о полицији,¹² Закон о

⁹ „Сл. гл. РС“, бр. 24/2005 и 61/2005;

¹⁰ „Сл. гл. РС“ бр. 79/05- 116/08

судијама,¹³ Закон о јавном тужилаштву,¹⁴ Закон о основама система образовања и васпитања,¹⁵ Закон о високом образовању,¹⁶ и сви други закони који садрже правила о радним односима.

На права, обавезе и одговорности из радних односа запослених у органима јединица локалне самоуправе примењује се Закон о радним односима у државним органима почев од 01.07.2006. године, на основу чл. 189. Закона о државним службеницима, а важиће док се за те органе не донесе посебан закон. Због тога, на оно што није уређено наведеним законом супсидијарно се примењује општи закон односно матични Закон о раду.

На права, обавезе и одговорности из радних односа, односно по основу рада запослених код осталих послодаваца из чл. 1. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији примењује се матични Закон о раду, јер је брисан чл. 23. Закона о јавним службама, којим је било прописано да се у погледу права, обавеза и одговорности запослених у установама из чл. 1. тог закона примењују прописи о радним односима у државним органима. Та одредба је брисана Законом о државним службеницима тако да се почев од 01.07.2006. године на радне односе у јавним службама примењује Закон о раду.

Закон о радним односима у државним органима садржи одредбе о престанку радног односа и о правима по престанку радног односа, као и одредбе о остваривању и заштити права запослених и постављених лица. Према чл. 64. тог Закона радни однос запослених у државним органима изабраних односно постављених лица престаје под условима и на начин утврђен овим законом и другим законима. У чл. 64а је прописано да радни однос престаје на основу писменог отказа запосленог или постављеног лица који се доставља функционеру који руководи државним органом односно органу или телу надлежном за постављање, најмање 15 дана пре дана означеног као дан престанка радног односа. Запосленом се отказује радни однос поред осталих случајева и када услед промена у организацији

¹¹ „Сл. гл. РС“ бр. 48/91- 39/2002

¹² „Сл. гл. РС“ бр. 101/05

¹³ „Сл. гл. РС“ бр. 116/08- 104/09

¹⁴ „Сл. гл. РС“ бр. 116/2008 - 101/2011

¹⁵ „Сл. гл. РС“ бр. 75/2009 и 52/2011

¹⁶ „Сл. гл. РС“ бр. 76/2005 - 44/2010

стекне статус нераспоређеног, а не може му се обезбедити радно место у истом или другом државном органу. Та одредба примењује се и на постављена лица. Правилима из чл. 65. тог Закона је прописано да ако је у државном органу дошло до смањења броја запослених, односно постављених лица, услед промена у организацији и методу рада, односно услед смањења обима и укидања послова, запослени и постављена лица распоређују се на радна места у истом или другом државном органу које одговарају њиховој стручној спреми. Одлуку о распоређивању запослених доноси функционер који руководи органом у којем се запослени распоређује, а одлуку о распоређивању постављених лица доноси орган који их је поставио. Ако запослени или постављено лице не прихвати радно место на које је распоређен, престаје му радни однос. Уколико се запослени, односно постављено лице, не може распоредити, функционер који руководи органом доноси решење којим се утврђује да је запослени, односно постављено лице, остало нераспоређено. Према одредбама из чл. 66. наведеног закона запослени у државним органима, односно постављена лица, који су остали нераспоређени на начин утврђен у чл. 65. имају иста права и обавезе као и запослени за чијим радом је престала потреба у предузећима, утврђена законом. У чл. 67. и 68 истог Закона прописано је да у случају укидања државног органа, државни орган у чији делокруг прелазе послови укинутог органа преузима потребан број запослених и постављених лица који су радили на преузетим пословима. У складу с потребама органа, функционер који руководи државним органом у чији су делокруг прешли послови укинутог органа доноси решење о распоређивању запослених који су преузети, а решења о распоређивању постављених лица доноси орган који их је поставио. У случају укидања државног органа и укидања свих послова који су се обављали у делокругу тог органа запослени и постављена лица који су радили у укинутом органу остају нераспоређени. У том случају и у случају када нису преузети због укидања државног органа од стране државног органа у чији делокруг су прешли послови укинутог органа они имају права и обавезе утврђене чл. 66. Закона. У ситуацији спајања два или више државна органа у нов орган сви запослени и постављена лица у овим органима имају статус нераспоређених. У складу са потребама органа, функционер који руководи државним органом доноси решење о распоређивању запослених који имају статус нераспоређених, а решења о распоређивању постављених лица која имају статус нераспоређених доноси орган који их је поставио.

Одредбама из чл. 71. Закона о радним односима у државним органима прописан је поступак за остваривање и заштиту права запослених и постављених лица. Прописано је да ради остваривања својих права, запослени у државном органу, односно постављена лица, писмено се обраћају функционеру који руководи органом. Против сваког решења или другог акта којим је одлучено о његовим правима и обавезама запослени, односно постављено лице, има право да поднесе приговор. Приговор се подноси функционеру који руководи државним органом у року од 8 дана од дана уручења решења или другог акта, а функционер је дужан да о њему одлучи у року од 15 дана од дана подношења приговора. Разматрајући поднети приговор, функционер преиспитује своју одлуку и може је изменити или допунити. Запослени, односно постављено лице, има право да поднесе приговор и у случају кад функционер у року од 15 дана од дана подношења захтева не одлучи о праву на које се захтев односи. Ако функционер у утврђеном року не одлучи о поднетом приговору или ако запослени, односно постављено лице, није задовољан одлуком функционера поводом поменутог приговора, запослени, односно постављено лице може се обратити надлежном суду у року од 15 дана.

Закон о раду не садржи одредбе о лимитирању максималног броја запослених код послодаваца на које се односи, па и код послодавца из чл. 1. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији. Међутим, садржи одредбе о решавању вишка запослених код послодаваца на које се примењује директно или супсидијарно, при чему не регулише поступак за утврђивање статуса нераспоређених запослених за чијим радом је престала потреба послодавца. Одредбе из чл. 153 до 160. наведеног закона прописују обавезу послодавца који утврди да ће због технолошких, економских или организационих промена доћи до престанка потребе за радом одређеног броја радника у радном односу на неодређено време да донесе програм решавања вишка запослених што зависи од броја запослених на неодређено време и од периода у оквиру којег ће доћи до престанка потребе за радом. Међутим, ако послодавац запошљава мањи број радника, мањи од мере из чл. 153. Закона или ако одреди дужи рок за смањење броја запослених, тада може да се ослободи вишка и без програма. Закон о раду не прописује критеријуме за утврђивање вишка запослених нити у случају када се врши смањење без програма, нити у случају када се вишак запослених решава кроз доношење програма, при чему

прописује да критеријуме за утврђивање вишка запослених мора садржати програм, а они морају бити усклађени са општим колективним уговором, односно другим колективним уговором који се примењује код послодавца, при чему њихова примена треба да буде по редоследу да се најпре имају узети у обзир резултати рада, који се утврђују на основу учинка оствареног по нормативима и стандардима рада, за период од најмање годину дана. Ако они нису утврђени, резултати рада се утврђују на основу образложене оцене непосредног руководиоца засноване на квалитету обављања посла, самосталности у раду, иновацијама, ефикасности рада, односа према раду, задацима и средствима рада, дужини неплаћених одсустава, плана рада и других показатеља. Наведени закон садржи одредбе о томе да критеријум за утврђивање вишка запослених не може да буде одсуствовање запосленог са рада због привремене спречености за рад, трудноће, породичног одсуства, неге детета и посебне неге детета.

Наиме, Општи колективни уговор¹⁷, чије је важење истекло јер је његово важење било орочено на период од три године чл. 263. Закона о раду, којим је прописано да престаје да важи по истеку овог рока, у одредбама чл. 38. до 43. прописује да одређивање запослених за чијим је радом престала потреба врши надлежни орган послодавца, применом критеријума утврђених Законом и колективним уговорима. Критеријуми се примењују по редоследу утврђеним уговором. Резултати рада утврђују се на основу остварених учинака према утврђеним нормативима и стандардима рада. Ако код послодавца нису утврђени нормативи и стандарди, резултати рада се утврђују на основу образложене оцене непосредног руководиоца засноване на елементима: квалитета обављеног посла; самосталности у раду и иновација; с рада; односа према раду, радним задацима и средствима рада, као и дужини неплаћених одсуства, а везано за извршавање послова радног места, плана рада и других показатеља. Резултати рада утврђују се за период од најмање годину дана. Ако запослени остварују једнаке резултате рада, примењује се допунски критеријум: имовно стање запосленог. Имовно стање запосленог се утврђује на основу: 1. оствареног прихода по члану заједничког породичног домаћинства по основу зараде, других примања и прихода од имовине у последњој календарској години; 2. тржишне вредности непокретности коју у својини има запослени или

¹⁷ “Сл. гл. РС” бр. 50/08

члан његовог заједничког породичног домаћинства. Приход и тржишна вредност непокретности утврђује се на основу документације, односно исправа надлежног органа. Имовно стање запосленог утврђује надлежни орган послодавца. Предност има запослени са слабијим имовним стањем. Ако запослени остварују једнаке послове рада и имају једнако имовно стање, примењују се следећи критеријуми: 1. број чланова породице који остварују зараду, при чему предност има запослени са мањим бројем чланова породице који остварују зараду; 2. дужина радног стажа, при чему предност има запослени са дужим радним стажом; 3. здравствено стање запосленог и чланова његове уже породице, при чему предност има запослени, ако он или члан његове уже породице болује од тежег обољења, према налазу надлежног здравственог органа; 4. број деце на школовању, при чему предност има запослени који има више деце на школовању. Запосленој жени са дететом до 2. године живота, чији је укупан месечни приход по члану домаћинства до висине минималне зараде, не може престати радни однос по основу престанка потребе за њеним радом. Послодавац не може донети одлуку о престанку радног односа по основу вишка инвалиду рада који је инвалидност стекао радом код тог послодавца, без његове сагласности, као ни запосленом са одређеним годинама стажа осигурања утврђених посебним, односно колективним уговором код послодавца. Послодавац је дужан да запосленом исплати отпремнину у износу који не може бити нижи од 1/3 зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу, а која не може бити нижа од 50% просечне зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку надлежног органа за послове статистике, на дан исплате отпремнине, ако је то за запосленог повољније.

Примена одредби које се односе на исплату отпремнине привремено је одложена Анексом II Општег колективног уговора.

Посебан колективни уговор за државне органе¹⁸, измењен и допуњен Посебним колективним уговором за државне органе¹⁹ са Анексом Посебног колективног уговора за државне органе који се односи на права и обавезе из радног односа запослених у органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, чије је важење продужено Споразумом о про-

¹⁸ “Сл. гл. РС” бр. 95/2008

¹⁹ “Сл. гл. РС” бр. 11/09

дужењу рока важења²⁰ од 18.11.2011. године за рок од наредне три године, садржи одредбе које се односе на решавање вишка запослених у органима територијалне аутономије и локалне самоуправе. Тим одредбама из чл. 51., 52., 53. и 54. је прописано да је послодавац дужан да у поступку рационализације, односно смањења броја запослених прибави мишљење репрезентативног синдиката код послодавца, а он је дужан да размотри предлоге синдиката и да га обавести о свом ставу у року који не може бити дужи од 8 дана. У поступку рационализације, односно смањења броја запослених, послодавац је дужан да узме у обзир могућност: распоређивања на друге послове; преквалификације и доквалификације; рада са непуним радним временом али не краћим од половине радног времена; остваривања других права у складу са законом. Запосленом за чијим радом је престала потреба без његове сагласности, не може престати радни однос и то: запосленој трудници; запосленом за време породилског одсуства; запосленом за време одсуства са рада ради неге детета; запосленом за време одсуства са рада ради посебне неге детета; запосленом инвалиду; запосленом који је једини хранилац малолетног детета; запосленом који има дете теже ометено у развоју; запосленом мушкарцу са 40 и жени са 35 година пензијског стажа. Запосленом за чијим радом је престала потреба, пре престанка радног односа послодавац је дужан да обезбеди право на плаћено одсуство у трајању од 45 дана ради тражења новог запослења. У чл. 63. наведеног Посебног колективног уговора прописано је да запослени који је остао нераспоређен има право на отпремнину за сваку навршену годину рада у висини 1/3 просечне плате која му је исплаћена за последња три месеца који претходе месецу у којем је донето решење о утврђивању да је остао нераспоређен.

Заштита права запослених

Судска заштита у споровима о законитости одлука о стицању статуса нераспоређености и о престанку радног односа поводом примене Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији остварује се у поступку пред Основним судом. Тужба се подноси против решења општинске и градске управе ако запослени сматра да су наведене одлуке незаконите, а тужба садржи и захтев за поништај тих од-

²⁰ “Сл. гл. РС” бр. 86/2011

лука, захтев за враћање запослених на рад ако суд поништи решења послодавца. Могу се истаћи и други захтеви, новчана потраживања, чија је основаност условљена усвајањем основног захтева. Ако се тражи поништај наведених одлука, наведених органа, наведених јединица локалне самоуправе, тужена страна је општина или град чији су органи донели оспорено решење.

Када се ради о одлукама установа и привредних друштава или других облика организовања чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе, а који се финансирају из буџета, тужена страна је установа односно привредно друштво, односно јавна агенција ако се ради о таквом облику организовања ради обављања послова из делатности јединица локалне самоуправе.

Рок за подношење тужбе против одлука органа јединица локалне самоуправе, општине и градских општина, јесте рок од 15 дана из чл. 71. Закона о радним односима у државним органима. Међутим, ако су предмети спора захтеви за поништавање одлука осталих послодаваца из чл. 1. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији, тада се примењује рок за подношење тужбе из чл. 195. Закона о раду.

Последица пропуштања рока за подношење тужбе јесте губитак права на судску заштиту јер је преклузиван. Кад је поднета тужба изван наведеног рока суд је одбацује.

Запослени за чијим радом је престала потреба код послодавца, а стекао је статус нераспоређеног лица и према коме је донета одлука о престанку радног односа, који није задовољан тим одлукама мора захтевати оцену законитости и одлуке којом је утврђено да је нераспоређен јер је та одлука последица примене критеријума из Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији, који се узимају у смислу чл. 9. ст. 5. у поступку утврђивања статуса нераспоређеног у органима јединице локалне самоуправе и утврђивања да за радом запосленог престаје потреба у установи, привредном друштву и другом облику организовања. Пропуштање да се тужбом захтева оцена законитости те одлуке води оцени неоснованости тужбеног захтева за оцену законитости одлуке о престанку радног односа.

Будући да се о правима и обавезама запослених у органима јединице локалне самоуправе одлучује по правилима Закона о радним односима у државним органима из чл. 71., који предвиђа двостепеност поступка одлучивања, мора се захтевати тужбом и оцена законитости другостепене одлуке, ако је донета у року прописаном наведеним чланом, по приговору запосленог против првостепених одлука о нераспоређивању и о престанку радног односа, јер у противном не постоје законски услови за пружање судске заштите против одлуке која није коначна.

Судска пракса

У раду Основних судова са подручја Апелационог суда у Нишу и раду тог суда у радним споровима, у споровима о законитости одлука о статусу нераспоређености запослених код послодаваца из чл. 1. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији и одлука о престанку радног односа нераспоређеним лицима, приликом примене напред наведених прописа, они нису тумачени и примењивани на истоветан начин, због чега су доношене различите одлуке у истим чињеничним и правним ситуацијама.

Поједине општинске и градске управе су започеле решавање вишка запослених и пре ступања на снагу Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији, односно почетком 2009. године у сарадњи са Владом Републике Србије и упутствима председника општина и градоначелника старешинама наведених органа локалне самоуправе. Од старешина општинских и градских управа тражена је израда нових оптималних систематизација радних места, имајући у виду околности о броју и структури запослених, заинтересованих за коришћење социјалних програма. Сугерисано је да се код запослених за чијим је радом престала потреба руководе критеријумима о реалној потреби за поједина радна места, о оспособљености запослених за потребе савремене и ефикасне управе, да се имају у виду запослени који испуњавају макар један од услова за стицање права на пензију, запослени чији чланови породице раде у некој од институција које се финансира из општинског, односно градског буџета и који имају друге изворе прихода. Присутно је и то да се у тим упутствима захтева од старешина управа навођење разлога због чега се предлажу поједини запослени да им престане радни однос уз предлог

Правилника о новој систематизацији радних места. Код појединих општина нису постојала таква упутства.

Значајан број спорова је решаван одбачајем тужбе због прекорачења рока за њихово подношење, јер су подношене по протеклу рока од 15 дана из чл. 71. ст. 6. Закона о радним односима у државним органима.

У једном мањем броју радних спорова показало се да је у поступку решавања вишка запослених начелник општинске управе донео Правилник о систематизацији радних места у смислу чл. 2. ст. 6. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији, сачинио је листу запослених за чијим радом је престала потреба, донета је одлука о утврђивању статуса нераспоређених лица према листи, а након тога одлука о престанку радног односа уз признавање права на отпремнину према критеријумима из чл. 9. ст. 3. Закона уз предочавање да им припада право на новчану накнаду за случај незапослености у висини утврђеној у складу са прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености. Међутим, послодавац није пружио одговарајуће доказе у судском поступку да је пре доношења првостепених решења извршио оцену резултата рада тужилаца и других запослених по поступку у складу са Правилником општинске управе, нити је пружио доказе о оцени резултата рада и имовног стања по критеријумима који се примењују у складу са применом општих прописа о раду и на начин и у обиму који су утврђени у тим прописима. Ти критеријуми коришћени су у другостепеном поступку по приговору запослених против првостепеног решења о престанку радног односа, јер су утврђени у том поступку. Због тога су судови заузели правни став да општинска управа није спровела поступак утврђивања статуса нераспоређених запослених за чијим је радом престала потреба и складу са законом, јер је изостала примена предвиђених критеријума на основу којих се индивидуализује вишак запослених. Такав став је прихваћен од стране Врховног касационог суда.

У раду Апелационог суда у Нишу, односно првостепених судова са тог подручја, појавили су се и спорови у којима није тражена оцена законитости решења о утврђивању статуса нераспоређености већ је тражена само оцена законитости решења о престанку радног односа. У том случају је примењен став да су тужбе неосноване због пропуста да се захтева поништај решења о утврђивању статуса нераспоређености, будући да је та одлука донета након спроведених активности од стране по-

слодавца прописаних Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији, које претходе доношењу решења у смислу доношења акта у систематизацији радних места из чл. 2. ст. 6. и будући да је у чл. 9. ст. 1. и 2. јасно прописано да запослени који након ступања на снагу акта о систематизацији радних места остану нераспооређени остварују права у складу са прописима којима се уређују права запослених у органима јединице локалне самоуправе, односно право на отпремнину и права на новчану накнаду за случај незапослености. Међутим, било је и одлука у којима је изражен став да је без значаја околност што захтевом тужбе није тражена оцена законитости решења о стицању статуса незапосленог лица за оцену законитости одлуке о престанку радног односа.

У једном броју спорова су поништена решења послодавца због пропуста да поступак о утврђивању вишка запослених спроведе у складу са правилима из чл. 9. ст. 5. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији код утврђивања резултата рада и имовног стања по правилима о примени општих прописа о раду и на начин и у обиму који су утврђени у тим прописима, односно у складу са Општим колективним уговором из чл. 39. и 40. У том погледу судови су сматрали да је изостала образложена оцена резултата рада запослених од стране непосредног руководиоца, узимајући притом да је била потребна писана оцена и изостала је писана форма о примени допунског критеријума, имовног стања запослених уз прилагање доказа о документацији односно исправама надлежних органа на основу који би се могло на поуздан начин проверити да ли је правилно примењен наведен критеријум.

При решавању насталих спорова поводом примене закона, Апелациони суд је примењивао став да у случајевима када је актом о систематизацији дошло до укидања појединих послова или радних места са једним извршиоцем, послодавац није био дужан да врши оцену резултата рада запосленог који је обављао те послове и да утврђује његово имовно стање и имовно стање запослених за чијим радом није престала потреба, макар да је тај запослени имао боље резултате рада или је слабијег имовног стања у односу на оне запослене који су радили на пословима и радним задацима у оквиру радних места која нису укинута систематизацијом.

Када се ради о општинским и градским управама, имајући у виду карактер Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној

администрацији, да се ради о *lex specialisimus* и Закона о радним односима у државним органима да се ради о *lex specialis*, који не прописују обавезу послодавца на доношење програма за решавање вишка запослених, у смислу чл. 153. Закона о раду, притом имајући у виду правило да *lex specialis* има јачу правну снагу од *lex specialis* а *lex specialis* од *lex generalis* а матични Закон о раду јесте *lex generalis*, макар да се ради о смањењу броја запослених у мери и роковима који су прописани наведеном одредбом, наведеног закона, примењен је став да послодавац није обавезан да сачињава програм решавања вишка запослених.

Међутим, кад се ради о послодавцима које представљају у смислу чл. 1. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији установе које се финансирају из буџета и привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе, осим јавних предузећа, а који се финансирају из буџета, у решавању спорова о законитости решења о утврђивању статуса нераспоређених и о престанку радног односа, сами послодавци су приликом решавања вишка запослених сачињавали програме решавања вишка запослених у складу са одредбама из чл. 153. до 160. Закона о раду када се испостави да ће због организационих или економских промена доћи до престанка потребе за радом запослених на одређено време у временским периодима и у броју који су опредељени одредбама из чл. 153. наведеног закона, будући да се ради о послодавцима код којих се на запослене примењује наведени закон, односно Општи колективни уговор или Посебни колективни уговори за поједине области, односно установе. Ако се не ради о случају из чл. 153. Закона о раду тада су примењивани ставови који се примењују и за смањења броја запослених до укупног максималног броја запослених прописаног законом код општинских и градских управа.

Присутна је и дилема о примени одредбе чл. 54. Посебног колективног уговора за државне органе којим је утврђена обавеза послодавца да запосленом за чијим радом је престала потреба, пре престанка радног односа обезбеди право на плаћено одсуство у трајању од 45 дана ради тражења новог запослења.

Одлуке судова

Правни став Апелационог суда у Нишу изражен у пресуди Гж. 1. бр. 2271/11 од 23.11.2011 године и подржан у пресуди Врховног касационог суда Рев. 2. бр. 41/12 од 21.06.2012. године:

„На спорни материјално правни однос примењује се као меродавно материјално право Закон о радним односима у државним органима ("Сл. гл. РС", бр. 48/91. . . 79/2005) који у чл. 71. прописује остваривање и заштиту права запослених и постављених лица у органима локалне самоуправе. Одредбама овог члана прописано је да се запослени у државном органу, односно постављена лица ради остваривања својих права писмено обраћају функционеру који руководи органом и да против сваког решења или другог акта којим је одлучено о њиховим правима и обавезама имају право да поднесу приговор функционеру који руководи државним органом у року од 8 дана од дана уручења решења или другог акта, а функционер је дужан да о приговору одлучи у року од 15 дана од дана подношења приговора. Ако функционер у утврђеном року не одлучи о поднетом приговору или ако запослени или постављено лице није задовољан одлуком функционера поводом поднетог приговора, запослени, односно постављено лице могу се обратити надлежном суду у року од 15 дана. У конкретном случају, тужилац је тужбом од 17.03.2010. године тражио поништај првостепених решења и то решења о нераспоређивању од 16.02.2010. године и решења о престанку радног односа од 01.03.2010. године, која не представљају коначне одлуке туженика да би против истих, у смислу напред цитираног законског прописа тужилац имао право на судску заштиту.

Допуном тужбе која је поднета 02.06.2010. године, тужилац је тражио и поништај другостепене одлуке којом је одбијен приговор на решење о нераспоређивању од 04.03.2010. године, не тражећи поништај другостепене одлуке о престанку радног односа тужиоца, па произилази да је ова тужба недовољна, јер је од дана пријема овог решења, до подношења тужбе протекао законски рок од 15 дана.

Имајући у виду утврђено чињенично стање и наведено материјално право, правилно је првостепени суд поступио када је одбацио као недозвољену тужбу за поништај првостепених решења од 16.02.2010. године о нераспоређивању тужиоца и од 01.03.2010. године о престанку

радног односа, а тужбу за поништај другостепеног решења од 04.03.2010. године, поводом приговора на решење о нераспоређивању, одбацио као неблаговремену.

Рев. 2. бр. 41/12 од 21.06.2012. године: „На основу тако утврђеног чињеничног стања, нижестепени судови су правилном применом материјалног права одлучили тако што су тужбу тужиоца од 17.03.2010. године за поништај првостепених решења туженог одбацили као недозвољену, а тужбу од 02.06.2010. године за поништај другостепеног решења од 04.03.2010. године, којим је одлучено о приговору на решење којима је утврђен статус тужиоца као нераспоређеног радника, одбацили као неблаговремену.

У конкретном случају примењују се одредбе Закона о радним односима у државним органима и то чл. 71. којим је прописано да против сваког решења или другог акта којим је одлучено о његовим правима и обавезама, запослени, односно постављено лице има право да поднесе приговор, који се подноси функционеру који руководи државним органом у року од 8 дана од дана уручења решења или другог акта, функционер је дужан да о њему одлучи у року од 15 дана од дана подношења приговора, с тим да ако функционер у утврђеном року не одлучи о поднетом приговору или ако запослени, односно постављено лице није задовољио одлуком функционера поводом поднетог приговора, запослени, односно постављено лице може се обратити надлежном суду у року од 15 дана. Из наведеног произлази да предмет судског спора у циљу заштите повређеног права запосленог може бити само коначна одлука туженог, односно пред судом се може тражити оцена законитости само коначне одлуке. Стога је правилно становиште нижестепених судова да тужба против првостепених решења туженог и то тужба поднета 17.03.2010. године за поништај решења којим је утврђен статус тужиоца као нераспоређеног радника од 16.02.2010. године и решења о престанку радног односа од 01.03.2010. године, није дозвољена, па је стога правилно одбачена.

Допуном тужбе од 02.06.2010. године тужилац је тражио и поништај другостепене одлуке којом је одбијен приговор на решење којим је утврђен статус нераспоређеног радника, које је донето 04.03.2010. године. Имајући у виду рок прописан чл. 71. Закона о радним односима у државним органима, у којем се радник може обратити суду за заштиту својих права, као и неспорну чињеницу да је решење од 04.03.2010. године,

тужилац примио дана 05.03.2010. године, а допуњу тужбе поднео 02.06.2010. године, правилно су нижестепени судови овај захтев тужиоца одбацили као неблаговремен, обзиром да је поднет по протеклу рока прописаног законом“.

О томе се у пресуди Врховног касационог суда Рев. 2. бр. 208/12 од 07.06.2012. године наводи:

„Наиме, према чл. 71. ст. 2. Закона о радним односима у државним органима ("Сл. гл. РС", бр. 48/91), против сваког решења или другог акта којим је одлучено о његовим правима и обавезама, запослени, односно постављено лице, има право да поднесе приговор. Према чл. 71. ст. 6. истог закона, ако функционер у утврђеном року, не одлучи о поднетом приговору или ако запослени или постављено лице није задовољно одлуком функционера поводом поднетог приговора, запослени, односно постављено лице се може обратити надлежном суду у року од 15 дана.

Тужбом поднетом 17.03.2010. године тужилац није обухватио другостепену одлуку о престанку радног односа, која му је била уручена 16.03.2010. године, нити другостепену одлуку о нераспоређивању, која му је била уручена 09.03.2010. године.

Тужилац је тужбом од 17.03.2010. године тражио поништај првостепених решења и то решења о нераспоређивању од 16.02.2010. године, која решења не представљају коначне одлуке туженог, да би против истих тужилац имао право на судску заштиту. Ово стога што је одредбама чл. 71. ст. 2. наведеног закона предвиђена двостепеност поступка одлучивања, па су правилно нижестепени судови применили материјално право када су закључили да не постоје законски услови за пружање судске заштите против одлуке која није коначна.

Допуном тужбе од 02.06.2010. године, тужилац је тражио поништај другостепеног решења којим је одлучено о приговору изјављеном на решење о престанку радног односа, коју одлуку је примио 16.03.2010. године. Како је тужилац пропустио законски рок од 15 дана за обраћање суду према чл. 71. ст. 6. наведеног Закона, како је гласила и поука о правном леку из другостепене одлуке, преиначена тужба је правилно одбачена као неблаговремено поднета“.

У пресуди Апелационог суда у Нишу Гж. 1. бр. 616/11 од 11.05.2011. године наводи се:

„Правилна је оцена првостепеног суда да првостепени орган није имао у виду оцену рада тужиоца и његово имовно стање, те оцену рада других запослених и њихово имовно стање, у тренутку доношења оспореног првостепеног решења, јер то решење не садржи разлоге о наведеним околностима. Разлоге о томе садржи другостепено решење, што указује да је наведене околности имао у виду другостепени орган.

Правилима из чл. 9. ст. 1. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији прописано је да запослени у органима јединица локалне самоуправе који након ступања на снагу акта о систематизацији радних места из чл. 2. ст. 6. Закона остану нераспоређени остварују права у складу са прописима којима се уређују права запослених у органима јединица локалне самоуправе. У поступку утврђивања статуса нераспоређеног запосленог у органу јединице локалне самоуправе и утврђивања да за радом запосленом престаје потреба у установи, привредном друштву и другом облику организовања у обзир се узимају резултати рада и имовно стање, у складу са применом општих прописа о раду и на начин и у обиму који су утврђени у тим прописима.

Општинска управа тужене општине није провела поступак утврђивања статуса нераспоређених запослених у том органу за чијим радом је престала потреба у складу са критеријумима који су прописани цитираним материјалним правом, будући да првостепени орган није имао у виду резултате рада и имовно стање тужиоца и осталих запослених код утврђивања њиховог статуса приликом доношења првостепеног решења, а без значаја су чињенице да су ти критеријуми утврђени у поступку по приговору тужиоца против првостепеног решења, јер је одлука по приговору морала бити донета само на бази околности које су постојале у време доношења првостепеног решења, односно на којима је засновано првостепено решење“.

У пресуди Врховног касационог суда Рев. 2. бр. 967/11 од 04.05.2011. године наводи се:

„Са становишта овог суда, правилан је закључак нижестепених судова, да општинска управа тужени није спровела поступак утврђивања статуса нераспоређених запослених у том органу за чијим радом је

престала потреба, да је изостала примена предвиђених критеријума на основу којих се индивидуализује вишиак запослених (оцена резултата рада и имовно стање запослених), па како првостепени орган није имао у виду резултате рада и имовно стање тужиоца и осталих запослених код утврђивања њиховог статуса приликом доношења првостепеног решења, без значаја је чињеница да су ти критеријуми утврђени у поступку по приговору тужиоца. Пре свега, што одлука по приговору је морала бити донета само на основу чињеница које су постојале у време доношења првостепеног решења“.

Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж. 1. бр. 1080/12 од 04.07.2012. године садржи следеће разлоге:

„Одредбом из чл. 9. ст. 5. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Сл. гл. РС“, бр. 104/2009) прописано је да се у поступку утврђивања статуса нераспоређеног запосленог у органу јединице локалне самоуправе и утврђивања да за радом запосленог престаје потреба у установи, привредном друштву и другом облику организовања у обзир се узимају резултати рада и имовно стање, у складу са применом општих прописа о раду и на начин и у обиму који су утврђени у тим прописима.

Општи прописи о раду у смислу наведене одредбе, наведеног Закона, представљају Закон о раду и Општи колективни уговор („Сл. гл. РС“, бр. 50/2008 до 8/2009). Закон о раду решавање вишка запослених регулише одредбама из чл. 153. до 160. Међутим, не садржи ближе одредбе о критеријумима који се узимају у поступку утврђивања статуса нераспоређеног запосленог и утврђивања да за радом запосленог престаје потреба. Одредбе тог законског прописа упућују на Програм решавања вишка запослених који мора да садржи критеријуме за утврђивање вишка запослених. Општи колективни уговор у одредбама од чл. 38. до 42. прописује критеријуме који се примењују код одређивања запослених за чијим је радом престала потреба. Чланом 38. наведеног уговора прописано је да одређивање запослених за чијим је радом престала потреба врши надлежни орган послодавца, применом критеријума утврђених Законом и Колективним уговорима. Критеријуми се примењују по редоследу утврђеним Општим колективним уговором. Одредбама из чл. 39. Општег колективног уговора прописано је да се резултати рада утврђују на основу остварених учинака према утврђеним нормативима и стандардима рада. Ако код послодавца нису

утврђени нормативи и стандарди, резултати рада се утврђују на основу образложене оцене непосредног руководиоца засноване на елементима: квалитета обављеног посла; самосталности у раду и иновација; ефикасности рада; односа према раду, радним задацима и средствима рада, као и дужини неплаћених одсустава, а везано за извршавање послова радног места, плана рада и других показатеља. Резултати се утврђују за период од најмање годину дана. Према одредбама из чл. 40. Општег колективног уговора, ако запослени остварују једнаке резултате рада, примењује се допунски критеријум. Имовно стање запосленог се утврђује на основу: оствареног прихода по члану заједничког породичног домаћинства по основу зараде, других примања и прихода од имовине у последњој календарској години; тржишне вредности непокретности коју у својини има запослени или члан његовог заједничког породичног домаћинства. Приход и тржишна вредност непокретности утврђује се на основу документације, односно исправа надлежног органа. Имовно стање запосленог утврђује надлежни орган послодавца. Предност има запослени са слабијим имовним стањем. Одредбама чл. 41. наведеног уговора је прописано да ако запослени остварује једнаке резултате рада и имају једнако имовно стање, примењују се следећи критеријуми: број чланова породице који остварују зараду, при чему предност има запослени са мањим бројем чланова породице који остварују зараду; дужина радног стажа, при чему предност има запослени са дужиим радним стажом; здравствено стање запосленог и чланова његове уже породице, при чему предност има запослени, ако он или члан његове уже породице болује од тежег обољења, према налазу надлежног здравственог органа; број деце на школовању, при чему предност има запослени који има више деце на школовању. Запосленој жени са дететом до 2 године живота, чији је укупан месечни приход по члану домаћинства до висине минималне зараде, не може престати радни однос по основу престанка потребе за њеним радом.

Прописи на које упућује чл. 38 ст. 1. Општег колективног уговора, у овом случају, јесу Закон о радним односима у државним органима („Сл. гл. РС“, бр. 70/2001 са изменама и допунама), који се у смислу чл. 189. Закона о државним службеницима („Сл. гл. РС“, бр. 79/05 са изменама и допунама) почев од 01.07.2006. године примењује на радне односе у органима аутономне покрајине и локалне самоуправе до доношења посебног закона, а који престанак радног односа, и права по престанку радног од-

носа запослених у државним органима и изабраних односно постављених лица регулише одредбама из чл. 64 до 70. као и Посебан колективни уговор за државне органе („Сл. гл. РС“, бр. 95/2008), измењен и допуњен Посебним колективним уговором за државне органе („Сл. гл. РС“, бр. 11/09), са Анексом Посебног колективног уговора за државне органе који се односи на права и обавезе из радног односа запослених у органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, чије је важење продужено Споразумом о продужењу рока важења који је објављен у („Сл. гл. РС“, бр. 86/2011). Одредбе из чл. 65. и 66. наведеног закона прописују да запослени у државним органима, односно постављена лица, који су остали нераспоређени на начин утврђен у члану 65. овог закона, односно након ступања на снагу новог акта о систематизацији радних места у смислу чл. 9. ст. 1. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији из чл. 2. ст. 6. тог закона, имају иста права и обавезе као и запослени за чијим је радом престала потреба у предузећима, утврђена законом, што даље подразумева да им припада право на отпремнину и на новчану накнаду за случај незапослености по прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености, а према критеријумима из чл. 9. ст. 3. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији из чега даље произилази да се не примењује одредба чл. 65. Закона о радним односима у државним органима. Посебан колективни уговор из 1998. године не садржи посебне одредбе у вези са критеријумима из чл. 9. ст. 5. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији, а наведеним одредбама тог закона, искључена је примена чл. 51., 52., 53. и 54. наведеног Посебног колективног уговора, јер је у ставу 5. члана 9. Закона прописано да у поступку утврђивања статуса нераспоређеног запосленог у органу јединице локалне самоуправе и утврђивања да за радом запосленог престаје потреба у установи, привредном друштву и другом облику организовања у обзир се узимају само резултати рада и имовно стање, у складу са применом општих прописа о раду и на начин и у обиму који су утврђени у тим прописима. Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији, када се ради о одредбама које регулишу утврђивање статуса нераспоређеног запосленог у органу јединице локалне самоуправе и утврђивање да за радом запосленог престаје потреба у установи, привредном друштву и другом облику организовања и с тим у вези када се ради о одредбама о престанку радног односа запосленима и о правима у вези са престанком рад-

ног односа, има карактер *lex specialisimus* у односу на Закон о раду, Закон о радним односима у државним органима представља *lex specialis* у односу на тај закон, док је матични Закон о раду *lex generalis*, што подразумева да *lex specialisimus* има јачу правну снагу у односу *lex specialisa* а *lex specialis* од *lex generalisa*.

Према томе произилази, да критеријуме за оцену битне околности да ли је тужиоцу престао радни однос у складу са наведеним материјалним правом, није утврдио тужени послодавац на начин како је прописано цитираним законским прописима и општим прописом о раду, јер је изостала писана, образложена оцена непосредног руководиоца тужиоца о његовим резултатима рада и резултатима рада осталих извршилаца послова на којима је радио тужилац до доношења оспорених одлука, на бази података и чињеница и доказа које је тужени понудио суду. Исто тако, недостаје писмена форма о доказима и о начину утврђивања имовног стања тужиоца и имовног стања осталих запослених који су радили на истим пословима или сличним које је обављао тужилац до доношења оспорених одлука“.

У пресуди Апелационог суда у Нишу Гж. 1. бр. 1161/11 од 09.06.2011. године је наведено:

„ У списима су садржане околности да је тужени поступајући у складу са обавезама из Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Сл. гл РС, бр. 104/2009), који се односи на запослене у установама које се финансирају из буџета , у које спадају домови културе , најпре донео нови Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака бр. 236/08 дана 09.12.2008. године, којим је регулисао унутрашњу организацију и систематизацију послова и радних задатака у дому културе „Вучје“ и утврдио број носиоца послова и радних задатака, те врсту стручне спреме која је потребна за извршавање послова и радних задатака на сваком од предвиђених радних места. За послове организатора културних манифестација где су разврстани послови васпитно образовног карактера грађана предвиђена су три извршиоца са средњом, вишом или високом стручном спремом друштвеног смера, што подразумева да нису посебно систематизовани послови које је тужилац обављао у тренутку када му је отказан уговор о раду.

Првостепени суд је правилно поступио, правилно применивши материјално право, правила наведеног закона, када је побијаним решењем отказа уговора о раду тужиоцу, имајући у виду и околност да је пре отказа уговора о раду послодавац поступио у складу са чл. 9 ст. 1. цитираног закона, јер је тужиоцу као нераспоређеном лицу утврдио права која му припадају по закону. Утврдио је права на отпремнину и извршио исплату отпремнине, прихватио обавезу да тужиоцу изврши исплату неисплаћених зарада и других новчаних накнада и примања која му по закону припадају и утврдио постојање права на новчану накнаду за случај незапослености, чији се обим има одредити по прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености.

Нису од важности околности које се истичу жалбом да је поступак одређивања запослених за чијим радом је престала потреба спроведен супротно правилима Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији, јер није поштовао критеријуме прописане тим законом, будући да новом систематизацијом послова и радних задатака приликом прописивања услова које извршиоци тих послова морају испуњавати у погледу висине и врсте стручног образовања, није предвиђена могућност обављања послова предвиђених новим правилником који се обављају код туженог са стручном спремом са којом располаже тужилац, јер природа тих послова изискује да извршиоци морају располагати стручном спремом из области тзв. друштвених грана науке. С тим у вези, послодавац није био у обавези да код утврђивања листе запослених за чијим радом је престала потреба има у виду критеријуме из чл. 9. ст. 5. наведеног закона“.

Пресуда Врховног касационог суда Рев. 2. бр. 819/11 од 17.05.2012. године о томе садржи следеће разлоге:

„Нижестепени судови су правилном применом материјалног права донели одлуку којом су одбили као неоснован тужбени захтев тужиоца за поништај решења о отказу уговора о раду. Чланом 3. ст. 6. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији прописано је да уколико је број запослених на неодређено време у локалној администрацији већи је од максималног броја запослених усвајањем акта о систематизацији радних места до 31.12.2009. године, број запослених може се смањити до максималног броја запослених, а чл. 9. ст. 2. истог Закона, да запосленима у локалној администрацији за чијим радом пре-

стаје потреба након ступања на снагу аката о систематизацији радних места, исплаћује се отпремнина и отказује уговор о раду у складу са законом. Неспорно је да је тужени донео Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака, дана 24.12.2009. године, у поступку прописаним Законом. Овим Правилником укинута су послови које је тужилац обављао до његовог доношења, а како исти не испуњава услове за обављање послова организатора културних манифестација ни по струци ни по дужини радног искуства, то је у таквој ситуацији тужени правилно поступио када је донео решење о отказу уговора о раду. У свему је поступио у складу са одредбама чл. 179. ст. 1. тач. 9. Закона о раду, ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређених послова или дође до смањења обима посла. У конкретном случају дошло је до организационих промена када је престала потреба за пословима које је обављао тужилац, а поступљено је и у складу са чл. 158. истог Закона јер му је исплаћена отпремнина“.

Поводом примене Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији у пресуди Апелационог суда у Нишу Гж. 1. бр. 908/12 од 20.06.2012. године је наведено:

„Правилно је првостепени суд поступио када је усвојио тужбени захтев тужиоца оценивши да је тужени приликом доношења оспорених решења учинио пропуст везан за поступак приликом доношења истих. Поступак оцене успешности у раду тужиоца није спроведен у складу са важећим правним актима и законском регулативом, при чему су примењивани и критеријуми који нису прописани ниједним законским нити интерним актом туженог.

Како би поступак спровела у складу са прописима, тужена Градска управа је најпре требала да утврди број запослених на неодређено време и број запослених који представља вишак запослених према критеријумима из Закона о одређивању броја запослених у локалној администрацији. Тек након тога је требало да буде донет Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места а потом на основу критеријума утврђених Општим колективним уговором (чл. 38-42, "Сл. гл. РС", бр. 8/09) утврдио ко је од радника постао нераспоређен услед промена у организацији у општинској управи, због чега је престала потреба за његовим радом, након чега се доноси решење о престанку рад-

ног односа са правом на отпремнину, зараде, накнаде зараде и других примања која му нису исплаћена до дана престанка радног односа.

Пре доношења првостепеног решења тужени је требало да изврши оцену резултата рада тужиоца и других запослених, али не паушално, већ у складу са поступком који је прописан Правилником Општинске управе тужене Општине, а на основу чл. 10. Закона о одређивању броја запослених у локалној самоуправи.

С обзиром да је тужена приликом доношења оспорених решења поступила супротно напред наведеним законским одредбама и одредбама Општег колективног уговора и Појединачног колективног уговора, оспорена решења су од стране првостепеног суда правилно оцењена као незаконита.

Тужена током спора није пружала нити један доказ за своје наводе у погледу правилности поступка оцењивања успешности у раду запослених, нити је пружила доказ о томе на основу којих критеријума је вршено оцењивање, а уколико својим интерним актом није утврдила критеријуме на основу којих ће се вршити ова оцена била је у обавези да спроведе поступак и примени критеријуме из општег колективног уговора (чл. 38-41.), као што је напред објашњено у ком делу примена општег колективног уговора из 2008. године, није одложена.

Чланом 38. наведеног ОКУ, прописано је да одређивање запослених за чијим је радом престала потреба, врши надлежни орган послодавца, применом критеријума утврђених законом и колективним уговорима. Критеријуми се примењују по редоследу утврђеним овим колективним уговором.

Чланом 39. прописано је да се резултати рада утврђују на основу остварених учинака према утврђеним нормативима и стандардима рада. Ако код послодавца нису утврђени нормативи и стандарди, резултати рада се утврђују на основу образложене оцене неспорног руководиоца засноване на елементима: квалитета обављеног посла; радним задацима и средствима рада као и дужини неплаћених одсуства, а везано за извршење послова радног места, плана рада и других показатеља. Ови резултати утврђују се за период од најмање годину дана.

Чланом 40. је прописано да се, ако запослени остварују једнаке резултате рада, примењује допунски критеријум и то имовно стање запосленог, а у случају ако запослени остварују једнаке резултате рада и имају једнако имовно стање, примењују се додатни допунски критеријуми из чл. 41. ОКУ, број чланова породице који остварују зараду, дужина радног стажа, здравствено стање запосленог и чланова његове уже породице, број деце на школовању уз посебне услове.

Поред тога, тужена није могла да примењује критеријуме утврђене на основу мишљења, препоруке или заузетог става њених органа, уколико исти нису прописани законом, колективним уговором или неким другим интерним актом тужене“.

Правно схватање поводом примене истог закона изражено је у пресуди Апелационог суда Гж. 1. бр. 1624/11 од 07.12.2011. годне, а које је прихваћено пресудом Врховног касационог суда Рев. 2. бр. 173/12 од 20.06.2012. године:

„Међутим, због погрешне примене материјалног права о чему овај суд води рачуна по службеној дужности у смислу чл. 372. ЗПП закључак првостепеног суда о основаности тужбеног захтева се не може прихватити, због чега је првостепена пресуда морала бити преиначена.

Одредбом чл. 71. Закона о радним односима у државним органима ст. 6. прописано је да ако функционер у утврђеном року не одлучи о поднетом приговору или ако запослени или постављено лице није задовољан одлуком функционера поводом поднетог приговора запослени односно постављено лице може се обратити надлежном суду у року од 15 дана.

Предмет тужбеног захтева је да се утврди да је незаконито првостепено решење о нераспоређивању и првостепено решење о престанку радног односа.

Против наведених одлука туженог тужилац је изјавио приговоре и по приговору на решење о престанку радног односа донета је другостепена одлука којом је приговор тужиоца одбијен као неоснован. У тој одлуци дата је и поука о правном леку да против тог решења запослени има право да се обрати надлежном Основном суду у Лесковцу у року од 15 дана од дана пријема решења. Дакле у конкретном случају овом судском поступку претходио је поступак одлучивања о изјављеном проговору након

чега је донета коначна одлука о престанку радног односа која у себи конзумира првостепену одлуку, па се законитост одлуке о престанку радног односа оцењује са становишта првостепене и са становишта другостепене одлуке. С тога предмет тужбеног захтева у спору о законитости престанка радног односа треба да буде првостепена и другостепена одлука. Како поводом поднетог приговора на одлуку о престанку радног односа, то се није могло приступити оцени законитости другостепене одлуке као коначне па из изнетих разлога је тужбени захтев тужιοца да се утврди да је незаконито решење којим му је престао радни однос неоснован. С тим у вези неоснован је и захтев за поништај решења о нераспоређивању, због чега је првостепена пресуда морала бити преиначена у смислу одбијање тужбеног захтева“.

У пресуди Врховног касационог суда Рев. 2. бр. 173/12 од 20.06.2012. године је наведено:

„Полазећи од утврђеног чињеничног стања, по налажењу овог суда, правилан је закључак другостепеног суда, када је преиначио првостепену пресуду и одбио тужбени захтев тужιοца.

Наиме, из разлога, што у овој парници тужилац није тражио поништај другостепене одлуке поводом поднетог приговора на одлуку о престанку радног односа, па се није могла ни ценити законитост другостепене одлуке туженог као коначне, због чега је тужбени захтев тужιοца да се утврди да је оспореним решењем, којим је престао радни однос неоснован, као и захтев за поништај решења о нераспоређивању, у смислу одредби чл. 71. Закона о радним односима у државним органима („Сл. гл. РС“ бр. 48/91. . . 79/05), који се примењује на радне односе у органима аутономне покрајине и локалне самоуправе до доношења посебног закона.

Према томе, неосновано се ревизијом побија пресуда, због погрешне примене материјалног права“.

Решењем Апелационог суда у Нишу Гж. 1. бр. 907/12 од 15.06.2012. године заузет је правни став:

„ На основу утврђеног чињеничног стања, првостепени суд налази да је тужбени захтев тужιοца неоснован, јер против решења којем је остао нераспоређен тужилац није тражио судску заштиту и да му је ис-

плаћена отпремнина у складу са чл. 66. Закона о радним односима у државним органима.

Међутим, овакав закључак првостепеног суда се не може прихватити, јер се заснива на непотпуно утврђеном чињеничном стању, обзиром да је изостало утврђење релевантних чињеница од којих зависи правилна примена материјалног права.

Одредбом чл. 1. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Сл. гл. РС“, бр. 104/2009) прописано је да се овим законом одређује укупан максималан број запослених у органима јединица локалне самоуправе (укључујући и органе градских општина), установама које се финансирају из буџета (осим установа у области образовања, здравства и предшколских установа), привредним друштвима и другим облицима организације чији је једини оснивач јединице локалне самоуправе (осим јавних предузећа), а који се финансирају из буџета.

Сходно одредби чл. 9. ст. 1. истог Закона запослени у органима јединица локалне самоуправе који након ступања аката о систематизацији радних места из чл. 2. ст. 6. наведеног Закона постану нераспоређени остварују права у складу са прописима, којима се утврђује право запослених у органима јединица локалне самоуправе, а ст. 5. истог члана прописано је да у поступку утврђивања статуса нераспоређеног запосленог у органу јединице локалне самоуправе и утврђивања да за радом запосленог престаје потреба у установи, привредном друштву и другом облику организације у обзир се узимају резултати рада и имовно стање, у складу са применом општих прописа о раду и на начин и у обиму који су утврђени у тим прописима.

За сада се не може прихватити као правилан закључак првостепеног суда да је тужбени захтев тужиоца неоснован само из разлога што тужилац у судском поступку није тражио поништај решења којим је остао нераспоређен и што му је исплаћена отпремнина, јер је првостепени суд требао да са становишта правилне примене Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији и одговарајућих одредаба Посебног колективног уговора за запослене у државним органима, који се примењује и на запослене у локалној самоуправи, које регулишу вишак запослених да цени законитост побијаног решења“.

Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж. 1. бр. 909/12 од 06.07.2012. године садржи правно схватање:

„Неосновано се жалбом указује и на примену чл. 54а анекса Посебног колективног уговора за државне органа. Наиме, Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији у одредби чл. 9. прописано је да се у поступку утврђивања статуса нераспоређеног запосленог у органу јединице локалне самоуправе и утврђивања да за радом запосленог престаје потреба у установи у обзир се узимају само резултати рада и имовно стање. Одредбом чл. 54. Анекса Посебног колективног уговора за државне органе прописано је да су учесници сагласни да се запосленом за чијим радом је престала потреба, пре престанка радног односа обезбеди право на плаћено одсуство у трајању од 45 дана ради тражења новог запослења.

Како Посебан колективни уговор не садржи посебне одредбе у вези са критеријумима из чл. 9. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији, то произилази да је искључена примена Посебног колективног уговора и Закона о радним односима у поступку утврђивања статуса нераспоређеног запосленог у органу јединице локалне самоуправе и утврђивања да је за радом запосленог престала потреба у установи, привредном друштву и другом облику организовања. У таквој чињеничној и правној ситуацији, непоступање тужене онако како је то предвиђено чл. 45. Анекса Посебног колективног уговора за државне органе, не чини наведено решење незаконитим а ова околност да тужили није омогућено коришћење 45 дана плаћеног одсуства ради тражења новог запослења, може евентуално бити од значаја за остваривање неког другог права, па су жалбени наводи тужиле неосновани у целисти и у том делу“.

У пресуди Апелационог суда у Нишу Гж. 1. бр. 782/12 од 16.05.2012. године је наведено:

„Оснивање и престанак јавних агенција уређен је Законом о јавним агенцијама („Сл. гл РС“, бр. 18/2005 и 81/2005). Правилима наведеног закона прописано је да, осим Републике Србије, јавне агенције могу оснивати и аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, ако су на то овлашћене својим општим актом и кад су испуњени услови за оснивање утврђени овим законом. Оне могу јавној агенцији поверити послове из свог изворног

делокруга који по врсти и природи одговарају пословима државне управе које јавним агенцијама може поверити Република Србија. Послови државне управе који су поверени јавној агенцији финансирају се из буџета оснивача. Јавна агенција одговара за своје обавезе свом својом имовином, а оснивач одговара за њене обавезе ако их не може испунити из своје имовине или ако би испуњење обавеза из имовине јавне агенције озбиљно угрозило њен рад. Јавна агенција престаје да ради ако буде укинута или се правноснажном судском одлуком утврди ништавост њеног уписа у судски регистар. Она може бити укинута и услед престанка сврхе због које је основана или ако неки други организациони облик може делотворније, рационалније и економичније да задовољи сврху јавне агенције. Одлуку о укидању доноси оснивач, на основу овлашћења у посебном закону.

Посебним законом, Законом о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС", бр. 129/07), регулисано је, поред осталог, да је град јединица локалне самоуправе и да врши надлежност општине као и друге надлежности и послове државне управе, који су му законом поверени, а поред осталих надлежности општина, град преко својих органа, у складу са уставом и законом, стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења, утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда и спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама.

Правилима Закона о привредним друштвима ("Сл. гл. РС", бр. 125/04), који је примењиван у време доношења оспорених решења, регулисана је ликвидација привредног друштва. Међутим, та правила се примењују и на поступак ликвидације правних лица, а што подразумева и поступак ликвидације установа, односно јавних служби, односно јавних агенција и других пословних и правних лица, према којима се у смислу правила Закона о стечају („Сл. гл. РС“, бр. 104/2009 и 99/2011) не спроводи стечајни поступак, а тај поступак се не спроводи у смислу чл. 14 наведеног закона нити према јавним агенцијама. Ставом 3. наведене одредбе, наведеног закона, за обавезе правног лица над којим се у складу са ставом 1. тог закона не спроводи стечајни поступак солидарно одговарају његови оснивачи, односно власници, као чланови или акционари.

Одредбама Закона о раду из чл. 176. ст. 1. тач. 5. прописано је да запослено престаје радни однос независно од његове воље и воље послодавца и у случају престанка рада послодавца, у складу са законом. Одред-

бама тог закона из чл. 147 до 152. на које се позива жалба тужилаца, регулисана су права запослених код промене послодавца. Поред осталог, прописано је да у случају статусне промене, односно промене послодавца, у складу са законом, послодавац следбеник преузима од послодавца претходника општи акт и све уговоре о раду који важе на дан промене послодавца. Те одредбе се примењују и у случају промене власништва над капиталом привредног друштва и другог правног лица.

Имајући у виду утврђено чињенично стање и наведено материјално право, произилази да је правилна оцена првостепеног суда да тужени град нема пасивну легитимацију за учешће у овој парници. Околности о томе да су оспорена решења донета од стране директора Стамбене агенције, да се не може сматрати према до сада изграђеној судској пракси Врховног суда и Врховног касационог суда и трговинских и привредних судова да се престанак правног лица везује за закључење поступка ликвидације према њему, а не за тренутак ступања на снагу одлуке о престанку или укидању донете од стране оснивача, односно да се престанак страначке способности одређује према тренутку брисања ликвидационог дужника из судског регистра, произилази да су тужιοици парницу за оцену законитости предметних решења на основу којих им је престао радни однос могли покренути против Стамбене агенције која је уписана као правни субјекат у ликвидацију у судском регистру надлежног Привредног суда и да се њихов радно правни статус разреши за време трајања ликвидационог поступка против наведене јавне агенције.

Оваква оцена произилази из наведених одредби, наведеног Закона о раду, јер према чл. 176 ст. 1 тач. 5. наведеног закона сматра се да се ради о престанку радног односа услед престанка рада послодавца због престанка његовог правног субјективитета који је утврђен у поступку по правилима Закона о стечају, када се ради о привредним друштвима, односно који је утврђен у поступку ликвидације када се ради о правним лицима против којих је изузето спровођење стечајног поступка у смислу чл. 14. ст. 3. наведеног закона. На основаност такве оцене указује и чињеница да је поступак ликвидације уређен Законом о привредним друштвима и да одредбе тог закона не садрже правила о решавању радно правног статуса запослених код правних лица према којима је отворен ликвидациони поступак, због чега се морају применити наведене одредбе Закона о раду из чл. 176. тач. 5.

Насупрот наводима жалбе, нема места примени одредби Закона о раду на које се указује жалбом, јер се у овом случају не ради о статусним променама, односно промени послодавца, будући да се у смислу чл. 147. тог закона под статусном променом подразумева спајање, подела или одвајање послодавца, промена правне форме његовог пословања и промена власништва над капиталом послодавца, а све те промене се односе углавном на привредна друштва, при чему се преузимање средстава којима је располагала Стамбена агенција у тренутку закључења поступка ликвидације према њој од стране оснивача, овде туженог града, или уступање тих средстава постојећем привредном субјекту или правном лицу које може вршити послове из надлежности града у области стамбених односа, не може сматрати променом власништва над капиталом. Одредбе из чл. 152. Закона о раду примењују се у случају промене власништва над капиталом када до такве промене дође у поступку приватизације државног или друштвеног капитала, односно у промету приватизованог капитала привредних друштава и других правних лица. Реч је о промени власништва над већинским делом капитала послодавца.

У овом случају се не може признати постојање пасивне (стварне) легитимације туженог града за учешће у овој парници ни применом правила наведеног Закона о јавним агенцијама и Закона о стечају, нити у складу са одлуком о оснивању Стамбене агенције, макар да је оснивач учествовао у финансирању делатности те агенције сопственим средствима, односно из свог буџета и поверио тој јавној служби обављање послова из своје надлежности, односно надлежности општине у складу са Законом о локалној самоуправи који се обављају од стране органа локалне самоуправе, будући да се ради о обавезама које се односе на испуњење новчаних и других потраживања трећих лица насталих обављањем делатности због којих је стамбена агенција основана, при чему се не може сматрати да се ради и о обавези решавања радно правног статуса запослених код те агенције због њеног укидања, односно због њене ликвидације, имајући притом у виду и нарочито околност да је агенција правно егзистирала у време доношења одлуке о њеном укидању и да је касније извршена ликвидација у законом прописаном поступку, због чега више не постоји правни основ да се у овом поступку реши питање њихове реинтеграције, с обзиром да су пропустили да захтевају поништај предметних решења према стамбеној агенцији чији је надлежни орган донео та

решења, тако да су она постала правноснажна у односу на послодавца тужилаца“.

Уместо закључка

Код оцене законитости одлука о статусу нераспоређености и престанку радног односа у вези са применом Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији, код послодавца који представљају органе јединица локалне самоуправе (општинске и градске управе) релевантно је постојање, вишка запослених према критеријумима за одређивање укупног максималног броја запослених у тим органима на неодређено време које пописује тај закон. Исто важи и за установе, привредна друштва и друге облике организовања чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе. С тим у вези јесте релевантно и постојање реорганизационих промена у смислу промена у организацији и методу рада, односно услед смањења обима и укидања послова, односно укидања појединих општинских управа или градских управа, или установа, односно спајање два или више органа (чл. 65, 67 и 68. Закона о радним односима у државним органима), када се ради о општинским и градским управама, а за послодавце који представљају установе, привредна друштва или други облик организовања, битне су околности о постојању технолошких, економских или организационих промена (чл. 153. Закона о раду). С тим у вези, релевантно је постојање нове систематизације послова и радних места, након извршене реорганизације.

Правилност и законитост одлука о стицању статуса нераспоређеног запосленог и о престанку радног односа расправља се само са аспекта правилности примене предвиђених критеријума Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији на основу којих се индивидуализује вишак запослених (оцена резултата рада и имовно стање) и то још у поступку доношења првостепеног решења којим је утврђен статус нераспоређености.

У случају када је новим актом о систематизацији радних места у смислу чл. 2. ст. 6. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији укинута радно место на коме је запослени радио у општинској управи или градској управи, установи, привредном друштву и другом облику организовања из чл. 1. Закона, тада послодавац нема оба-

везу да врши оцену резултата рада и утврђује имовно стање запосленог за чијим радом је престала потреба и који је стекао статус нераспоређеног лица. Међутим, у случају смањења броја извршилаца на појединим радним местима, тада се законитост одлука о нераспоређености и престанку радног односа, односно отказа уговора о раду, има оценити са аспекта правилности примене критеријума (резултати рада и имовно стање) у складу и у обиму како је то утврђено Општим колективним уговором, при чему је релевантна околност постојања писане, образложене оцене руководиоца код туженог послодавца о његовим резултатима рада и резултатима рада осталих извршилаца послова на којима је радио тужилац до доношења оспорених одлука и писана форма о доказима и о начину утврђивања имовног стања тужиоца и имовног стања осталих запослених који су радили на истим или сличним пословима које је обављао тужилац до доношења оспорених одлука.

Имајући у виду одредбе из чл. 9. ст. 1. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији, којима је прописано да запослени у органима јединица локалне самоуправе, који након ступања на снагу акта о систематизацији радних места из чл. 2. ст. 6. тог Закона постану нераспоређени, остварују права у складу са прописима којима се уређују права запослених у органима јединица локалне самоуправе, и имајући у виду одредбе из чл. 66. ст. 1. у вези чл. 65. Закона о радним односима у државним органима, произилази да се у тој ситуацији наведеним лицима могу признати само права садржана у чл. 158. и 160. Закона о раду. Ово отуда, јер је наведеним одредбама, наведеног закона, прописано да запослени у државним органима који су остали нераспоређени на начин утврђен у чл. 65. тог Закона, имају права и обавезе као запослени за чијим радом је престала потреба у предузећима, утврђена законом. Ради се о запосленима који су стекли статус нераспоређених услед промена у организацији и методу рада, односно услед смањења обима и укидања послова. Права из чл. 158. и 160. Закона о раду и то право на отпремнину и на новчану накнаду за случај незапослености призната су наведеној категорији лица и самим Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији, чл. 9. ст. 2, 3. и 4.

Због посебности Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији, како у односу на Закон о радним односима у државним органима, тако и у односу на Закон о раду, у поступку решава-

ња вишка запослених код органа у јединицама локалне самоуправе, и регулативе из претходно наведених одредби, из наведених законских прописа, старешина општинске и градске управе, који је утврдио да је за радом одређеног броја запослених, односно постављених лица престала потреба услед промене организације или метода рада или укидања и смањења броја извршилаца на појединим радним местима, не би био обавезан да донесе програм решавања вишка запослених у смислу чл. 153. Закона о раду.

Ако дође до престанка радног односа запосленима услед престанка рада послодавца над којим је отворен ликвидациони поступак, а који јесу правна лица против којих је изузето спровођење стеченог поступка у смислу чл. 14. ст. 1. Закона о стечају, тада се поступак за оцену законитости одлуке о престанку радног односа може покренути против тих послодаваца све до тренутка закључења поступка ликвидације, односно брисања субјекта ликвидације из судског регистра. У смислу одредби наведеног члана, наведеног закона, стечајни поступак се не спроводи према: Републици Србији; аутономним покрајинама, органима локалне самоуправе; фондовима или организацијама обавезног пензијског, инвалидског, социјалног и здравственог осигурања; правним лицима чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, а која се искључиво или претежно финансирају кроз уступљене јавне приходе или из републичког буџета аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе; народној банци Србије; Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности; јавним агенцијама.

У поступку смањења броја запослених код послодаваца из чл. 1. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији потребно је да послодавац води рачуна о категорији запослених из чл. 41. ст. 2. и 42. Општег колективног уговора и из чл. 53. Посебног колективног уговора за државне органе.